

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 甲은 S시에 600㎡의 토지를 소유하고 있다. S시장 乙은 2002년 5월 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의거하여 수립한 도시관리계획으로 甲의 토지가 포함된 일대에 대해 공원구역으로 지정하였다가 2006년 5월 민원에 따라 甲의 토지를 주거지역으로 변경지정하였다. 乙은 2010년 3월 정부의 녹색도시 조성 정책에 부응하여 도시근린공원을 조성하고자 甲의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점) -24회 1번

1) 甲은 乙이 2010년 3월 그의 토지에 대해 녹지지역으로 재지정한 것은 신뢰 보호의 원칙에 위배될 뿐만 아니라, 당해 토지 일대의 이용상황을 고려하지 아니한 결정이었다고 주장하며, 녹지지역 지정을 해제할 것을 요구하고자 한다. 甲의 주장이 법적으로 관철될 수 있는가에 대하여 논하시오. (20점)

2) 乙은 공원조성사업을 추진하기 위하여 甲의 토지를 수용하였는데, 보상금산정시 녹지지역을 기준으로 감정평가한 금액을 적용하였다. 그 적법성 여부를 논하시오. (20점)

【문제 2】 甲은 하천부지에 임시창고를 설치하기 위하여 관할청에 하천점용허가를 신청하였다. 이에 관할청은 허가기간 만료 시에 위 창고건물을 철거하여 원상복구할 것을 조건으로 이를 허가하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

-20회 2번 변형

1) 甲이 위 조건에 대하여 취소소송으로 다툴 수 있는지 여부와, 본안에서 위 조건이 위법하다고 인정될 때 수소법원이 위 조건만을 취소하는 판결을 할 수 있는지 검토하시오. (30점)

2) 甲은 창고건물철거에 따른 손실보상을 청구할 수 있는지 검토하시오. (10점)

【문제 3】 20년 이상 감정평가업에 종사하고 있는 감정평가사 甲은 2년 전에 국토교통부장관 乙의 인가를 받아 50명 이상의 종업원을 고용하는 감정평가법인을 설립하였다. 그 후 乙은 甲이 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 감정평가법인의 설립인가를 받았다는 이유로 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제32조 제1항 제13호에 따라 설립인가를 취소하였다. 甲은 乙의 인가취소가 잘못된 사실관계에 기초한 위법한 처분이라는 이유로 취소소송을 제기하면서 집행정지신청을 하였다. 甲의 집행정지신청의 인용여부를 논하시오. (20점)

- 23회 3번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '공익사업법'이라 한다)에 따라 도로확장건설을 위해 사업인정을 받은 A는 해당 지역에 위치한 甲의 토지를 수용하고자 甲과 협의를 시도하였다. A는 甲과 보상액에 관한 협의를 이루어지지 않자 공익사업법상의 절차에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청하였다. 그런데 관할 토지수용위원회는 「감정평가에 관한 규칙(국토교통부령)」에 따른 '감정평가 실무기준(국토교통부 고시)'과는 다르게 용도지역별 지가변동률이 아닌 이용상황별 지가변동률을 적용한 감정평가사의 감정결과를 채택하여 보상액을 결정하였다. 그 이유로 해당 토지는 이용상황이 지가변동률에 더 큰 영향을 미친다는 것을 들었다. 다음 물음에 답하십시오. (40점)

- 26회 1번

1) 甲은 보상액 결정이 '감정평가 실무기준(국토교통부 고시)'을 따르지 않았으므로 위법이라고 주장한다. 甲의 주장은 타당한가? (20점)

2) 甲은 위 토지수용위원회의 재결에 불복하여 공익사업법에 따라 보상금의 증액을 구하는 소송을 제기하고자 한다. 이 소송의 의의와 그 특수성을 설명하십시오. (20점)

【문제 2】 다음 각각의 사례에 대하여 답하시오. (30점)

- 22회 2번

1) 국토교통부장관은 감정평가업자 甲에 대하여 법령상 의무 위반을 이유로 6월의 업무정지처분을 하였다. 甲은 업무정지처분취소소송을 제기하였으나 기각되었고 동 기각판결은 확정되었다. 이에 甲은 위 처분의 위법을 계속 주장하면서 이로 인한 재산상 손해에 대해 국가배상청구소송을 제기하였다. 이 경우 업무정지처분취소소송의 위법성 판단과 국가배상청구소송의 위법성 판단의 관계를 설명하시오.(20점)

2) 감정평가업자 乙은 국토교통부장관에게 감정평가사 갱신등록을 신청하였으나 거부당하였다. 그런데 乙은 갱신등록거부처분에 앞서 거부사유와 법적 근거, 의견제출의 가능성 등을 통지받지 못하였다. 위 갱신등록 거부처분의 위법성 여부를 검토하시오. (10점)

【문제 3】 감정평가법인 甲은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제25조의 성실의무 위반을 이유로 같은 법 제32조 제1항 제11호에 의하여 2025년 2월 1일 국토교통부장관으로부터 설립인가취소처분을 통보받았다. 이에 甲은 국토교통부장관이 설립인가취소 시 같은 법 제45조에 의한 청문을 실시하지 않은 것을 이유로 2025년 8월 1일 설립인가취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 甲의 소송은 인용될 수 있는가. (30점)

-17회 2번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교시	시간	시험과목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성명

【문제 1】 A도 도지사 甲은 도내의 심각한 주차난을 해결하기 위하여 A도내 B시 일대 40,000 m²(이하 '이 사건 공익사업구역'이라 함)를 공영주차장으로 사용하고자 사업계획을 수립하고 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)에 따른 절차를 거쳐, 국토교통부장관의 사업인정을 받고 이를 고시하였다. 이후 甲은 이 사건 공익사업구역 내 주택 세입자 乙등이 이 사건 공익사업이 시행되는 동안 임시로 거주할 수 있도록 B시에 임대아파트를 건립하여 세입자에게 제공하는 등 이주대책을 수립·시행하였다. 한편, 乙은 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」(이하 '토지보상법 시행규칙'이라 함) 제54조 제2항에 해당하는 세입자이다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

-29회 1번

1) 乙은 토지보상법 시행규칙에 따른 주거이전비를 받을 수 있는 권리를 포기한다는 취지의 '임대아파트 입주에 따른 주거이전비 포기각서'를 甲에게 제출하고 위 임대아파트에 입주하였지만, 이후 관련 법령이 임대아파트와 같은 임시수용시설 등을 제공받는 자를 주거이전비 지급대상에서 배제하지 않고 있는 점을 알게 되었다. 이에 乙은 위 포기각서를 무시하고 토지보상법 시행규칙 상의 주거이전비를 청구하였다. 乙의 주거이전비 청구의 인용여부에 관하여 논하시오. (30점)

2) 한편, 丙은 이 사건 공익사업구역 밖에서 음식점을 경영하고 있었는데, 이 사건 공익사업으로 인하여 자신의 음식점의 주출입로가 단절되어 일정 기간 휴업을 할 수 밖에 없게 되었다. 이때, 丙은 토지보상법령상 보상을 받을 수 있는가? (10점)

<공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙>

제54조(주거이전비의 보상)

① 공익사업시행지구내 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 해당 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다.

② 공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자(법제78조제1항에 따른 이주대책대상자인 세입자는 제외한다)로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시 해당 공익사업시행지구안에서 3개월 이상 거주한 자에 대하여는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있는 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대하여는 본문에 따라 주거이전비를 보상하여야 한다.

【문제 2】 한국수자원공사는 한국수자원공사법 제9조 및 제10조에 근거하여 수도권(首都圈) 광역상수도사업 실시계획을 수립하여 국토해양부장관의 승인을 얻은 후, 1필지인 甲의 토지 8,000㎡ 중 6,530㎡를 협의취득하였다. 협의취득 후 甲의 잔여지는 A지역 495㎡, B지역 490㎡, 그리고 C지역 485㎡로 산재(散在)하고 있다. (30점)

-23회 2번

1) 甲은 위 잔여지의 토지가격의 감소를 이유로 손실보상을 청구하려고 한다. 이 경우 잔여지의 가격감소에 대한 甲의 권리구제방법을 설명하시오. (15점)

2) 호텔을 건립하기 위해 부지를 조성하고 있던 甲은 자신의 잔여지를 더 이상 종래의 사용목적대로 사용할 수 없게 되자 사업시행자와 매수에 관한 협의를 하였으나, 협이가 성립되지 아니하였다. 이에 甲은 관할 토지수용위원회에 잔여지의 수용을 청구하였지만, 관할 토지수용위원회는 이를 받아들이지 않았다. 이 경우 잔여지수용청구의 요건과 甲이 제기할 수 있는 행정소송의 형식을 설명하시오. (15점)

【문제 3】 법원으로부터 근저당권에 근거한 경매를 위한 감정평가를 의뢰받은 감정평가사 乙이 감정평가 대상토지의 착오로 실제 대상토지의 가치보다 지나치게 낮게 감정평가액을 산정하였다. 토지소유자인 甲이 이에 대해 이의를 제기하였음에도 경매담당 법관 K는 乙의 감정평가액을 최저입찰가격으로 정하여 경매절차를 진행하였으며, 대상토지는 원래의 가치보다 결국 낮게 丙에게 낙찰되어 甲은 손해를 입게 되었다. 甲이 법관의 과실을 이유로 국가배상을 청구한 경우 이 청구의 인용가능성을 검토하시오. (20점)

- 25회 3번

【문제 4】 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정고시의 효과에 대해 설명하시오. (10점)

- 23회 4번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교시	시간	시험과목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성명

【문제 1】 관할 A시장은「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 甲소유의 토지에 대해 공시기준일을 2018. 1. 1.로 한 개별공시지가를 2018. 6. 28. 결정·공시하고(당초 공시지가) 甲에게 개별통지하였으나, 이는 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 것이었다. 이후 甲소유의 토지를 포함한 지역 일대에 개발사업이 시행되면서 관련법에 의한 부담금 부과 대상이 된 甲의 토지에 대해 A시장은 2018. 8. 3. 당초 공시지가에 근거하여 甲에게 부담금을 부과하였다. 한편 甲소유 토지에 대한 당초 공시지가에 이의가 있는 인근 주민 乙은 이의신청기간이 도과한 2018. 8. 10. A시장에게 이의를 신청하였고, A시장은 甲소유 토지에 대한 당초 공시지가를 결정할 때 토지가격비준표의 적용에 오류가 있었음을 이유로「부동산 가격공시에 관한 법률」제12조 및 같은 법 시행령 제23조제1항에 따라 개별공시지가를 감액하는 정정을 하였고, 정정된 공시지가는 2018. 9. 7. 甲에게 통지되었다. 다음 물음에 답하십시오. (아래 설문은 각각 별개의 독립된 상황임) (40점)

-30회 1번

물음 1) 甲은 정정된 공시지가에 대해 2018. 10. 22. 취소소송을 제기하였다. 甲의 소송은 적법한가? (15점)

물음 2) 甲은 이의신청기간이 도과한 후에 이루어진 A시장의 개별공시지가 정정처분은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장은 타당한가? (10점)

물음 3) 만약, A시장이 당초 공시지가에 근거하여 甲에게 부담금을 부과한 것이 위법한 것이더라도, 이후 A시장이 토지가격비준표를 제대로 적용하여 정정한 개별공시지가가 당초 공시지가와 동일하게 산정되었다면, 甲에 대한 부담금 부과 하자는 치유되는가? (15점)

【문제 2】 甲은 A시의 시외로 나가는 일반도로에 접한 자신 소유의 X토지에 교통로를 개설하고 대형음식점을 운영하고 있다. A시에서는 X토지와 이에 접하여 연결된 Y·W토지의 소유권을 취득하여 혼잡한 교통량을 분산할 목적으로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거하여 우회도로를 설치한다는 방침을 결정하고, A시의 시장은 X·Y·W토지의 개별공시지가 및 이 개별공시지가 산정의 기초가 된 P토지의 표준지공시지가와 도매물가상승률 등을 반영하여 산정한 보상기준가격을 내부적으로 결정하고 예산확보를 위해 중앙부처와 협의 중이다. 다음 물음에 답하시오. (30점) -25회 2번

1) 甲은 보상이 있을 것을 예상하여 더 많은 보상금을 받기 위해 부동산 가격공시에 관한 법률에 의거하여 감정평가사를 통해 산정된 P토지의 표준지공시지가에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다. 이 경우 甲에게 법률상 이익이 있는지 여부를 검토하시오. (15점)

2) 위 취소소송에 P토지의 소유자인 丙이 소송에 참가할 수 있는지 여부와 甲이 확정 인용판결을 받았다면 이 판결의 효력은 Y·W토지의 소유자인 乙에게도 미치는지에 대하여 설명하시오. (15점)

【문제 3】 지목은 대(垓)이지만, 그 현황이 인근 주민의 통행에 제공된 사실상 도로인 토지를 대상으로 도시 및 주거환경정비법에 따른 매도청구권을 행사하는 경우와 토지보상법에 따른 수용재결이 행하여야 하는 경우에 관하여 다음 물음에 답하시오. (20점) -28회 3번

1) 매도청구권 행사에 따른 쟁송절차와 수용재결에 따른 보상금을 다투는 쟁송절차의 차이점을 설명하시오. (10점)

2) 토지의 감정평가방법과 그 기준에 있어 매도청구권이 행사되는 경우와 수용재결이 행하여지는 경우의 차이점을 설명하시오. (10점)

【문제 4】 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제26조는 수용재결 신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 협의제도를 규정하고 있다. 이에 따른 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 여부와 관할 토지수용위원회에 의한 협의성립의 확인의 법적 효과를 설명하시오. (10점) - 30회 4번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 국토부장관은 2013. 11. 18. 사업시행자를 'A공사'로, 사업시행지를 'X시 일대 8,958,000㎡'로, 사업시행기간을 '2013. 11.부터 2017. 12. 까지'로 하는 '◇◇공구사업'에 대해서 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정을 고시하였고, 사업시행기간은 이후 '2020. 12.까지'로 연장되었다. 甲은 ㉠토지 78,373㎡와 ㉡토지 2,334㎡를 소유하고 있는데, ㉠토지의 전부와 ㉡토지의 일부가 사업시행지에 포함되어 있다. 종래 甲은 ㉠토지에서 하우스 딸기농사를 지어 왔고, ㉡토지에서는 농작물직거래판매장을 운영하여 왔다. 甲과 A공사는 사업시행지 내의 토지에 대해 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 협의의 매수를 하기 위한 협의를 시작하였다. 다음 물음에 답하시오.(아래의 물음은 각 별개의 상황임) (40점) -32회 1번

물음 1) 협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. (15점)

물음 2) ㉠토지에 대하여 협의가 성립되지 않았고, A공사의 수용재결신청에 의하여 ㉠토지가 수용되었다. 甲은 ㉠토지가 수용되었음을 이유로 A공사를 상대로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 농업손실보상을 청구할 수 있는지를 검토하시오. (10점)

물음 3) 협의가 성립되지 않아 사업시행지 내의 ㉡토지가 수용되었다. 그 후 甲은 ㉡토지의 잔여지에 대해서 2020. 11. 12. 잔여지수용청구를 하였다. 잔여지수용청구권의 법적 성질과 甲의 잔여지수용청구가 인정될 수 있는지를 검토하시오. (15점)

[참조조문]**<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>**

제28조(재결의 신청) ① 제26조에 따른 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때 (제26조제2항 단서에 따른 협의 요구가 없을 때를 포함한다)에는 사업시행자는 사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

② <생략>

제30조(재결 신청의 청구) ① 사업인정고시가 된 후 협의가 성립되지 아니하였을 때에는 토지소유자와 관계인은 대통령령을 정하는 바에 따라 서면으로 사업시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있다.

② <이하 생략>

제77조(영업의 손실 등에 대한 보상) ① 영업을 폐업하거나 휴업함에 따른 영업손실에 대하여는 영업이익과 시설의 이전비용 등을 고려하여 보상하여야 한다. ② 농업의 손실에 대하여는 농지의 단위면적당 소득등을 고려하여 실제 경작자에게 보상하여야 한다. 다만, 농지소유자가 해당 지역에 거주하는 농민인 경우에는 농지소유자와 실제 경작자가 협의하는 바에 따라 보상할 수 있다.

③ <이하 생략>

【문제 2】 B시에 거주하는 甲은 2005년 5월 자신의 토지 위에 주거용 건축물을 신축하였다. 그런데 甲은 건축허가 요건을 충족하지 못하여 행정기관의 허가없이 건축하였다. 甲은 위 건축물에 입주하지 않았으나, 친척인 乙이 자신에게 임대해 달라고 요청하여 이를 허락하였다. 乙은 필요시 언제든지 건물을 비워주겠으며, 공익사업시행으로 보상의 문제가 발생할 때에는 어떠한 보상도 받지 않겠다는 내용의 각서를 작성하여 임대차계약서에 첨부하였다. 乙은 2006년 2월 위 건축물에 입주하였는데, 당시부터 건축물의 일부를 임의로 용도변경하여 일반음식점으로 사용하여 왔다. 甲의 위 토지와 건축물은 2015년 5월 14일 국토교통부장관이 한 사업인정 고시에 따라서 공익사업시행지구로 편입되었다. 甲은 이 사실을 알고 동년 6월에 위 건축물을 증축하여 방의 개수를 2개 더 늘려 자신의 가족과 함께 입주하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점) -26회 2번

1) 위 甲의 건축물은 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 손실보상의 대상이 되는지, 만일 된다면 어느 범위에서 보상이 이루어져야 하는지 설명하시오. (10점)

2) 甲과 乙은 주거이전비 지급 대상자에 포함되는지 여부를 그 지급 요건에 따라서 각각 설명하시오. (20점)

【문제 3】 감정평가사 甲과 乙은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가준칙을 위반하여 감정평가를 하였음을 이유로 업무정지처분을 받게 되었으나, 국토교통부장관은 그 업무정지처분이 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준공시지가 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래할 우려가 있음을 들어, 2021. 4. 1. 甲과 乙에게 업무정지처분을 갈음하여 각 3천만원의 과징금을 부과하였다. 다음 물음에 답하십시오.(20점) -32회 3번

물음 1) 甲은 부과된 과징금이 지나치게 과중하다는 이유로 국토교통부장관에게 이의신청을 하였고, 이에 대해서 국토교통부장관은 2021. 4. 30. 甲에 대하여 과징금을 2천만원으로 감액하는 결정을 하였다. 甲은 감액된 2천만원의 과징금도 과중하다고 생각하여 과징금부과처분의 취소를 구하는 소를 제기하고자 한다. 이 경우 甲이 취소를 구하여야 하는 대상은 무엇인지 검토하십시오.(10점)

물음 2) 乙은 2021. 6. 1. 자신에 대한 3천만원의 과징금부과처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 이에 대한 심리 결과 법원이 적정한 과징금의 액수는 1천5백만원이라고 판단하였을 때, 법원이 내릴 수 있는 판결의 내용에 관하여 검토하십시오.(10점)

【문제 4】 甲 소유의 토지를 포함하는 일단의 토지가 공공토지의 비축에 관한 법률에 따라 X읍-Y읍간 도로사업용지 비축사업(이하 '이 사건 비축사업'이라 함) 지역으로 지정되었고, 한국토지주택공사를 사업시행자로 하여 2014. 3. 31. 이 사건 비축사업에 대하여 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정 고시가 있었다. 한편, 관할 도지사는 X읍-Y읍간 도로확포장공사와 관련하여 2016. 5. 1. 도로구역을 결정·고시하였는데, 甲의 토지는 도로확포장공사가 시행되는 도로구역 인근에 위치하고 있다. 이후 이 사건 비축사업을 위하여 甲 소유의 토지에 대해 2016. 7. 5. 관할 토지수용위원회의 수용재결이 있어는 바, 위 도로확포장공사로 인하여 상승된 토지가격이 반영되지 않는 감정평가가격으로 보상금이 결정되었다. 이에 甲은 도로확포장공사로 인한 개발이익이 배제된 보상금 결정은 위법하다고 주장하는 바, 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하십시오. (10점) -28회 4번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 A대도시의 시장은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시관리 계획으로 관할구역 내 oo동 일대 90,000m² 토지에 공영주차장과 자동차정류장을 설치하는 도시계획시설사업결정을 한 후 지방공기업법에 따른 A대도시 X지방공사(이하 'X공사'라 함)를 도시계획시설사업의 시행자로 지정하고, X공사가 작성한 실시계획에 대해 실시계획인가를 하고 이를 고시하였다. 이에 따라 공익 사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '토지보상법'이라 함)에 의해 사업인정 및 고시가 이루어졌다. 한편, X공사는 사업대상구역 내에 위치한 20,000m² 토지를 소유한 甲과 토지수용을 위한 협의를 진행하였으나 협의가 성립되지 아니하여 관할 지방토지수용위원회에 토지수용의 재결을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호독립적임) (40점) -34회 1번

물음 1) 토지보상법상의 사업인정과 사업인정고시의 법적 성질에 관하여 설명하시오. (10점)

물음 2) 甲은 수용 자체가 위법이라고 주장하면서 관할 지방토지수용위원회의 수용재결과 중앙토지수용위원회의 이의재결을 거친 후 취소소송을 제기하였다. 취소소송의 대상적격과 피고적격에 관하여 설명하시오. (20점)

물음 3) 甲은 자신의 토지에 대한 보상금이 적으며, 일부 지장물이 손실보상 대상에서 제외되었다는 이유로 관할 지방토지수용위원회의 수용재결에 불복하여 중앙토지수용위원회에 이의신청을 거쳤으나 기각재결을 받았다. 甲이 이에 대하여 불복하는 경우 적합한 소송 형태를 쓰고 이에 관하여 설명하시오. (10점)

[참조 조문]**<국토의 계획 및 이용에 관한 법률>**

제88조(실시계획의 작성 및 인가 등) ① 도시·군계획시설사업의 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획(이하 "실시계획"이라 한다)을 작성하여야 한다.

② 도시·군계획시설사업의 시행자(국토교통부장관, 시도지사 및 대도시 시장은 제외한다. 이하 제3항에서 같다)는 제1항에 따라 실시계획을 작성하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장의 인가를 받아야 한다. 다만, 제98조에 따른 준공검사를 받은 후에 해당 도시·군계획시설사업에 대하여 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하기 위하여 실시계획을 작성하는 경우에는 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장의 인가를 받지 아니한다.

제96조(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 준용) ① 제95조에 따른 수용 및 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

② 제1항에 따라 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용할 때에 제91조에 따른 실시계획을 고시한 경우에는 같은 법 제20조제1항과 제22조에 따른 사업인정 및 그 고시가 있었던 것으로 본다. 다만, 재결 신청은 같은 법 제23조제1항과 제28조제1항에도 불구하고 실시계획에서 정한 도시·군계획시설사업의 시행기간에 하여야 한다.

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>

제28조(재결의 신청) ① 제26조에 따른 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때(제26조제2항 단서에 따른 협의 요구가 없을 때를 포함한다)에는 사업시행자는 사업인정고시가 된 날부터 1년이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.

제83조(이의의 신청) ① 중앙토지수용위원회의 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.

② 지방토지수용위원회의 제34조에 따른 재결에 이의가 있는 자는 해당 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 이의의 신청은 재결서의 정본을 받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

제84조(이의신청에 대한 재결) ① 중앙토지수용위원회는 제83조에 따른 이의신청을 받은 경우 제34조에 따른 재결이 위법하거나 부당하다고 인정할 때에

는 그 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다.

② 제1항에 따라 보상금이 늘어난 경우 사업시행자는 재결의 취소 또는 변경의 재결서 정본을 받은 날부터 30일 이내에 보상금을 받을 자에게 그 늘어난 보상금을 지급하여야 한다. 다만, 제40조제2항제1호·제2호 또는 제4호에 해당할 때에는 그 금액을 공탁할 수 있다.

【문제 2】 甲은 A시에 토지를 소유하고 있다. A시장은 甲의 토지 등의 비교표준지로 A시 소재 일정 토지(2020. 1. 1. 기준 공시지가가 1㎡당 1,000만원이다)를 선정하고, 甲의 토지 등과 비교표준지의 토지가격비준표상 총 가격 배율을 1.00으로 조사함에 따라 甲의 토지가격을 1㎡당 1,000만원으로 산정하였다. A시장으로부터 산정된 가격의 검증을 의뢰받은 감정평가사 乙은 甲의 토지가 비교표준지와 비교하여 환경조건, 획지조건 및 기타조건에서 열세에 있고, 특히 기타조건과 관련하여 비교표준지는 개발을 위한 거래가 이어지고 있으나 甲의 토지 등은 개발 움직임이 없다는 점을 '장래의 동향'으로 반영하여 91%의 비율로 열세에 있다고 보아, 비교표준지의 공시지가를 약 83.9%의 비율로 감액한 1㎡당 839만원을 개별공시지가로 정함이 적정하다는 검증의견을 제시하였다. A시장은 A시부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이 검증의견을 그대로 받아들여 2020. 5. 20. 甲의 토지의 개별공시지가를 1㎡당 839만원으로 결정·공시하고, 甲에게 개별 통지하였다. 甲은 토지가격비준표에 제시된 토지특성에 기초한 가격배율을 무시하고 乙이 감정평가방식에 따라 독자적으로 지가를 산정하여 제시한 검증의견을 그대로 반영하여 개별공시지가를 결정한 것은 위법하다고 보아, 「부동산 가격공시에 관한 법률」제11조에 따라 2020. 6. 15. 이의신청을 제기하였고, 2020. 7. 10. 이의를 기각하는 내용의 이의신청결과가 甲에게 통지되었다. 다음 물음에 답하시오.(아래의 물음은 각 별개의 상황임)(30점) -32회 2번

물음 1) 甲은 2020. 9. 10. 개별공시지가결정에 대해 취소소송을 제기하였다. 甲이 제기한 취소소송은 제소기간을 준수하였는가?(10점)

물음 2) 甲이 개별공시지가결정에 대해 다투지 않은 채 제소기간이 도과하였고, 이후 甲의 토지에 대해 수용재결이 있었다. 甲이 보상금의 증액을 구하는 소송에서 개별공시지가결정의 위법을 주장하는 경우, 甲의 주장은 인용될 수 있는가?(20점)

[참조 조문]**<부동산 가격공시에 관한 법률>**

제11조(개별공시지가에 대한 이의신청) ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다. ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따라 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제10조에 따라 개별공시지가를 조정하여 다시 결정·공시하여야 한다.

<부동산 가격공시에 관한 법률 시행령>

제18조(개별공시지가의 검증) ① <생략>

② 법 제10조제5항 본문에 따라 검증을 의뢰받은 감정평가법인은 다음 각 호의 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.

1. 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
2. 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
3. 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
4. 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와와의 균형 유지에 관한 사항
5. 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산가격 및 비주거용 개별부동산가격 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
7. 개별토지가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부(公簿)와 일치하는지 여부
- 7그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항

<행정심판법>

제3조(행정심판의 대상) ① 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 의하여 행정심판을 제기할 수 있다.

【문제 3】 X군에 거주하는 어업인들을 조합원으로 하는 A수산업협동조합(이하 'A조합'이라 함)은 조합원들이 포획·채취한 수산물의 판매를 위탁받아 판매하는 B수산물위탁판매장(이하 'B위탁판매장'이라 함)을 운영하여 왔다. 한편, B위탁판매장 운영에 대해서는 관계 법령에 따라 관할 지역에 대한 독점적 지위가 부여되어 있었으며, A조합은 B위탁판매장 판매액 중 일정비율의 수수료를 지급받아 왔다. 그런데, 한국농어촌공사는「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 X군 일대에 대한 공유수면매립면허를 받아 공유수면매립사업을 시행하였고, 해당 매립사업의 시행으로 인하여 사업대상지역에서 어업활동을 하던 A조합의 조합원들은 더 이상 조업을 할 수 없게 되었다. A조합은 위 공유수면매립사업 지역 밖에서 운영하던 B위탁판매장에서의 위탁판매사업의 대부분을 중단하였고, 결국에는 B위탁판매장을 폐쇄하기에 이르렀다. 이에 따라 A조합은 공유수면매립사업으로 인한 위탁판매수수료 수입의 감소에 따른 영업손실의 보상을 청구하였으나, 한국농어촌공사는 B위탁판매장이 사업시행지 밖에서 운영되던 시설이었고「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」상 직접적인 보상 규정이 없음을 이유로 보상의 대상이 아니라고 주장한다. 한국농어촌공사의 주장은 타당한가? (20점)

-30회 3번

【문제 4】감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제21조에 따른 '사무소 개설 등'에 관하여 설명하시오. (10점)

-34회 4번

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교시	시간	시험과목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성명

【문제 1】 A지방자치단체는 도로사업 부지를 취득하기 위하여 甲의 토지를 협의 취득하여 공공용지의 협의취득을 원인으로 하는 소유권이전등기를 하였고, 乙의 토지에 대하여는 수용재결에 의하여 소유권을 취득한 후 소유권이전 등기를 마쳤다. 그러나 甲과 乙의 토지(이하 '이 사건 토지'라 함)가 관내의 택지개발예정 지구에 포함되자 A지방자치단체는 이 사건 토지가 도로 사업에 더 이상 제공될 수 없는 상황에서 도로사업의 목적 달성이 불가능 하다고 판단하여, 당초 협의 취득 및 수용의 목적이 된 해당 도로사업을 폐지하였다. 이에 따라 甲과 乙에게 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 환매권이 발생하였다. 甲은 협의취득 당시에 수령한 보상금 상당 금액을 공탁한 후, A지방자치단체에게 환매의 의사표시를 하고 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 한편, 乙이 환매권을 행사할 무렵 환매금액에 관한 A지방자치단체와 乙의 협의가 성립되지 아니하여, A지방자치단체는 환매 대상 토지의 현재 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 상승하였음을 들어 환매대금의 증액을 구하는 소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점) -35회 1번

물음 1) 乙의 환매권 및 乙에 대한 환매대금증액청구소송의 법적 성질을 각각 설명하시오. (15점)

물음 2) 甲의 소유권이전등기청구소송에서, A지방자치단체는 환매 대상 토지 가격의 상승에 따른 환매대금증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의 차액을 지급할 것을 선(先)이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수 있는지에 관하여 설명하시오. (10점)

물음 3) 만약 乙의 토지에 대한 수용재결에 취소사유에 해당하는 하자가 있어 乙이 환매권 행사 이전에 수용재결의 하자를 이유로 자신의 소유권 회복을 위한 소유권이전등기말소청구소송을 제기한 경우, 그 승소 여부를 검토하시오. (단, 수용재결에 불가쟁력이 발생하였음) (15점)

[참조 조문]**< 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 >**

제91조 (환매권) ① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 "취득일"이라 한다) 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인(이하 "환매권자"라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할수 있다.

1. 사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 제24조에 따른 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날

2. 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 사업완료일

②~③ < 생략 >

④ 토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 환매권은 「부동산등기법」에서 정하는 바에 따라 공익사업에 필요한 토지의 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다.

【문제 2】 국토교통부장관은 표준지로 선정된 A토지의 2022. 1. 1. 기준 공시지가를 1㎡당 1,000만원으로 결정·공시하였다. 국토교통부장관은 A토지의 표준지공시지가를 산정함에 있어 부동산 가격공시에 관한 법률 및 같은 법 시행령이 정하는 '토지의 일반적인 조사사항' 이외에 국토교통부 훈령인 표준지공시지가 조사·평가 기준 상 상업·업무용지 평가의 고려사항인 '배후지의 상태 및 고객의 질과 양', '영업의 종류 및 경쟁의 상태' 등을 추가적으로 고려하여 평가하였다. 甲은 X시에 상업용지인 B토지를 소유하고 있다. X시장은 A토지를 비교표준지로 선정하여 B토지에 대한 개별공시지가를 1㎡당 1,541만원으로 결정·공시 후 이를 甲에게 통지하였다. 甲은 국토교통부장관이 A토지의 표준지공시지가를 단순히 행정청 내부에서만 효력을 가지는 국토교통부 훈령 형식의 표준지공시지가 조사·평가 기준 이 정하는 바에 따라 평가함으로써 결과적으로 부동산가격공시에 관한 법령이 직접 규정하지 않는 사항을 표준지공시지가 평가의 고려사항으로 삼은 것은 위법하다고 주장하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

-33회 2번

물음 1) 표준지공시지가 조사·평가 기준의 법적 성질에 비추어 甲 주장의 타당성 여부를 설명하시오. (20점)

물음 2) 甲은 부동산 가격공시에 관한 법률 제11조에 따라 X시장에게 B토지의 개별공시지가에 대한 이의를 신청하였으나 기각되었다. 이 경우 甲이 기각결정에 불복하여 행정심판법상의 행정심판을 제기할 수 있는지 설명하시오. (10점)

[참조 조문]

<부동산 가격공시에 관한 법률>

제11조(개별공시지가에 대한 이의신청) ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

<부동산 가격공시에 관한 법률 시행령>

제6조(표준지공시지가 조사·평가의 기준) ① 법 제3조제4항에 따라 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우 참작하여야 하는 사항의 기준은 다음 각 호와 같다. <각 호 생략>

② 표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권

리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 표준지공시지가의 조사·평가에 필요한 세부기준은 국토교통부장관이 정한다.

<표준지공시지가 조사·평가 기준>

제23조(상업·업무용지) 상업·업무용지(공공용지를 제외한다)는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 토지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다. <단서 생략>

1. 배후지의 상태 및 고객의 질과 양
2. 영업의 종류 및 경쟁의 상태
- 3.~6. <생략>

【문제 3】 국토교통부장관은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제6조(감정평가서)에 반하는 감정평가서를 작성·발급하였다는 이유로 감정평가사 甲에게 3월의 업무정지처분을 하였다. 甲은 위 처분에 대하여 행정심판을 청구 하였고, 행정심판위원회는 “국토교통부장관은 甲에게 한 3월의 업무정지 처분을 2월의 업무정지처분으로 변경하라”는 재결을 하였다. 국토교통부 장관은 위 재결취지에 따라 “3월의 업무정지처분을 2월의 업무정지처분으로 변경한다”는 후속 변경처분을 하였다. 다음 물음에 답하시오. (20점) -36회 3번

물음 1) 甲이 후속 변경처분을 받은 후에 취소소송을 제기하는 경우 어떠한 처분을 대상으로 하는지 검토하시오. (10점)

물음 2) 위 행정쟁송이 있기 전, 국토교통부장관은 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」상 업무정지처분을 갈음하여 과징금을 부과할 수 있는지, 그리고 甲이 과징금 납부의무를 불이행한 경우 국토교통부장관은 어떠한 조치를 할수 있는지 검토하시오. (10점)

【문제 4】 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제28조 제1항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 감정평가법인등이 하여야 하는 '필요한 조치'의 내용과 '필요한 조치'를 하지 아니한 경우 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 행정상 제재를 설명하시오. (10점) -35회 4번

[참조 조문]

<감정평가 및 감정평가사에 관한 법률>

제28조(손해배상책임) ① 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
3교시	100분	③ 감정평가법규
수험번호		성 명

【문제 1】 주식회사 甲은 30년 넘게 서울특별시 A구에서 콘크리트 제조 공장을 허가 받아 적법하게 운영하고 있다. 甲이 창고로 사용하고 있는 부지(이하 '이 사건 부지'라 함)는 백제 한성기의 왕성 유적으로 알려진 국가지정문화유산 B유적지의 보호구역에 있다. 학계 등은 B유적지의 완전한 복원을 위해서는 이 사건 부지의 수용 필요성을 오래전부터 제기해 왔고, 이 사건 부지에 있는 창고의 증축과정에서 백제 토성의 유물이 발견되기도 하였다. 한편, 관련 법령에 따라 B유적지를 관리하는 A구청장 乙은 B유적지의 정비 및 복원을 위하여 이 사건 부지에 대한 공익사업을 계획하고 국토교통부장관에게 사업인정 신청을 하였다. 국토교통부장관은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)에 따라 사업인정(이하 '이 사건 사업인정'이라 함)을 하고 이를 고시하였다.

甲은 다음과 같은 이유로 이 사건 사업인정 및 고시가 위법하다고 주장한다.

1. 이 사건 부지가 수용되면 공장 운영의 차질 및 콘크리트 공급 감소로 인한 건설 현장의 대혼란을 야기할 수 있으므로 문화유산 보호의 이유로는 수용될 수 없다.
2. 乙은 국가지정문화유산을 관리하는 행정청이지 수용 권한이 있는 것은 아니다.

다음 물음에 답하십시오. (40점)

-36회 1번

물음 1) 토지보상법상 다음의 법적 성격을 설명하십시오. (10점)

- ① 사업인정 전과 후의 '보상에 관한 협의'
- ② 사업인정 후 '협의취득'

물음 2) 甲 주장(1. 및 2.)의 타당성 여부를 검토하십시오. (20점)

물음 3) 이 사건 부지에 대한 수용이 진행될 경우, 甲의 영업손실에 대한 보상요건을 설명하십시오. (10점)

[참조 조문]**<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률>**

제16조(협의) 사업시행자는 토지등에 대한 보상에 관하여 토지소유자 및 관계인과 성실하게 협의하여야 하며, 협의의 절차 및 방법 등 협의에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제20조(사업인정) ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 [별표]>

1. 법 제20조에 따라 사업인정을 받아야 하는 공익사업 (1) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 기본측량의 실시 (2) 「공공토지의 비축에 관한 법률」에 따라 한국토지주택공사가 공공개발용 토지의 비축사업계획을 승인받은 공공개발용 토지의 취득 (3) 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 서울대학교의 학교 용지 확보 (4) 「국립대학법인 인천대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 인천대학교의 학교 용지 확보 (5) 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」에 따른 특화사업 (6) 「농어업재해대책법」에 따른 응급조치 (7) 「대기환경보전법」 제4조에 따라 고시된 측정망설치계획에 따른 환경부장관 또는 시·도지사의 측정망 설치 (8) 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」, 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 문화 유산과 자연유산의 보존·관리

<공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙>

제45조(영업손실의 보상대상인 영업) 법 제77조제1항에 따라 영업손실을 보상하여야 하는 영업은 다음 각 호 모두에 해당하는 영업으로 한다.

1. 사업인정고시일등 전부터 적법한 장소(무허가건축물등, 불법형질변경토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소가 아닌 곳을 말한다)에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업. 다만, 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업을 말한다.
2. 영업을 행함에 있어서 관계법령에 의한 허가등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있는 영업

<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>

제83조(토지의 수용 또는 사용) ① 국가유산청장이나 지방자치단체의 장은 문화유산의 보존·관리를 위하여 필요하면 지정문화유산이나 그 보호구역에 있는 토지, 건물, 나무, 대나무, 그 밖의 공작물을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 수용(收用)하거나 사용할 수 있다.

【문제 2】 甲은 2023. 8. 23. 父로부터 A광역시 B구 소재의 토지(이하 '이 사건 토지'라 함)를 증여 받았고, 이 사건 토지에 관하여 증여 당시에는 2023. 1. 1.을 기준으로 하는 개별공시지가가 m^2 당 2,200,000원으로 결정·고시되어 있었다. 甲은 이를 기초로 하여 산정한 증여세를 납부하고자 하였으나, 개별공시지가에 오류가 있음을 발견하여 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제12조에 따른 개별공시지가 정정결정을 신청하였다. 그런데 B구의 구청장 乙은 甲의 정정결정신청에 대하여 정정불가 결정을 통지하였다. 한편 그 이후 乙은 이 사건 토지에 관하여 토지특성조사의 착오 등 지가산정에 잘못이 있다고 하여 B구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 위 개별공시지가를 m^2 당 3,900,000원으로 정정하여 결정·고시하였다. 이에 관할 세무서장 丙은 이 사건 토지의 가액이 m^2 당 3,900,000원이라고 보아 이를 기초로 증여재산의 가액을 산정하여 증여세부과처분을 하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호독립적임) (30점) -35회 2번

물음 1) 甲이 乙의 정정불가 결정 통지를 대상으로 취소소송을 제기할 수 있는지를 설명하시오. (15점)

물음 2) 甲은 乙의 개별공시지가 정정결정과 관련하여 i) 정정 사유가 있다고 하더라도 그 사유가 명백하여야만 비로소 정정할 수 있는데, 정정 사유가 명백하지 않음에도 불구하고 乙이 개별공시지가를 정정한 것은 위법하다고 주장하고 있다. 또한, ii) 설령 乙의 개별공시지가 정정결정이 타당하다고 하여도 이 사건 토지에 관하여 증여 당시 고시되어 있던 종전의 개별공시지가를 기초로 하지 아니한 丙의 증여세부과처분은 위법하다고 주장하고 있다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 각각 설명하시오. (15점)

[참조 조문]

<부동산 가격공시에 관한 법률>

제12조(개별공시지가의 정정) 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

<행정소송법>

제19조(취소소송의 대상) 취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.

【문제 3】 국방부장관은 국방·군사에 관한 사업을 위하여 국토교통부장관으로부터 甲소유의 토지를 포함한 200필지의 토지 600,000m²에 관하여 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조에 따른 사업인정을 받았다. 그러나 국토교통부장관은 사업인정을 하면서 동법 제21조에 규정된 이해관계인의 의견을 청취하는 절차를 거치지 않았다. 한편, 국방부장관은 甲과 손실보상 등에 관하여 협의하였으나 협의를 성립되지 않았다. 국방부장관은 재결을 신청하였고 중앙토지수용위원회는 수용재결을 하였다. 甲은 수용재결에 대한 취소소송에서 사업인정의 절차상 하자를 이유로 수용재결의 위법성을 주장할 수 있는가? (단, 국토교통부장관의 사업인정에 대한 취소소송의 제소기간은 도과하였음) (20점) -27회 3번

【문제 4】 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제25조에 따른 감정평가법인등의 '성실의무 등'의 내용을 서술하시오. (10점) -32회 4번

2기 1주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (20점)****I. 논점의 정리**

甲의 녹지지역 지정 해제 요구는 계획변경청구에 해당하므로 신뢰보호원칙과 형량명령 준수 여부를 바탕으로 계획변경청구권이 인정되는지를 검토하고, 나아가 甲의 주장이 법적으로 관철될 수 있는지를 논한다.

II. 관련 행정작용의 법적 성질

녹지지역 재지정행위는 국토계획법에 따른 도시·군관리계획으로서 행정계획에 해당하며, 그 지정으로 건축물의 용도, 건폐율, 용적률 등이 제한되어 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로 처분성이 인정된다(개별검토설).

III. 신뢰보호원칙**1. 의의(행정기본법 제12조 제1항)**

신뢰보호원칙이란 행정기관의 적극적, 소극적 언동에 대한 국민의 보호가치 있는 신뢰는 보호해야 한다는 원칙을 말한다.

2. 요건

① 행정청의 선행조치(공적인 견해표명), ② 보호가치 있는 신뢰, ③ 상대방의 조치, ④ 인과관계, ⑤ 선행조치에 반하는 후행처분이 요구된다.

3. 한계

신뢰보호원칙의 요건이 충족되더라도 공익과 사익을 비교형량해야 하며, 공익 또는 제3자의 이익이 더 큰 경우 신뢰보호원칙 적용은 제한된다.

4. 관련 판례 및 사안의 경우

① 판례는 용도지역을 결정한 것만으로는 장래 그 용도지역을 유지하거나 변경하지 않겠다는 취지의 공적인 견해표명을 한 것으로 볼 수 없다고 본다(2002두5474).
② 따라서 2006년 5월 주거지역으로 변경·지정한 것만으로는 주거지역을 유지하거나 변경하지 않겠다는 공적인 견해표명이라 볼 수 없으므로, 녹지지역 재지정은 신뢰보호원칙에 위배되지 않는다.

IV. 형량명령 준수 여부**1. 계획재량의 의의**

계획재량이란 행정주체(계획청)가 행정계획의 수립·변경과정에서 갖게 되는 광범위한 형성의 자유를 말한다.

2. 계획재량의 한계

① 행정계획을 수립함에 있어서는 계획청에게 계획재량이 인정되는데, 이러한 계획재량은 무제한적인 것이 아니라 일정한 한계를 가진다. ② 행정계획은 근거 법령의 목적에 부합하는 것이어야 하며, ③ 행정계획은 그 목적 달성에 필요한 수단이어야 한다. ④ 또한 필요한

수단이라 하더라도 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다(형량명령).

3. 형량명령의 준수

형량명령이란 행정계획을 입안·결정함에 있어서 관련된 이익을 정당하게 형량하여야 한다는 원칙으로서 계획재량의 통제이론이다. 형량하자에는 형량의 해태, 형량의 흠결, 평가의 과오, 오형량이 있다. 이러한 형량하자가 있으면 행정계획은 계획재량권을 일탈·남용한 것으로 위법하게 된다.

4. 사안의 경우

녹지지역 재지정은 정부의 녹색도시조성 시책에 따라 도시근린공원을 조성하기 위한 것으로서 계획재량이 인정된다. 사안에서 당해 토지 일대의 이용상황을 고려하지 않은 결정이라는 사정만으로는 관련 공익과 사익을 정당하게 형량하지 않았다고 볼 수 없으므로 형량하자가 인정되기 어렵다.

V. 계획변경청구권

1. 의의

계획이 확정된 후 사정변경 및 관련 개인의 권익침해 등을 이유로 하여 그 계획의 변경을 청구할 수 있는 권리를 말한다.

2. 인정여부

① 계획법규는 원칙상 공익의 보호를 목적으로 하는 것이며 사익의 보호를 목적으로 하지 않기 때문에 이러한 계획변경청구권은 일반적으로 인정되지 않는다. ② 그러나, 예외적으로 법규상 또는 조리상 계획변경신청권이 인정되는 경우에는 해당 계획의 변경을 청구할 수 있을 것이다.

3. 판례

① 판례는 과거 계획변경청구권을 일반적으로 인정하지 않았으나, 최근에는 긍정적인 입장을 취하고 있다. ② 폐기물처리사업계획의 적정통보를 받은 자의 국토이용계획변경신청(용도지역 변경)을 거부하는 것이 실질적으로 폐기물처리업 허가 자체를 거부하는 결과가 되는 경우, 예외적으로 그 신청인에게 법규상 또는 조리상 행정계획변경을 신청할 권리를 인정하여 신청거부행위의 처분성을 긍정하였다.

VI. 甲의 주장이 법적으로 관철될 수 있는지

국토계획법에는 토지소유자가 용도지역의 변경·해제를 신청할 수 있는 규정이 없으며, 녹지지역 재지정이 실질적으로 다른 처분을 거부하는 결과를 가져오지 않는다. 또한 신뢰보호원칙 위반이나 형량하자도 인정되지 않으므로, 법규상·조리상 계획변경신청권은 인정되지 않는다. 따라서 甲의 주장은 법적으로 관철될 수 없다.

(물음2) (20점)**I. 논점의 정리**

토지보상법 시행규칙 제23조의 공법상 제한을 받는 토지의 평가 기준을 바탕으로 보상금 산정 시 녹지지역을 기준으로 감정평가한 것이 적법한지 검토한다.

II. 토지의 보상평가 기준**1. 헌법상 기준**

헌법 제23조 제3항은 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용·제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급해야 한다고 규정한다. 정당한 보상의 의미에 대해 완전보상설, 상당보상설, 절충설이 있다. 피수용재산의 객관적 재산가치를 완전하게 보상하고, 보상의 시기·방법 등에 어떠한 제한도 없는 완전한 보상을 의미한다고 보는 완전보상설이 타당하며 판례도 이를 취한다.

2. 개발이익 배제

① 개발이익이란 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시되거나 공익사업의 시행, 그 밖에 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인하여 토지소유자가 자기의 노력에 관계없이 지가가 상승되어 현저하게 받은 이익으로서 정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분을 말한다(표준지 조사 평가기준 제2조 제2호).

② 개발이익 배제란 보상금 산정 시 해당 공익사업으로 인한 토지 등의 가격 변동을 고려하지 않는 것을 말한다(토지보상법 제67조 제2항).

III. 공법상 제한받는 토지 평가**1. 공법상 제한을 받는 토지의 의미**

공법상 제한을 받는 토지란 개별 법률에 의해 이용 규제를 받고 있는 토지를 말한다. 공법상 제한에는 일반적 계획제한과 개별적 계획제한이 있다. 일반적 계획제한은 제한 그 자체로 목적이 완성되고 구체적 사업시행이 필요하지 않은 제한을 말한다. 개별적 계획제한이란 그 제한이 구체적 사업시행을 필요로 하는 제한을 말한다.

2. 보상평가 기준**1) 원칙**

공법상 제한받는 토지는 제한받는 상태대로 평가한다(칙 제23조 제1항 본문).

2) 예외**(1) 해당 공익사업시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우**

공법상 제한이 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우에는 제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다(칙 제23조 제1항 단서).

(2) 해당 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 등이 변경된 경우

해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 또는 용도지구 등이 변경된 토지에 대하여는 변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다(칙 제23조 제2항).

이는 해당 공익사업으로 인한 토지 등의 가격 변동을 고려하지 않고 정당보상을 실현하는데 취지가 있다.

IV. 사안의 해결

도시근린공원을 조성하기 위해 녹지지역으로 재지정한 것은 공원조성사업의 시행을 직접 목적으로 용도지역이 변경된 경우에 해당한다. 따라서 변경 전 용도지역인 주거지역을 기준으로 감정평가해야 하며, 녹지지역을 기준으로 감정평가한 것은 적법하지 않다.

[문제2] (40점)

(물음1) (30점)

I. 논점의 정리

하천점용허가 시 부과된 원상복구 조건의 법적 성질을 살펴본 후, 부관의 독립쟁송가능성과 독립취소가능성 여부를 검토한다.

II. 원상복구 조건의 법적 성질

1. 부관의 의의 및 종류

부관이란 주된 행정행위의 효과를 제한하거나 요건을 충족시키기 위하여 부가된 종된 규율을 말하며 조건, 기한, 철회권 유보, 부담 등이 있다.

2. 판단기준

부관의 종류는 행정청의 객관적인 의사에 따라 판단한다. 다만, 그 의사가 불분명하다면 최소침해의 원칙상 사인에게 유리하도록 판단한다.

3. 사안의 경우

부담이란 행정행위의 주된 내용에 부수하여 상대방에게 작위·부작위·급부·수인 등의 의무를 부과하는 부관을 말한다. 사안의 원상복구 조건은 甲에게 작위의무를 부과한 것이므로 조건이란 표현과 관계없이 부담에 해당한다.

III. 부관의 독립쟁송가능성

1. 학설

① 부담은 그 자체가 독립된 행정행위이므로 부담만이 독립적으로 행정쟁송 제기가 가능하고, 그 외의 부관은 부관부행정행위 전체를 소의 대상으로 삼아야 한다고 보는 <부담·기타 부관 구별설>, ② 독립쟁송가능의 문제는 부관의 독립 취소가능성 문제의 전제조건이므로 독립취소가 인정될 수 있을 정도로 주된 행정행위와의 분리가능성을 가지는 부관이라면, 부관만 독립하여 다룰 수 있다고 보는 <분리가능성설>, ③ 부관의 분리가능성은 본안의 문제이며, 소송요건의 문제는 아니기 때문에 모든 부관은 소의 이익이 있는 한 독립하여 취소쟁송의 대상이 된다고 보는 <전부가능성설>이 있다.

2. 판례

① 대법원은 일관되게 부담만이 항고소송의 대상이 될 수 있다고 보며, 기타 부관은 독립하여 항고소송의 대상이 될 수 없다는 입장이다. ② 따라서 부담이 아닌 부관만의 취소를 구

하는 소송이 제기된 경우에 법원은 각하판결을 하여야 한다고 본다.

3. 검토

① 본안의 문제인 독립취소가능성과 소송요건의 문제인 독립쟁송가능성은 구분하는 것이 타당하고, 위법한 행정작용의 통제를 위해 가능한 쟁송가능성을 넓히는 것이 타당하므로 <전 불가능성설>이 타당하다. ② 부관의 주된 행정행위로부터의 분리가능성은 독립취소가능성의 문제로 보아야 한다.

4. 사안의 해결

사안의 원상복구 조건은 甲에게 작위의무를 부과하므로 취소를 구할 실익이 있어 이를 독립하여 취소소송으로 다룰 수 있다. 나아가 판례에 따르더라도 부담에 해당하므로 독립쟁송의 대상이 된다.

IV. 독립취소 가능성

1. 학설

① 기속행위는 부관의 취소가 가능하고, 재량행위는 부관만의 취소는 인정되지 않는다고 한다(재량·기속행위 구별설). ② 부관이 주된 행정행위의 중요하고 본질적 요소라면 부관만의 취소는 인정되지 않고 부관부행정행위 전체를 취소해야 한다고 한다. 이때 부관이 본질적인 부분인지 여부는 행정청이 부관이 없이는 당해 행정행위를 하지 않았을 것이라고 해석되는지를 행정청의 객관적인 의사를 기준으로 판단해야 한다(중요성 기준설). ③ 취소소송의 소송물이 부관 자체의 위법성이므로 부관이 위법하면 부관만을 취소할 수 있다고 한다(부관의 위법성 기준설).

2. 판례

판례는 부담의 독립취소가능성은 인정하고 있으나, 부진정일부취소소송을 인정하지 않으므로 부담 이외 부관은 부정하는 입장이다.

3. 검토

부관이 본질적임에도 부관만의 취소를 인정하는 것은 행정청의 의사에 반하여 부관없는 행정행위를 강요하는 것이 되므로, 국민의 권익구제와 행정목적의 실현을 적절히 조절하는 중요성 기준설이 타당하다.

4. 사안의 해결

하천을 점용하여 임시창고를 설치하는 행위는 하천의 공익적 기능을 저해할 우려가 있으므로, 관할청은 원상복구를 전제로 허가한 것으로 이해된다. 따라서 원상복구 조건은 허가의 본질적 요소로서 그 조건만을 취소하는 판결을 할 수 없다.

(물음2) (10점)**I. 논점의 정리**

손실보상의 요건을 바탕으로 甲이 창고건물 철거에 따른 손실보상을 청구할 수 있는지 검토한다.

II. 손실보상의 요건

① 공공필요 ② 공권력에 의한 적법한 침해 ③ 재산권에 대한 침해 ④ 특별한 희생 ⑤ 보상규정의 존재가 요구된다.

사안에서 하천의 원상회복은 공공필요에 따른 관할청의 적법한 공권력 행사이고, 그에 따라 창고건물을 철거해야 하므로 甲의 재산권 침해가 인정된다. 다만, 이러한 침해가 특별한 희생인지가 문제된다.

III. 특별한 희생**1. 의의**

특별한 희생이란 타인과 비교하여 불균형하게 가해진 권익의 박탈로서, 사회적 제약을 넘는 손실을 말한다.

2. 판단기준

① 통설은 형식적 기준설과 실질적 기준설을 종합하여 특별한 희생과 사회적 제약을 구별하여야 한다고 본다. ② 형식적 기준설에 따라 재산권의 침해가 특정 범위의 사람에 대하여 가해진 것인지 여부와 실질적 기준설에 따라 침해의 본질성 및 강도를 고려하여 특별한 희생인지 여부를 판단해야 한다.

3. 관련 판례

하천부지 점용허가를 하면서 '점용기간 만료 또는 점용을 폐지하였을 때에는 즉시 원상복구할 것'이라는 부관을 붙인 사안에서 위 부관의 의미는 하천부지에 대한 점용기간 만료 시 그에 관한 개간비보상청구권을 포기하는 것을 조건으로 한 것으로 본다(2007두25930).

4. 사안의 경우

관할청은 허가기간 만료 시 창고건물을 철거하여 원상회복할 것을 조건으로 점용허가를 하였다. 이에 따라 甲은 설치 당시부터 원상회복 의무를 수인하고 점용한 것으로 볼 수 있으므로 철거로 인한 손해가 수인한도를 넘는다고 볼 수 없다. 따라서 특별한 희생에 해당하지 않는다.

IV. 甲의 손실보상 청구 가능성

甲의 손실은 특별한 희생이 아니므로 창고건물 철거에 따른 손실보상을 청구할 수 없다.

[문제3] (20점)**I. 논점의 정리**

집행정지는 행정소송법 제23조 제1항의 집행부정지 원칙에 대한 예외이므로, 집행정지의 요건을 바탕으로 甲의 집행정지 신청이 인용될 수 있는지 검토한다.

II. 집행정지**1. 집행부정지 원칙과 집행정지(행정소송법 제23조)**

① 행정소송법 제23조 제1항은 집행부정지를 원칙으로 규정하고 있다. ② 다만, 소송이 길어지면 승소판결이 있다고 하더라도 당사자에게 회복되기 어려운 손해가 발생하는 등 실익이 없는 경우가 있을 수 있다. ③ 따라서 동조 제2항에서는 예외 규정으로 일정한 요건 하에서 처분의 효력 등을 정지시키는 집행정지를 인정하고 있다.

2. 요건**1) 적극적 요건****(1) 적법한 본안소송의 계속**

① 민사집행법상의 가구제와는 다르게 행정소송법상 집행정지를 신청하기 위해서는 적법한 본안소송이 계속 중일 것을 요한다. ② 따라서 본안소송이 취하되면 집행정지결정의 효력도 소멸한다.

(2) 처분 등의 존재

① 집행정지의 대상이 되는 처분 등이 존재하여야 한다. ② 따라서 부작위에 대해서는 집행정지가 허용되지 않고, 처분의 효력이 발생하기 전이나 처분의 효력이 소멸된 후에도 집행정지가 허용되지 않는다. ③ 거부처분에 대해서 집행정지가 허용되는지 견해의 대립이 있는데, 통설과 판례는 집행정지의 대상이 되지 않는다고 본다.

(3) 회복하기 어려운 손해 발생의 우려

회복하기 어려운 손해란 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 금전보상이 불능인 경우뿐만 아니라 금전보상으로는 사회관념상 당사자가 참고 견딜 수 없거나 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유·무형의 손해를 말한다.

(4) 긴급한 필요

① 긴급한 필요란 본안판결을 기다릴 여유가 없는 것을 의미한다. ② 판례는 긴급한 필요가 있는지 여부는 처분의 성질, 양태와 내용, 처분상대방이 입는 손해의 성질·내용과 정도, 원상회복·금전배상의 방법과 난이도 등은 물론 본안청구의 승소가능성 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다고 본다.

2) 소극적 요건**(1) 공공복리에 중대한 영향을 줄 우려가 없을 것**

행정소송법 제23조 제3항에 따라 집행정지는 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다.

(2) 본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것

- ① 행정소송법상 명문 규정은 없으나, <본안청구가 이유 없음이 명백하지 아니할 것>이 집행정지의 소극적 요건인지에 대해 견해 대립이 있다.
- ② 본안에서 승소가능성이 전혀 없음에도 집행정지를 인정하는 것은 집행정지제도의 취지에 반하며, 집행정지신청의 남용을 방지할 필요도 있으므로 본 요건이 요구된다고 보는 것이 일반적 견해이다.

Ⅲ. 甲의 집행정지 신청 인용 여부**1. 적극적 요건 검토**

- ① 적법한 본안소송인 취소소송이 계속 중이며, ② 감정평가법인의 설립인가를 취소하는 침익적 처분이 존재한다. ③ 인가취소로 감정평가법인의 이미지 및 신용이 훼손되어 중대한 경영상의 위기를 맞을 수 있으므로, 회복하기 어려운 손해 발생의 우려가 있다. ④ 이러한 손해를 예방하기 위해 본안판결을 기다릴 여유가 없으므로 긴급한 필요가 인정된다.

2. 소극적 요건 검토

- ① 인가취소의 집행정지로 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 보기 어렵다. ② 또한 감정평가법 제32조 제1항 제13호에 따른 인가취소는 기속행위가 아니라 재량행위이므로 재량권의 일탈·남용이 문제될 여지가 있다. 따라서 본안청구가 이유 없음이 명백하다고 보기 어렵다.

3. 결론

적극적, 소극적 요건을 모두 충족하므로 甲의 집행정지 신청은 인용될 것이다.

2기 2주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (20점)****I. 논점의 정리**

감정평가 실무기준의 법적 성질을 바탕으로 이에 반하는 보상액 결정이 위법한지 甲의 주장의 타당성을 검토한다.

II. 법령보충적 행정규칙**1. 의의 및 근거**

- ① 법령보충적 행정규칙이란 법률의 위임에 의해 법령을 보충하는 법규사항을 정하는 행정규칙을 말한다.
- ② 행정기본법 2조 1호 가목 3)은 법률 등의 위임을 받아 중앙행정기관의 장이 정한 고시 등을 법령으로 정의하고 있다.

2. 법적 성질**1) 학설**

- ① 법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 보는 견해이다.
- ② 행정규칙설은 법규명령 형식은 대통령령·총리령·부령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 보는 견해로서 형식을 중시한다.
- ③ 수권여부기준설은 상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 본다.
- ④ 규범구체화 행정규칙설은 대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 보는 견해이다.

2) 판례

- ① 행정규칙의 형식으로 제정된 것이라도 상위법령의 위임이 있고, 위임의 한계를 벗어나지 않으며, 상위법령의 내용을 보충하는 기능을 가지는 경우에는 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령이라고 보았다.
- ② 다만, 법률의 위임을 받은 것이기는 하나 행정적 편의를 도모하기 위한 절차적 규정은 법령보충적 행정규칙이 아니라 단순한 행정규칙이라고 보았다.

3) 검토

- ① 상위법령의 위임이 있는 경우에는 그와 결합하여 법령을 보충하므로 법규성을 인정하는 것이 행정현실상 타당하다고 판단된다.
- ② 다만, 일반적인 법규명령 제정절차를 거치지 않기 때문에 국민의 예측가능성을 고려하여 고도의 전문적 영역에 한정되어 최소한도로 인정해야 할 것이다.

III. 감정평가 실무기준의 법적 성질**1. 관련 판례**

감정평가에 관한 규칙에 따른 감정평가 실무기준은 감정평가의 구체적 기준을 정함으로써 감정평가업자가 감정평가를 수행할 때 이 기준을 준수하도록 권장하여 감정평가의 공정성과

신뢰성을 제고하는 것을 목적으로 하는 것이고 일반 국민이나 법원을 기속하지 않는다고 판시했다(2013두4620).

2. 소결

판례는 감정평가 실무기준이 대외적 구속력을 가지지 않는다고 본다. 다만, 감정평가 실무기준은 형식상 국토교통부 고시이나, 감정평가법 제3조 제3항, 감정평가에 관한 규칙 제28조의 상위법령의 위임에 근거한다. 또한 감정평가시 지켜야 할 세부 기준을 정한 것으로 위임의 한계를 벗어나지 않고 상위법령의 내용을 보충하는 기능을 하므로 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 가진다.

IV. 甲 주장의 타당성

1. 관련 규정 검토

감정평가 실무기준은 취득하는 토지의 보상평가에서, 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역별 지가변동률을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 다만 비교표준지와 같은 용도지역의 지가변동률이 조사·발표되지 않은 경우에는 공법상 제한이 유사한 용도지역의 지가변동률 또는 이용상황별 지가변동률을 적용할 수 있다고 규정한다.

2. 甲 주장의 타당성

‘해당 토지의 이용상황이 지가변동률에 더 큰 영향을 미친다’는 사정은 감정평가 실무기준이 정한 이용상황별 지가변동률을 적용할 수 있는 경우에 해당하지 않는다. 따라서 이용상황별 지가변동률을 적용한 보상액 결정은 대외적 구속력을 가지는 감정평가 실무기준에 위반되므로, 법률우위의 원칙에 반하여 위법하고, 甲의 주장은 타당하다.

(물음2) (20점)

I. 甲이 제기하는 소송

- ① 수용재결은 행정소송법 제2조 제1항 제1호의 처분에 해당하므로 항고소송의 대상이 된다.
- ② 토지보상법 제85조 제1항은 제34조에 따른 재결에 불복하는 경우 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하며, 동조 제2항은 그 행정소송이 보상금의 증감에 관한 소송인 경우 보상금증감청구소송을 제기해야 한다고 규정한다.
- ③ 甲은 보상금의 증액을 구하므로 보상금증액청구소송을 제기해야 한다.

II. 보상금증감청구소송

1. 의의 및 취지(토지보상법 제85조 제2항)

보상금증감청구소송이란 수용재결 중 보상금에 대하여서만 이의가 있는 경우에 보상금의 증액 또는 감액을 구하는 소송을 말한다. 이는 분쟁을 일회적으로 해결하고, 권리구제의 신속성·실효성 확보를 도모함에 취지가 있다.

2. 소송의 성질

1) 형식적 당사자소송

보상금증감청구소송은 기본적으로 보상금액을 다투는 소송이며 소송을 제기함에 있어 재결

청을 피고로 하는 것이 아니라 그 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하는 소송에 해당하게 되므로 형식적 당사자소송이라 할 것이다.

2) 소송의 법적 성질

(1) 학설

- ① 형성소송설은 보상금증감청구소송은 실질적으로는 보상액의 취소·변경을 구하는 항고소송으로서, 법원이 재결을 취소하고 정당한 보상액을 판단함으로써 비로소 구체적 손실보상 청구권이 형성된다고 한다.
- ② 확인·급부소송설 보상청구권은 헌법조항에 근거하여 당연히 발생하므로, 법원은 정당보상액을 직접 확인·급부하는 것에 대한 판단이면 충분하다 보는 견해이다.

(2) 검토

보상당사자 사이에서 보상금의 증감에 관한 분쟁을 종국적으로 해결하도록 한 입법취지를 고려하고, 분쟁을 일회적으로 해결하도록 한 취지 등을 고려할 때, <확인·급부소송>으로 봄이 바람직하다.

3) 소송의 대상

보상금증감청구소송은 관할 토지수용위원회가 행한 재결로 형성된 법률관계인 보상금의 증감에 관한 것을 소송의 대상으로 삼아야 하며 보상금의 증감에 관한 사항 외에는 소송의 대상이 될 수 없다.

4) 소제기의 요건

- ① 관할 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자 또는 관계인이 소송을 제기하는 경우에는 사업시행자를 피고로, 사업시행자가 소송을 제기하는 경우에는 토지소유자 또는 관계인을 피고로 하여,
- ② 재결서를 받은 날로부터 90일 이내에, 이의신청을 거친 경우에는 이의재결서를 받은 날로부터 60일 이내에 피고의 소재지를 관할하는 행정법원 또는 토지 소재지 관할 행정법원에 소송을 제기할 수 있다.

5) 심리

- ① 보상금증감청구소송의 범위에 잔여지수용청구에 관한 것까지 포함할 것인가에 관하여 견해의 대립이 있다.
- ② 판례는 잔여지 수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 보상금증감청구소송이라고 하여 긍정하고 있다.

6) 보상항목간의 유용

판례는 행정소송의 대상이 된 물건 중 일부 항목에 관한 보상액이 과소하고 다른 항목의 보상액은 과다한 경우에는 그 항목 상호간의 유용을 허용하여 과다 부분과 과소 부분을 합산하여 보상금의 합계액을 결정하여야 한다고 하여 긍정하고 있다.

7) 입증책임

판례는 보상금증감청구소송에 있어서 재결에서 정한 보상금액보다 정당한 손실보상액이 많다는 점에 대한 입증책임은 원고에게 있다고 본다.

[문제2] (30점)

(물음1) (20점)

I. 논점의 정리

전소의 주문에 포함된 기판력 있는 법률관계가 후소의 선결문제가 되는 경우에는 전소 판결의 기판력이 후소에 미칠 수 있다. 이에 따라 취소소송의 기각판결이 확정된 후 제기된 국가배상청구소송에 취소소송의 기판력이 미치는지 검토한다.

II. 취소소송의 기판력

1. 의의 및 취지

- ① 기판력이란 소송물에 관하여 판결이 확정되면 이후 동일한 사항이 문제되는 경우에 당사자(승계인 포함)는 그에 반하는 주장을 할 수 없고, 법원도 이에 모순*저촉되는 판단을 할 수 없는 판결의 구속력을 말한다.
- ② 기판력은 소송절차의 반복과 모순된 재판의 방지라는 법적 안정성의 요청에 따라 일반적으로 인정되고 있는 판결의 효력이다.

2. 근거 및 적용 판결

- ① [행정소송법]은 기판력에 관한 명문의 규정을 두고 있지 않지만, [행정소송법] 제8조 제2항에 의하여 [민사소송법]의 관련 규정이 준용된다.
- ② 인용, 기각판결 모두 기판력이 발생한다.

3. 효력 범위

1) 주관적 범위

- ① 기판력은 당해 소송의 당사자 및 당사자와 동일시할 수 있는 승계인, 소송에 참가한 제3자에게 미친다.
- ② 그러나 당해 소송과 관계없는 제3자에게는 미치지 않는다.

2) 객관적 범위

- ① 기판력은 판결의 주문에 표시된 <소송물>에 관한 판단에만 미치고, 판결이유에서 제시된 구체적인 위법사유에 관한 판단에는 미치지 않는다.
- ② 취소소송의 소송물을 통설 및 판례와 같이 <위법성 일반>으로 보게 되면, 취소소송의 기판력은 인용판결의 경우에는 당해 처분이 위법하다는 점에, 기각판결의 경우에는 당해 처분이 적법하다는 점에 미친다.
- ③ 다만, 사정판결은 기각판결의 일종이지만, 처분의 위법성을 주문에 명시하므로 당해 처분이 위법하다는 점에 기판력이 생긴다.

3) 시간적 범위

- ① 기판력은 사실심 변론종결 시를 기준으로 발생한다.

② 따라서 사실심 변론종결시까지 제출할 수 있었던 공격방어 방법은 후소에서 제출불가하나, 변론종결 후 새로운 사유가 발생한 경우에는 기판력이 미치지 않는다.

Ⅲ. 취소소송의 기판력이 국가배상청구에 미치는지 여부

1. 학설

- ① 기판력 부정설은 양 소송의 위법성은 서로 다른 개념이므로 취소소송의 판결의 기판력은 국가배상청구소송에 영향을 미치지 않는다는 견해이다(결과불법설, 상대적위법성설).
- ② 기판력 긍정설은 양 소송의 위법성은 동일하므로 취소소송의 판결의 기판력은 국가배상청구소송에 영향을 미친다고 보는 견해이다(협의의 행위위법설).
- ③ 제한적 긍정설은 국가배상청구소송의 위법개념을 취소소송의 위법개념보다 넓은 개념으로 보면서, 인용판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치지만, 기각판결의 기판력은 미치지 않는다고 본다(광의의 행위위법설).

2. 판례

- ① 취소소송의 확정판결의 기판력이 국가배상청구소송에 미치는지 여부와 관련하여 판례의 입장은 분명하지 않다.
- ② 다만, 대법원은 처분등이 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의해 당해 처분 등이 곧바로 불법행위를 구성하는 것이 아니라고 본다.

3. 검토

국가배상청구소송의 목적은 위법한 공무원의 행위로 인한 국민의 손해를 금전적으로 배상하는데 있으므로 국가배상청구소송에서의 위법성을 취소소송보다 넓게 보는 제한적 긍정설이 타당하다.

Ⅳ. 사안의 적용

국가배상청구소송에서의 위법성 개념이 더 광의이므로, 업무정지처분취소소송 기각판결의 기판력은 국가배상청구소송에 미치지 않는다.

(물음2) (10점)

Ⅰ. 논점의 정리

거부처분이 사전통지 대상인지 여부를 바탕으로 갱신등록 거부처분의 위법성 여부를 검토한다.

Ⅱ. 사전통지

1. 의의 및 취지(행정절차법 21조)

- ① 사전통지란 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에 사전에 통지하는 것을 말한다.
- ② 사전통지는 의견진술의 전치절차로서, 당사자에게 불이익처분을 하기 전에 의견제출의 기회를 주려는 데 의의가 있다.

2. 거부처분이 사전통지 대상인지 여부

1) 문제점

사전통지의 적용 범위와 관련하여 수익적 행정처분의 신청을 거부하는 것이 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분인지가 문제 된다.

2) 학설

- ① 수익적 행정처분의 신청만으로는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부여되지 않았으므로, 그 거부하는 권익을 제한하는 처분이 아니므로 사전통지가 불필요하다고 보는 <부정설>,
- ② 신청을 한 당사자는 긍정적인 처분을 기대하므로 그 거부하는 기대이익을 제한하는 처분에 해당하여 사전통지가 필요하다고 보는 <긍정설>,
- ③ 원칙적으로는 부정하나, 인허가에 부가된 갱신기간의 경우는 신청인의 권익이 보호될 필요가 있는 것으로 보아 <제한적 긍정설>이 있다.

3) 판례

판례는 신청에 따른 처분이 이루어지지 않은 경우에는 아직 당사자에게 아무런 권익이 부과되어 있지 않으므로 그 거부가 권익을 제한하는 처분에 해당하지 않고 이에 사전통지의 대상이 되지 않는다고 하여 <부정설>의 입장을 취한다.

4) 검토

- ① 원칙적으로 신청의 거부는 권익제한이 아니라고 판단된다.
- ② 다만, 인허가 갱신의 경우는 갱신에 의해 종전의 허가효과가 유지되는 바, 갱신신청의 거부는 권익 제한에 해당한다고 볼 수 있으므로 <제한적 긍정설>이 타당하다고 본다.

5) 사안의 해결

갱신등록에 대한 거부처분이 있으면 업무를 계속할 수 없게 되므로, 갱신신청의 거부는 감정평가사의 권익제한에 해당한다고 볼 수 있다. 따라서 사전통지의 대상이 된다.

Ⅲ. 사전통지 결여의 위법성 여부

- ① 갱신등록 거부는 사전통지 대상임에도 불구하고 절차가 누락되었으므로 절차상 하자가 존재한다. ② 절차상 하자는 독자적인 위법사유가 될 수 있다는 견해와 판례에 따르면 갱신등록거부처분은 위법하며, ③ 사전통지 결여는 내용상 중대하나 외견상 명백하지 않아 취소사유에 해당한다.

[문제3] (30점)**I. 논점의 정리**

무효확인소송에서 확인의 이익이 필요한지 등 소송요건을 살펴본 뒤, 청문 결여로 인한 절차상 하자가 독자적 위법사유가 되는지와 위법성의 정도, 그리고 취소사유에 대해 무효확인소송을 제기한 경우 법원이 어떤 판결을 해야하는지를 바탕으로 인용가능성을 검토한다.

II. 무효등확인소송**1. 의의 및 성질**

- ① 무효등확인소송이란 행정청의 처분 등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송을 말한다(행정소송법 제4조 제2호).
- ② 무효등확인소송은 주관적 소송으로서 당해 처분등이 처음부터 무효임을 확인 선언하는 확인소송의 성질을 가진다.

2. 확인의 이익이 필요한지 여부**1) 문제점**

- ① 무효등확인소송도 소의 이익이 요구된다. 이와 관련하여 민사소송에서의 확인의 이익(확인소송의 보충성)이 요구되는지 문제된다.
- ② 즉, 무효등확인소송보다 실효적인 권리구제수단이 가능한 경우에도 무효등확인소송이 허용되는지 견해의 대립이 있다.

2) 학설

- ① 무효등확인소송에서 취소판결의 기속력(행정소송법 제30조) 규정을 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있어 확인소송의 보충성은 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>과
- ② 무효등확인소송은 확인소송의 성질을 가지고 있으므로 확인소송의 보충성이 필요하다고 보는 <보충성 필요설>이 대립한다.

3) 판례

종래에는 무효등확인소송에서 확인의 소의 보충성이 필요하다고 보았으나, 최근에는
 (ㄱ) 행정소송은 민사소송과 목적, 취지, 기능 등을 달리하고,
 (ㄴ) 확정판결의 기속력에 의해 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있으며,
 (ㄷ) 외국과 달리 우리 행정소송법은 보충성을 규정하고 있지 않는다고 하여 불요설로 변경하였다.

4) 검토

- ① 무효등확인소송은 행정소송법 제30조를 준용하므로 무효확인판결의 기속력에 따라 무효판결만으로도 판결의 실효성을 확보할 수 있다.
- ② 따라서 확인소송의 보충성이 요구되지 않는다고 보는 <보충성 불요설>이 타당하다.

Ⅲ. 소송요건 검토

- ① 설립인가취소는 행정청인 국토교통부장관이 행하는 감정평가법 제25조 성실의무 위반이라는 사실에 관한 감정평가법 제32조 집행행위로서 우월한 지위에서 행하는 공권력 행사에 해당하며 법적 행위이므로 행정쟁송법상 처분에 해당하므로 대상적격이 인정된다.
- ② 甲은 처분의 직접 상대방이므로 원고적격이 인정된다.
- ③ 확인소송의 보충성은 요구되지 않으며, 甲은 무효확인판결을 받을 실익이 있으므로 협의의 소익이 인정된다.
- ④ 무효확인소송은 제소기간이 제한이 없으므로 소송요건은 모두 갖추었다.

Ⅳ. 본안요건 검토

1. 설립인가취소처분의 절차상 하자 유무

1) 청문

(1) 의의

청문이란 행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자등의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차를 말한다(행정절차법 제2조 5호).

(2) 청문 요건(행정절차법 제22조)

- ① 다른 법률등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우, ② 행정청이 필요하다고 인정하는 경우, ③ 인허가 등의 취소, 신분·자격의 박탈, 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소의 처분을 하는 경우 행정청은 청문을 해야 한다.

(3) 예외 사유

- ① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우, ② 법령등에서 요구된 자격이 없거나 없어지게 되면 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우에 그 자격이 없거나 없어지게 된 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 경우, ③ 해당 처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될 만한 상당한 이유가 있는 경우, ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 청문을 하지 않을 수 있다.

(4) 관련 규정

감정평가법 제45조는 국토교통부장관이 동법 제32조 제1항에 따른 감정평가법인 설립인가취소처분을 하려는 경우에는 청문을 실시해야 한다고 규정한다.

(5) 사안의 경우

감정평가법 제45조에서 청문을 하도록 규정하고 있고, 사안에 예외사유에 해당하는 사정이 보이지 않으므로 청문을 실시해야 한다. 따라서 청문을 실시하지 않은 설립인가취소처분에는 절차상 하자가 존재하며, 이러한 절차상 하자가 독자적 위법사유가 되는지 문제된다.

2. 절차상 하자의 독자적 위법 사유 여부

- ① 절차상의 하자가 독자적인 위법사유인지에 대해 긍정설, 부정설, 절충설(기속행위와 재량

행위를 구분하는 학설)이 대립한다.

② 판례는 재량행위, 기속행위를 구별하지 않고 절차상 하자는 독자적인 위법사유가 될 수 있다고 본다.

③ 생각건대, 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 긍정설이 타당하다.

3. 청문 결여의 위법성의 정도

청문절차를 결여한 설립인가취소처분은 절차상 하자로 인하여 위법한 처분이 된다. 청문절차의 결여는 내용상 중대하나 외견상 명백하지 않아 취소사유에 해당한다. 다만, 감정평가법 제45조의 규정을 위반한 것이므로 하자가 외견상 명백하다고 보면 무효사유에 해당한다고도 볼 수 있다. 따라서 소송의 인용가능성은 위법성의 정도에 따라 각각 검토한다.

V. 하자가 취소사유인 경우 인용가능성

1. 취소사유에 대해 무효확인소송을 제기한 경우

1) 취소소송의 제기요건 갖추지 못한 경우

법원은 기각판결을 해야 한다.

2) 취소소송의 제기요건을 갖춘 경우

① 법원이 어떠한 판결을 내려야 하는지에 대해 청구기각판결설, 소변경필요설, 취소판결설이 대립된다.

② 판례는 일반적으로 행정처분의 무효확인을 구하는 소에는 원고가 그 처분의 취소를 구하지 아니한다고 밝히지 아니한 이상 그 처분이 만약 당연무효가 아니라면 그 취소를 구하는 취지도 포함되어 있는 것으로 보아야 한다고 하여 <취소판결설>의 입장을 취한다.

③ 처분이 무효라는 주장에는 취소를 구하는 뜻도 포함되어 있다고 볼 수 있으므로 판례와 같이 처분을 취소하는 판결을 할 수 있다고 보는 <취소판결설>이 타당하다.

2. 사안의 해결

설립인가취소처분은 취소사유에 해당하며, 무효확인소송을 제기한 2025년 8월 1일은 처분을 통보받은 날부터 90일이 도과한 시점이므로, 행정소송법 제20조에 따른 제소기간 요건을 갖추지 못했다. 따라서 甲의 무효확인소송은 인용될 수 없고 기각판결을 받을 것이다.

VI. 하자가 무효사유인 경우 인용가능성

청문절차 결여의 하자가 내용상 중대하고 외견상 명백한 경우에는 무효사유에 해당하므로 인용판결을 받을 것이다.

2기 3주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (30점)****I. 논점의 정리**

토지보상법상 주거이전비 지급청구권의 법적성질을 검토하고, 동법 시행규칙 제54조 제2항의 요건을 갖추었음에도 주거이전비를 포기하는 각서를 쓴 경우 그 각서의 효력을 살펴 乙의 주거이전비 청구 인용여부를 논한다.

II. 주거이전비**1. 의의 및 취지**

주거이전비는 공익사업지구에 편입되는 주거용 건축물에 실제 거주하고 있는 소유자 및 세입자에 대하여 가구원수에 따라 지급하는 보상이다. 판례는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적인 목적과 주거이전으로 인해 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원의 생활보상의 성격도 가진다고 본다.

2. 근거 (토지보상법 제78조 제6항)

토지보상법 제78조 제6항은 주거용 건물의 거주자에 대해 주거이전에 필요한 비용 등을 보상할 것을 규정하고 있고, 동법 시행규칙 제54조에서는 소유자와 세입자의 주거이전비의 구체적 보상 기준을 규정하고 있다.

3. 주거이전비 지급청구권의 법적성질**1) 학설**

주거이전비 지급청구권에 대하여는 ② 대등한 당사자 사이의 금전청구에 관한 법률관계로 <사권>이라고 보는 견해, ② 공익사업이라는 공법상 원인행위로 발생한 <공권>이라고 보는 견해가 대립한다.

2) 판례

주거이전비는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적 목적과 주거이전으로 인하여 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적 차원에서 지급되는 공법상 권리이므로, 주거이전비 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 당사자소송에 의하여야 한다고 판시했다.

3) 검토

주거이전비는 공익사업으로 인해 이주하게 되는 거주자를 위한 보상으로서 그 원인과 취지를 고려할 때 판례와 같이 <공법상 권리>로 보는 것이 타당하다.

4. 주거이전비 포기각서의 효력 (2011두3685)

판례는 토지보상법 시행규칙에서 정하고 있는 세입자에 대한 주거이전비는 공익사업 시행으로 인하여 생활 근거를 상실하게 되는 세입자를 위하여 사회보장적 차원에서 지급하는 금원으로 보아야 하므로, 사업시행자의 세입자에 대한 주거이전비 지급의무를 정하고 있는 토지보상법 시행규칙 제54조 제2항은 당사자 합의 또는 사업시행자 재량에 의하여 적용을 배제할 수 없는 강행규정이라고 판시했다. 따라서 사안의 주거이전비 포기각서는 강행규정 위반

으로 <무효>이며 당사자에게 구속력이 발생하지 않는다.

5. 계속거주 요건 여부

소유자와 달리(소유자는 계속거주요건 요함), 세입자는 사업인정고시일 등 당시 공익사업지구 안에서 3월 이상 거주한 자에 해당하면 그 이후 사업시행자의 주거이전비 산정통보일 또는 수용개시일까지 계속 거주할 것을 요함이 없이 사업인정고시일 등에 바로 주거이전비와 이사비 청구권을 취득한다(대법원 2011두23603). 따라서 계속거주요건은 필요하지 않다.

Ⅲ. 乙의 주거이전비 청구 인용 여부

乙은 토지보상법 시행규칙 54조 2항의 요건을 갖추었고, 포기각서는 그 효력이 없으며, 세입자는 계속거주요건이 필요 없으므로, 乙은 주거이전비 대상자이며, 乙의 청구는 인용될 것이다.

다만, 사업시행자가 그 청구를 거부할 경우 乙은 공법상 당사자소송을 제기할 수 있으며, 재결을 거친 경우라면, 토지보상법 제85조 제2항에 따른 보상금증액청구소송을 제기할 수 있다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

토지보상법 제79조의 간접손실보상 요건 및 동법 시행규칙 제64조를 바탕으로 丙이 보상을 받을 수 있는지 검토한다.

Ⅱ. 간접손실보상의 요건충족여부

1. 의의

간접손실은 공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실을 말한다.

2. 요건

1) 손실보상의 일반적 요건

이와 더불어 헌법 제23조 제3항의 손실보상의 일반적 요건, 즉 공공필요에 의한 적법한 공권력 행사로 인한 재산권에 침해로 특별한 희생이 발생하고, 보상규정이 존재해야 하는 요건이 요구된다.

2) 간접손실보상의 요건

① 공익사업의 시행에 수반된 사업지구 밖의 제3자가 입은 손실이 존재할 것, ② 공익사업의 시행으로 그러한 손실이 발생하리라는 것을 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있을 것이 요구된다.

3. 사안의 경우

공공필요에 의해 적법한 공권력 행사로 공익사업이 이루어졌고, 해당 공익사업으로 인해 사업시행지구 밖에서 영업하던 丙의 음식점은 주출입로가 단절되어 휴업이 불가피하게 되므로 특별한 희생에 해당하며, 손실이 발생하리라는 것을 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도

구체적으로 특정할 수 있다.

Ⅲ. 토지보상법상 요건충족여부

1. 동법 시행규칙 제64조

토지보상법 시행규칙 제64조는 지구 밖의 영업손실보상을 규정하고 있다. 요건으로는 ① 배후지의 2/3 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우 또는 ②진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업을 하는 것이 불가피한 경우에 사업지구에 편입된 것으로 보아 동 시행규칙 제45조를 적용하여 영업손실을 보상해야 한다고 규정한다.

2. 사안의 경우

丙은 이 사건 공익사업으로 인하여 주출입로가 단절되어 휴업을 하는 것이 불가피한 경우이므로 위 요건을 충족한다.

Ⅳ. 丙이 보상받을 수 있는지 여부

丙에게 간접손실이 발생하였으며, 공익사업으로 인해 음식점의 주출입로가 단절되었으므로 토지보상법 시행규칙 제64조 제1항 제2호에 따라 丙은 보상을 받을 수 있다.

【문제 2】 30점**(물음1) (15점)****I. 논점의 정리**

토지보상법 제73조를 바탕으로 잔여지 가격감소에 대한 甲의 권리구제방법을 검토한다.

II. 잔여지 손실보상**1. 의의 및 취지(토지보상법 제73조)**

잔여지 손실보상이란 일정한 요건하에서 잔여지의 가치가 하락하거나, 공사가 필요한 때 그 비용을 보상하는 것을 말하며 정당보상 실현에 취지가 있다.

2. 요건**1) 규정 검토**

사업시행자는 동일한 소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등 신설 등 그 밖의 공사가 필요할 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다. 다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다(제73조 제1항).

2) 일단의 토지의 의미

‘일단의 토지’란 연속된 토지로서 그 전체가 어떤 단일의 목적에 공용되고 있는 것으로 전체로서 경제상의 이용가치를 지니는 것을 말하며, 반드시 공부상의 한 필지임을 요하지 않는다. 다만, 일단의 토지는 동일한 소유자에게 속하는 것이어야 한다.

3. 보상청구 기간 (토지보상법 제73조 제2항)

잔여지의 손실 또는 비용의 보상은 사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제73조 제2항).

4. 손실보상 청구 절차 (토지보상법 제9조 제6항 및 제7항 준용)

토지보상법 제73조 제4항에서 잔여지 손실보상 등은 토지보상법 제9조 제6항 및 제7항을 준용한다고 규정하고 있다. 따라서 손실의 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의(제6조)하고, 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자나 손실을 입은 자는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다(제7조).

5. 소송제기 전 재결이 선행되어야 하는지 여부(재결전치주의)

판례는 토지보상법이 협의, 재결, 쟁송의 절차를 규정한 내용 및 입법 취지 등을 종합하여 보면, 토지소유자가 사업시행자로부터 공익사업법 제73조에 따른 잔여지 가격감소 등으로 인한 손실보상을 받기 위해서는 토지보상법 제34조, 제50조 등에 규정된 재결절차를 거친 다음 그 재결에 대하여 불복이 있는 때에 비로소 공익사업법 제83조 내지 제85조에 따라 권리구제를 받을 수 있을 뿐, 이러한 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다고 봄이 상당하다고 판시했다(2006두19495).

Ⅲ. 甲의 권리구제방법

甲은 잔여지 가격감소에 따른 손실보상금을 한국수자원공사와 협의하여 결정할 수 있다. 만약, 협의 불성립 시 곧바로 소송을 제기할 수 없으며, 재결절차를 거친 후 재결에 대해 불복하는 때에 동법 제83조에 따른 이의신청, 동법 제85조에 따른 보상금증감청구소송을 통해 권리구제를 받을 수 있다.

(물음2) (15점)**I. 논점의 정리**

토지보상법 제74조 및 시행령 제39조의 잔여지수용청구 요건과 甲이 제기할 수 있는 행정소송의 형식을 검토한다.

Ⅱ. 잔여지수용청구**1. 의의, 취지(토지보상법 제74조)**

잔여지수용청구란 일정한 요건하에 토지소유자가 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구하는 것을 말한다. 확장수용의 일환으로 피수용자의 권리구제 확대 및 원활한 사업수행에 그 취지가 인정된다.

2. 요건**1) 토지보상법 제74조**

① 동일한 소유자에 속하는 ② 일단의 토지의 일부로서 ③ 매수 또는 수용됨으로 인하여 ④ 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 ⑤ 현저히 곤란한 경우이어야 한다. 또한 ⑤잔여지수용청구는 매수에 관한 협의가 불성립된 경우에만 가능하고 ⑥ 사업완료일까지 하여야 한다.

2) 토지보상법 시행령 제39조

① 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우 ② 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우 ③ 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우 ④ 위와 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 중 하나에 해당하여야 한다.

3) 관련 판례

'종래의 목적'이라 함은 수용재결 당시에 당해 잔여지가 현실적으로 사용되고 있는 구체적인 용도를 의미하고, '사용하는 것이 현저히 곤란한 때'라고 함은 물리적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우는 물론 사회적, 경제적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우, 즉 절대적으로 이용 불가능한 경우만이 아니라 이용은 가능하나 많은 비용이 소요되는 경우를 포함한다고 판시한 바 있다.

3. 사안의 경우

甲은 편입토지와 잔여지의 소유자가 동일하고, 1필지 토지의 일부가 매수되어 남은 부분이 잔여지에 해당한다. 또한 종래 호텔부지로 이용하려던 목적대로 사용하기 어렵게 되었으므로

로 잔여지수용청구의 요건을 충족한다.

Ⅲ. 甲이 제기할 수 있는 소송의 형식

1. 잔여지수용청구권의 법적성질 (형성권)

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 그 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하는 형성권에 해당한다.

2. 잔여지수용 거부에 대한 보상금증감청구소송 가능성

1) 학설

① 보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있으므로 보상금증감청구소송에서 심리할 수 있다고 보는 <긍정설>과 ② 확장수용에 대한 다툼은 보상금액의 문제가 아니라 보상의 범위에 관련된 문제이므로, 취소소송이나 무효등확인소송을 제기해야 한다는 <부정설>이 있다.

2) 판례

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 수용의 효과가 발생하는 형성권적 성질을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 “보상금의 증감에 관한 소송”에 해당하여 사업시행자를 피고로 하여야 한다고 판시했다.

3) 검토

보상금증감청구소송의 제도 취지가 분쟁의 일회적 해결로서 피수용자의 권리구제를 위한 것이므로, 보상금증감청구소송에서 목적물 범위까지 심리하여 다룰 수 있도록 함이 타당하다.

3. 결론

甲은 잔여지수용청구 요건을 구비하였고, 협의를 거쳐 수용을 청구하였으므로 그 청구에 의해 수용의 효과가 발생 되었다. 따라서 잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 재결에 대해서 甲은 사업시행자를 상대로 토지보상법 제85조 제2항의 보상금증감청구소송을 제기하여야 한다.

【문제 3】 20점**I. 논점의 정리**

법관 K의 경매절차 진행행위로 甲에게 발생한 손해가 국가배상책임의 요건을 충족하는지를 바탕으로 국가배상청구의 인용가능성을 검토한다.

II. 국가배상책임**1. 의의**

국가배상이란 공무원의 고의·과실로 인한 위법한 직무행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 국가 또는 지방자치단체 등이 배상을 해주는 제도를 말한다.

2. 법적 성질

- ① 국가배상청구권의 법적 성질에 대해 국가배상책임은 일반불법행위 책임의 한 유형에 불과한 것으로서, 국가배상법을 민법의 특별법으로 보는 <사권설>과 국가배상책임은 공법적 원인에 의해 발생한 것이므로 공권으로 보는 <공권설>이 대립한다.
- ② 판례는 국가배상법을 민법의 특별법, 국가배상청구권을 사권으로 보고 민사소송으로 다룬다.
- ③ 생각건대, 국가배상책임은 공법적 원인에 의하여 발생한 손해에 대한 전보이므로 국가배상법을 공법으로 보고, 국가배상청구권의 법적 성질은 공권으로 보는 것이 타당하다.

3. 요건**1) 공무원****(1) 개념**

국가배상법 제2조의 공무원은 행정부, 입법부, 사법부 소속의 공무원 및 지방자치단체의 공무원을 포함하며, 실질적으로 공무를 수행하는 기능적 의미의 공무원을 말한다.

(2) 사안의 경우

법관 K는 사법부 소속의 공무원으로서 국가배상법 제2조의 공무원에 해당한다.

2) 직무행위를 집행하면서**(1) 개념**

- ① 판례는 국가배상청구의 요건인 공무원의 직무에는 권력적 작용만이 아니라 비권력적 작용도 포함되며 단지 행정주체가 사경제주체로서 하는 활동만 제외된다고 하여 광의설의 입장을 취한다. ② 직무를 <집행하면서>는 단순한 직무 집행행위뿐만 아니라 널리 외형상 직무집행과 관련 있는 행위를 포함한다고 보는 것이 통설·판례의 태도이다(외형설).

(2) 사법작용(재판행위)의 국가배상청구 가능성

- ① 기판력을 침해하는 것은 아니라는 <긍정설>, 판결의 위법성을 인정해야 하므로 기판력을 침해하는 것이라는 <부정설>, 재판행위의 특수성을 고려하는 <제한적 긍정설>이 있다
- ② 판례는 법관의 재판행위에 국가배상책임이 인정되려면 당해 법관이 위법 또는 부당한 목적을 가지고 재판을 하였다거나 법관이 그에게 부여된 권한의 취지에 명백히 어긋나게 이를 행사하였다고 인정할 만한 특별한 사정이 있어야 한다고 하여 제한적으로 인정하고 있다.

③ 생각건대, 법관도 공무원이고 재판행위도 직무에 포함되므로 <공정설>에 따라 위법한 재판행위에 대해 국가배상청구가 가능하다고 보는 것이 타당하다. 다만, 과실과 위법의 인정을 엄격히 하여 재판의 독립성이 침해되지 않도록 해야 할 것이다.

(3) 사안의 경우

법관 K가 경매절차를 진행한 행위는 경매담당 법관으로서 행한 직무집행행위에 해당한다. 다만, 사법작용에 해당하므로 재판의 독립성을 고려해 과실과 위법의 인정은 엄격하게 판단해야 한다.

4) 고의 또는 과실

(1) 개념

고의란 위법행위의 발생 가능성을 인식하고도 그 결과를 용인하는 것을 말하고, 과실이란 통상적으로 갖추어야 할 주의의무를 해태하여 위법한 결과의 가능성을 인식하지 못하는 것을 말한다.

(2) 사안의 경우

甲의 이의제기에 대해 통상적인 주의를 기울였다면 실제 대상토지의 가치보다 지나치게 낮은 감정평가액을 확인할 수 있었을 것이므로, 법관 K는 주의의무를 해태한 과실이 인정된다.

5) 법령 위반

(1) 개념

a. 학설

① 취소소송상의 위법과 동일하게 보는 <협의의 행위위법설>, ② 취소소송상의 위법보다 넓게 보아 인권존중·공서양속·신의성실원칙 위반 등도 포함된다고 보는 <광의의 행위위법설>, ③ 피침해이익의 성격과 침해 정도, 가해행위의 태양 등을 종합적으로 고려해 객관적 정당성을 상실했는지로 판단하는 <상대적 위법성설>, ④ 수인의 한도를 넘었는지를 기준으로 판단하는 <결과불법설>이 있다.

b. 판례

① 판례는 공무원의 직무집행이 법령이 정한 요건과 절차에 따라 이루어진 것이라면 특별한 사정이 없는 한 법령에 적합한 것이고, 그 과정에서 개인의 권리가 침해된다고 하여 법령적합성이 곧바로 부정되는 것은 아니라고 하여 결과불법설은 배척하고 행위위법성설에 입각한 판시도 한 바 있으며, ② 최근 피침해이익의 종류 및 성질, 침해행위의 태양 및 원인, 손해의 정도 등 제반사정을 종합하여 객관적 정당성을 상실하였는지 여부를 기준으로 판단하여 상대적 위법성설을 따르는 듯한 판례도 있어, 판례의 입장은 명확하지 않다.

c. 소결

① 국가배상법이 법치주의의 요청에 따라 법규범을 위반한 직무행위에 의하여 발생한 손해에 대한 국가 등의 배상책임임을 인정하기 위하여 제정되었음을 볼 때, 기본적으로 행위위법설이 타당하다. ② 손해전보를 목적으로 하는 국가배상에서 반드시 항고소송의 위법과 동

일하게 볼 필요는 없으며, 인권보장의 측면에서 볼 때, 공무원에게 직무상의 일반적 손해방지 의무를 인정하는 것이 타당하므로 행위위법설 중에서도 광의의 행위위법설이 타당하다.

(2) 사안의 경우

실제 대상토지의 가치보다 지나치게 낮은 감정평가액을 최저입찰가격으로 결정한 것은 경매 담당 법관으로서 지켜야 할 신의성실원칙에 반하는 등 객관적 정당성을 상실한 것으로 판단된다. 따라서 광의의 행위위법설에 따라 법령 위반 요건이 충족된다.

6) 손해 및 인과관계

(1) 개념

- ① 손해는 가해행위로 인해 발생한 일체의 손해로서 법률상 이익의 침해를 말하며, 반사적 이익의 침해는 해당되지 않는다.
- ② 손해는 적극적·소극적 손해를 불문하고, 생명·신체·정신상의 손해도 포함된다.
- ③ 상당인과관계의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 직무상 의무를 부과하는 법령을 비롯한 행동규범의 목적, 가해행위의 양태와 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

(2) 사안의 경우

실제 대상토지의 가치보다 지나치게 낮은 감정평가액을 최저입찰가격으로 결정한 것으로 인해 낮게 낙찰되어 소유자인 甲에게 재산상 손해가 발생했으므로 인과관계가 인정된다.

Ⅲ. 인용가능성 여부

국가배상책임의 요건을 모두 충족하므로 甲의 국가배상청구는 인용될 것이다. 다만, 사법작용에 해당하므로 판례가 요구하는 특별한 사정에 해당되지 않는다면 기각될 것이다.

【문제 4】 10점**I. 사업인정(토지보상법 제20조)**

사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다(제2조 제7호). 사업인정은 사업시행자에게 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로, 일정한 내용의 수용권을 설정해 주는 형성적 처분이며, 재량행위, 제3자효 행정행위이다.

II. 사업인정고시(동법 제22조)**1. 의의 및 법적 성질**

사업인정고시란 국토교통부장관이 사업인정을 하였을 때 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하는 것을 말한다. 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생하므로 사업인정고시는 사업인정의 효력발생요건이다.

2. 효과**1) 토지수용권의 발생**

사업인정이 고시됨으로써 사업시행자는 자기가 시행하는 공익사업을 위하여 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 목적물을 수용할 수 있는 권한이 부여된다.

2) 수용목적물의 확정

토지세목고시에 의해 수용 또는 사용할 토지의 범위가 특정된다.

3) 관계인의 범위 제한

① 사업인정의 고시가 된 후에 권리를 취득한 자는 기존의 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 않는다. ② 관계인을 사업인정 시로 한정하는 것은 공용수용의 절차에 참여하는 자를 제한하여 그 절차의 이행을 간소하고 명확하게 함에 목적이 있다.

4) 토지 등의 보전의무

① 사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다.(법 제25조) ② 토지 등의 보전의무는 토지소유자 및 관계인에 한정되지 않고 누구에게나 부과된다.

5) 토지·물건조사권의 발생

① 사업인정고시 후 사업시행자가 사업의 준비나 토지물건조서를 작성하기 위해 필요한 경우 또는 감정평가법인등이 감정평가를 위하여 필요한 경우에는, 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다.(법 제27조 제1항) ② 이 경우 출입의 통지(제10조 제3항), 토지점유자의 인용의무(제11조) 및 증표 등의 휴대(제13조) 규정을 준용한다(제27조 제2항).

III. 사업인정의 실효(동법 제23조)

사업시행자가 사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 재결신청을 하지 않은 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

2기 4주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (15점)****I. 논점의 정리**

- ① 취소소송은 관할권 있는 법원에(행정소송법 제9조) 원고적격(제12조 제1문), 협의의 소의 (제12조 제2문), 피고적격(제13조), 대상적격(제19조), 제소기간(제20조) 등의 요건을 갖추어 제기해야 한다.
- ② 사안에서는 나머지 요건은 특별히 문제되지 않으므로, 대상적격과 제소기간을 중점적으로 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적 성질

- ① 개별공시지가란 시군구청장이 표준지공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다(부동산공시법 제10조 제1항).
- ② 개별공시지가 정정이란 시장 등이 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 명백한 오류가 있음을 발견한 때에 지체 없이 이를 정정하는 것을 말한다(동법 제12조).
- ③ 최초 개별공시지가 결정과 정정은 모두 과세의 기준이 되는 등 국민의 권리, 의무에 직접적인 영향을 미치므로 항고소송의 대상인 처분에 해당한다.
- ④ 다만, 원처분과 정정처분 중 무엇이 소의 대상인지가 문제된다.

III. 대상적격 검토**1. 판례****1) 적극적(실질적) 변경처분**

- ① 후속처분이 종전처분의 주요 부분을 실질적으로 변경하는 경우, 종전처분은 그때부터 효력을 상실하므로 후속처분만이 항고소송의 대상이 된다.
- ② 이 경우 변경취소소송의 제소기간의 준수여부는 변경처분시를 기준으로 한다.

2) 소극적(일부) 변경처분

후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고, 추가·철회·변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다.

2. 관련 판례

대법원은 경정결정되어 공시된 이상 당초에 결정·공시된 개별공시지가는 그 효력을 상실하고 경정결정된 새로운 공시지가가 공시기준일에 소급하여 그 효력을 발생한다고 한다.

3. 사안의 경우

사안의 개별공시지가의 정정은 당초 개별공시지가에 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 명백한 오류가 있음을 이유로 하는 변경처분으로서, 종전 처분의 효력을 부인하고 처분의 실질적인 주요 부분을 변경하는 것으로 봄이 타당하다. 따라서 사안에서 甲이 정정된 공시지가를 대상으로 취소소송을 제기한 것은 대상적격을 충족한다.

IV. 제소기간 검토

행정소송법 제20조에 따라 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 제기해야 한다. 사안에서 정정된 공시지가는 2018.9.7. 甲에게 개별 통지되었으므로, 甲은 이날 정정처분이 있었음을 알게 되었다. 그리고 2018.10.22.은 처분을 안 날부터 90일이 경과하지 않았으므로, 甲의 소제기는 제소기간을 충족한다.

V. 결론

甲이 제기한 취소소송은 대상적격, 제소기간 등 소송요건을 충족하므로 甲의 소제기는 적법한다.

(물음2) (10점)**I. 논점의 정리**

개별공시지가에 대한 이의신청과 정정의 관계를 바탕으로, 이의신청기간이 도과한 후 이루어진 정정처분이 위법한지 검토한다.

II. 개별공시지가에 대한 이의신청

- ① 이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 공시일부 30일 이내에 시장·군수·구청장에게 이의를 신청하는 것을 말한다(부동산공시법 제11조).
- ② 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.
- ③ 부동산공시법상 이의신청은 준사법적 절차로 하는 어떠한 규정도 두고 있지 않으므로 부동산공시법상 이의신청은 행정심판이 아니며 강학상 이의신청으로 봄이 타당하다.

III. 이의신청과 정정의 관계

부동산공시법 제12조는 시장 등이 개별공시지가에 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정해야 한다고 규정하면서, 정정에 관해 기간을 제한하거나 이의신청을 거쳐야 한다고 하지 않는다.

IV. 甲 주장의 타당성

부동산공시법 제11조의 이의신청은 강학상 이의신청에 해당하므로 진정의 성격을 가지는 희망의 진술에 불과하다. 또한 동법 제12조에 따르면 이의신청 기간 도과와 무관하게 시장 등은 정정사유인 토지가격비준표 적용의 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정해야 하므로 개별공시지가 정정은 위법하지 않으며, 甲 주장은 타당하지 않다.

(물음3) (15점)**I. 논점의 정리**

행정행위 하자의 치유를 바탕으로, 개별공시지가 정정처분으로 부담금 부과처분의 하자가 치유되는지 검토한다.

II. 하자의 치유**1. 의의 및 취지**

- ① 하자의 치유란 성립당시에 하자가 있는 행정행위가 사후에 하자의 원인이 되는 법률요건을 충족하였거나 또는 그 하자가 취소사유가 되지 않을 정도로 경미해진 경우에 그의 성립 당시의 하자에도 불구하고 하자 없는 적법한 것으로 다루는 것을 말한다.
- ② 하자의 치유는 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 인정될 수 있다.

2. 인정 여부**1) 학설**

- ① 행정의 능률성 측면에서 하자의 치유를 인정하는 <긍정설>,
- ② 행정결정의 신중성 확보 측면에서 부정하는 <부정설>,
- ③ 국민의 방어권 보장을 침해하지 않는 범위 내에서 제한적으로 허용해야 한다고 보는 <제한적 긍정설>이 있다.

2) 판례

판례는 원칙적으로 하자 치유는 허용될 수 없으나, 예외적으로 국민의 권리나 이익을 침해하지 않는 범위 내에서 구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정해야 한다고 판시한 바 있다.

3) 검토

하자 치유는 하자의 종류에 따라서, 하자의 치유를 인정함으로써 달성되는 이익과 그로 인하여 발생하는 불이익을 비교衡量하여 개별적으로 결정하여야 한다(제한적 긍정설).

3. 적용 범위 및 사유

- ① 통설·판례는 무효인 행정행위는 치유될 수 없고, 내용상 하자 역시 법률적합성 원칙상 치유를 인정하지 않는다는 입장이다.
- ② 하자치유가 인정되려면 흠결된 요건이 사후에 보완되는 등 치유사유가 있어야 한다.

4. 한계**1) 실체적 한계**

행정행위의 하자의 치유는 국민의 권리와 이익을 침해하지 않는 범위 내에서만 허용된다.

2) 시간적 한계

- ① 쟁송제기이전시절, 소송제기이전시절, 쟁송종결이전시절이 대립된다.
- ② 판례는 치유를 허용하려면 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간 내에 해야 한다고 하여 쟁송제기이전시절을 취한다.

③ 행정의 효율성과 공정한 행정 및 사전적 권리구제 기능 등을 종합 고려하여 쟁송제기 전까지 가능하다고 보는 <쟁송제기이전시설>이 타당하다.

5. 효과

하자의 치유는 소급효가 있다. 즉, 행정행위의 하자가 치유되면 당해 행정행위는 치유시가 아니라 처음부터 하자가 없는 적법한 행정행위로서 그 효력이 발생한다.

Ⅲ. 부담금 부과 하자 치유 가능성

1. 관련 판례

선행처분인 개별공시지가결정이 위법하여 그에 기초한 개발부담금 부과처분도 위법하게 된 경우 그 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 그 후 적법한 절차를 거쳐 공시된 개별공시지가결정이 종전의 위법한 공시지가결정과 그 내용이 동일하다는 사정만으로는 위법한 개별공시지가결정에 기초한 개발부담금 부과처분이 적법하게 된다고 볼 수 없다.

2. 결론

정정한 개별공시지가가 당초 공시지가와 동일하게 산정되었더라도, 부담금 부과처분의 하자는 위법한 개별공시지가에 기초한 내용상 하자에 해당므로 법률적합성 원칙상 치유될 수 없다. 또한 하자치유를 인정하면 납부의무자에게 가산금 부담 등 불이익이 발생할 수 있어 실체적 한계를 벗어나게 되므로 하자는 치유되지 않는다.

【문제 2】 30점**(물음1) (15점)****I. 논점의 정리**

행정소송법 제12조의 원고적격을 바탕으로 P토지의 소유자가 아닌 甲에게 P토지의 표준지 공시지가 결정에 대한 취소를 구할 법률상 이익이 있는지 여부를 검토한다.

II. 표준지공시지가의 개관

- ① 표준지공시지가란 국토교통부장관이 토지이용상황, 주변환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지의 매년 공시기준일 현재 단위 면적당 적정가격을 말한다(부동산공시법 제3조 제1항).
- ② 이는 적정가격을 공시하여 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하는데 취지가 있다.
- ③ 법적 성질에 관해 견해 대립이 있으나, 다수설 및 판례는 표준지공시지가 결정은 손실보상액 산정의 기준이 되는 등 국민의 권리·의무에 영향을 미치므로 항고소송의 대상인 처분으로 본다.

III. 원고적격**1. 의의**

원고적격이란 원고로서 소송을 수행하여 본안판결을 받을 수 있는 자격을 말한다. 행정소송법 제12조는 취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다고 규정한다.

2. 법률상 이익의 의미**1. 학설**

- ① 위법한 처분으로 권리를 침해당한 자만이 원고적격을 갖는다는 <권리구제설>,
- ② 위법한 처분으로 인하여 근거법규 및 관계법규에 의하여 보호되는 이익이 침해된 자에게 당해 처분을 취소할 원고적격이 인정된다고 보는 <법률상 보호이익구제설>,
- ③ 침해된 이익이 법률상 이익이든 사실상 이익이든 실질적으로 재판상 보호할 가치가 있는 이익이 침해된 자는 원고적격이 있다고 보는 <보호가치이익구제설>,
- ④ 처분의 적법성 확보와 가장 밀접한 이익을 가진 자가 원고적격을 가진다고 보는 <적법성 보장설> 등이 있다.

2. 판례

법률상 보호되는 이익이라 함은 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익을 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익과 같이 사실적·경제적 이해관계를 갖는 데 불과한 경우는 여기에 포함되지 않는다고 판시했다.

3. 검토

- ① 권리구제설은 원고적격의 인정 범위가 너무 좁고, ② 보호가치이익구제설은 보호가치 판단기준이 모호하며, ③ 적법성보장설은 취소소송을 객관화하는 문제점이 있다.

3. 법률의 범위

- ① 일반적인 견해는 처분의 근거법규, 관련법규 외에 헌법상 기본권 규정도 보충적으로 고려해야 한다고 본다.
- ② 판례는 헌법상의 기본권은 일반적으로 고려하지 않으나, 대법원은 접견권(91누7552), 헌법재판소는 경쟁의 자유(97마141)를 기본권이지만 법률상 이익으로 인정한 바 있다.
- ③ 생각건대, 국민의 권리구제 가능성을 확대한다는 측면에서 헌법합치적·목적론적 해석을 통해 기본권 규정을 보충적으로 고려하는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

토지보상법 제70조에 따라 표준지공시지가가 손실보상액 산정의 기준이 된다. 사안에서 P토지는 X토지의 보상기준가격에 영향을 미치는 점을 고려할 때, 甲은 표준지의 소유자가 아니더라도 표준지공시지가 결정으로 인해 자신의 재산권(보상금)에 대한 개별·직접·구체적 이익이 침해될 우려가 있으므로 그 취소를 구할 법률상 이익이 인정된다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

甲의 표준지공시지가결정 취소소송에 제3자인 丙의 소송참가 가능성과 인용판결의 효력(형성력)이 乙에게도 미치는지 검토한다.

II. 제3자의 소송참가

1. 의의 및 취지(행정소송법 제16조)

- ① 제3자의 소송참가란 소송의 결과에 의해 권익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 그 제3자를 소송에 참가시키는 제도를 말한다.
- ② 제3자의 권익을 보호하려는데 그 취지가 인정된다.

2. 요건

- ① 타인간의 취소소송 등이 계속 중일 것, ② 소송결과에 따라 법률상 이익의 침해를 받을 제3자일 것이 요구된다. 여기서 <제3자>란 소송당사자 이외의 자를 말하고, <이익의 침해>는 법률상 이익을 말하며, 단순한 사실상의 이익이나 경제상의 이익은 포함되지 않는다.

3. 소송참가인의 지위

참가인에게는 민사소송법 제67조를 준용하므로 참가인의 지위는 공동소송적 보조참가인과 유사한 지위를 가진다는 것이 일반적인 견해이다.

4. 丙의 소송참가 가능성

- ① 甲과 행정청(국토교통부장관) 사이에 취소소송이 계속 중이고, ② 인용판결로 표준지공시지가가 상향 조정되면 해당 표준지의 소유자인 丙은 조세 부담이 증가하는 등 재산권이 침해될 가능성이 있다. 따라서 丙은 취소소송에 참가할 수 있다.

Ⅲ. 인용판결의 효력(형성력)

1. 형성력

- ① 판결의 형성력이란 법원의 판결에 따라 법률관계의 발생·변경·소멸을 가져오는 효력을 말한다.
- ② 처분등에 대한 취소판결이 확정되면 처분청의 별도의 취소를 기다릴 것 없이 처분등이 당연히 <소급적>으로 효력을 상실하게 된다.
- ③ 형성력은 행정처분을 취소하는 인용판결에만 인정되고, 기각판결에는 인정되지 않는다.
- ④ 행정소송법 제29조 제1항의 해석에 의해 인정된다고 보며, 형성력은 제3자에게도 미친다.

2. 인용판결의 효력이 乙에게도 미치는지

인용판결의 형성력은 행정소송법 제29조에 따라 제3자인 乙에게도 미친다. 따라서 인용판결로 P토지의 표준지공시지가가 상향 조정되면, Y·W토지 소유자인 乙의 보상금 산정에서도 이에 따른 공시지가가 적용될 것이다.

【문제 3】 20점**(물음1) (10점)****I. 매도청구와 수용재결의 의의**

- ① 매도청구란 재건축사업의 사업시행자가 도시정비법에서 정한 절차를 거쳐 조합설립 또는 사업시행자 지정에 동의하지 않은자, 분양신청을 하지 않은 자 등을 상대로 건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 청구하는 것을 말한다. 매도청구권은 매매계약을 성립시키는 형성권의 성질을 가진다.
- ② 수용재결이란 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차를 말한다. 수용재결에 따른 보상금을 다투는 쟁송절차에는 이의신청(토지보상법 제83조), 보상금증감청구소송(동법 제85조 제2항)이 있다.

II. 쟁송절차의 차이점**1. 소송형태 및 관할법원**

- ① 매도청구를 둘러싼 법률관계는 사법상의 법률관계로서 그 매도청구권 행사에 따른 소유권이전등기의무의 존부를 다투는 소송인 매도청구소송은 민사소송이다. 따라서 관할 법원은 민사법원이 된다.
- ② 반면, 토지보상법 제85조 제2항에 따라 제기하는 보상금증감청구소송은 공법상 당사자소송이며, 사업시행자와 피수용자가 각각 피고 또는 원고가 되어 보상금을 다투는 소송이므로 형식적 당사자소송에 해당한다. 따라서 행정법원이 관할 법원이 된다.

2. 절차 및 제소기간**1) 매도청구**

- ① 도시정비법 제64조에 따라 사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 30일 이내에 조합설립 또는 사업시행자 지정에 관한 동의 여부를 회답할 것을 촉구하고, 촉구를 받은 토지등소유자는 2개월 이내에 회답해야 한다.
- ② 2개월 이내 회답하지 않은 경우 부동의한 것으로 본다. 2개월의 회답기간이 만료된 때부터 2개월 이내에 부동의자를 상대로 매도를 청구할 수 있다.
- ③ 그리고 도시정비법 제73조에 따라 관리처분계획인가가 고시된 다음 날부터 90일 이내에 분양신청을 하지 않은 자 등과 손실보상에 관한 협의를 해야하고 협의가 성립되지 않으면 협의 기간 만료일 다음 날부터 60일 이내에 매도청구소송을 제기해야 한다.

2) 보상금증감청구소송

보상금증감청구소송은 수용재결 재결서 정본 송달일부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 제기해야 한다.(도시정비법 제65조, 토지보상법 제85조)

3. 당사자

- ① 매도청구소송의 원고는 사업시행자가 되고, 피고는 부동의자, 분양신청을 하지 않은 자 등이 된다. ② 반면, 보상금증액청구소송에서는 원고는 피수용자, 피고는 사업시행자가 되며, 보상금감액청구소송에서는 원고는 사업시행자, 피고는 피수용자가 된다.

(물음2) (10점)**I. 개설**

매도청구에 따른 감정평가는 도시정비법상 사법관계에서 매매대금을 정하기 위한 시가평가이고, 수용재결에 따른 보상평가는 정당보상을 실현하기 위한 감정평가이다. 따라서 평가목적, 적용 법률 등이 달라 감정평가방법과 그 기준에 차이가 발생한다.

II. 감정평가방법과 그 기준의 차이점**1. 감정평가의 기준시점**

- ① 매도청구 소송감정의 기준시점은 형성권인 매도청구의 의사가 상대방에게 도달한 때인 매매계약체결 의제일이다.
- ② 반면, 수용재결의 보상금을 다투는 소송감정의 가격시점은 수용재결일이다(토지보상법 제67조 제1항).

2. 개발이익 반영 여부

- ① 매도청구에 따른 감정평가는 재건축사업이 시행된다는 것을 전제로 하여 시장에서 형성, 반영되고 있는 개발이익을 반영해야 한다. 다만, 기준시점에 현실화, 구체화되지 않은 개발이익이나 조합원의 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제해야 한다.
- ② 반면, 수용재결에 따른 보상평가는 해당 사업으로 인한 개발이익은 반영하지 않는다(토지보상법 제67조 제2항).

3. 사실상 사도의 평가기준

- ① 매도청구권 행사에 따른 평가는 시가평가이며 판례는 '토지의 현황이 도로일지라도 재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 인근 대지 시가와 동일하게 평가하되, 각 토지의 형태, 주요 간선도로와의 접근성, 획지조건 등 개별요인을 고려하여 감액 평가하는 방법으로 산정하는 것이 타당하다'고 판시하고 있다.
- ② 반면, 수용재결에 따른 보상평가는 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제2호에 의거 인근토지에 대한 평가액의 1/3 이내로 평가하여야 한다.

【문제 4】 10점**I. 토지보상법 제26조 협의****1. 의의 및 취지**

협의란 사업시행자가 공익사업에 제공될 토지 등에 관한 권리를 취득하거나 소멸시키기 위해 토지소유자 및 관계인과 교섭하는 절차를 말한다. 이는 수용에 앞서 피수용자의 의견을 존중하고, 원만한 토지취득을 통해 공익사업을 원활하게 수행하려는 데 취지가 있다.

2. 법적 성질

- ① 사법상 계약설은 대등한 지위에서 행하는 합의임을 근거하며, 공법상 계약설은 수용권을 실행하는 방법임을 근거한다.
- ② 판례는 협의취득이 사법상의 법률행위에 해당한다고 하면서도, 그 배후에는 수용에 의한 강제취득이 예정되어 있고 협의 과정에는 여러 가지 공법적 규제가 수반되는 등 공익적 특성을 고려해야 한다고 판시했다.
- ③ 생각건대, 사업인정 후 협의는 사업시행자에게 수용권이 부여된 상태에서 이루어지고 협의가 불성립하면 곧바로 수용재결 절차로 나아갈 수 있으므로 공법상 계약설이 타당하다.

3. 협의가 수용재결 신청 전 필요적 전치절차인지 여부

동법 제28조의 재결신청과 제30조의 재결신청 청구는 협의 불성립을 요건으로 하므로 협의는 필요적 전치절차에 해당한다. 다만, 사업인정 이전에 협의절차를 거쳤으나 협의가 성립되지 아니하여 사업인정을 받은 사업으로서 조서의 내용에 변동이 없는 경우에는 예외적으로 협의를 생략할 수 있고, 이 경우에도 사업시행자 또는 토지소유자 등이 협의를 요구하면 협의를 해야 한다(동법 제26조 제2항).

II. 토지보상법 제29조 협의성립확인**1. 의의 및 취지**

협의성립확인이란 사업인정 후 협의가 성립하면 사업시행자가 피수용자의 동의를 받거나 또는 공증을 받아 관할 토지수용위원회의 확인을 받는 제도를 말한다. 이는 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 원활한 공익사업 진행에 취지가 있다.

2. 법적 성질

특정한 사실관계 또는 법률관계에 대해 의문이 있는 경우 공권적으로 그 존부 또는 정부를 판단하는 행위이므로 기존의 사실 또는 법률관계를 유권적으로 확정하는 준법률행위적 행정행위인 확인행위에 해당한다.

3. 법적 효과

- ① 협의성립에 대한 확인이 있게 되면 재결로 간주되어, 재결과 동일한 효과가 발생한다.
- ② 즉, 사업시행자는 보상금의 지급 또는 공탁을 조건으로 수용목적물을 원시취득하고 피수용자의 의무불이행시 대항·대집행을 신청할 수 있으며 위험부담이 이전된다.
- ③ 피수용자에게는 목적물의 인도·이전의무와 손실보상청구권, 환매권이 발생하게 된다.
- ④ 또한, 협의성립확인이 있으면 사업시행자, 토지소유자 및 관계인은 그 확인된 협의의 성립이나 내용에 대하여 다툴 수 없는 확정력이 발생한다.(동법 제29조 제4항)

- ⑤ 협의성립확인을 받은 후에도 협의에서 정한 보상일까지 보상금을 지급하지 않으면 재결의 실효규정(제42조)이 적용되어서 확인행위의 효력은 상실된다고 보아야 할 것이다.

2기 5주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (15점)****I. 논점의 정리**

甲의 재결신청 청구에 대해 A공사가 재결신청을 하지 않은 것이 부작위에 해당하는지를 바탕으로 甲의 불복 방법을 검토한다.

II. 부작위에 해당하는지 여부**1. 부작위의 의의 및 성립요건**

부작위란 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다(행정소송법 제2조 제2호). 즉, ① 당사자의 신청, ② 상당한 기간 경과, ③ 일정한 처분을 할 법률상 의무, ④ 아무런 처분을 하지 않을 것이 요구된다.

2. 관련 판례

판례는 토지소유자의 재결신청 청구에도 사업시행자가 재결신청을 하지 않을 때 토지소유자는 사업시행자를 상대로 거부처분취소소송 또는 부작위위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다고 판시하였다.

3. 사안의 경우

- ① 피수용자의 재결신청의 청구가 있었다.
- ② 사안에서 구체적으로 주어지지 않았으나, 사업시행자가 재결신청의 청구를 받은 날부터 60일 이내에 재결신청이 없었다면 본 요건은 충족된다.
- ③ 피수용자의 재결신청의 청구가 있으면 사업시행자에게는 재결을 신청해야 할 법률상 의무가 발생한다.(법 제30조 제2항) 판례도 재결신청 청구에 대한 거부는 토지소유자등이 재결 절차를 거치지 못하게 하여 손실보상에 직접적인 영향을 주는 점, 재결신청은 사업시행자에게만 인정되므로 그 거부는 토지소유자등에 대해 우월적 지위에서 하는 권력작용으로 봄이 타당한 점, 토지보상법 제30조 제2항에 따라 사업시행자는 재결신청을 해야 할 의무를 부담하는 점을 고려할 때 처분으로 봄이 타당하다고 판시하였다.
- ④ 사업시행자의 재결신청에 무응답하고 있으므로, 행정소송법상의 부작위로 봄이 타당하다. 따라서 이하 부작위에 대한 불복방법을 검토한다.

III. 甲의 불복방법**1. 의무이행심판(「행정심판법」 제5조 제3호)**

의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 말한다.

2. 부작위위법확인소송 (「행정소송법」 제4조 제3호)

부작위위법확인소송이란 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송을 말한다.

3. 의무이행소송 가능성

의무이행소송이란 행정청의 거부처분 또는 부작위에 대하여 법상의 작위의무의 이행을 청구

하는 소송을 말한다. 인정 여부에 대해 견해가 대립하며, 판례는 의무이행소송은 현행법상 허용되지 않는다고 하여 부정설의 입장이다. 생각건대, 국민의 권익구제를 위해 현행 항고소송만으로는 실효적인 권리구제가 곤란한 경우에 한하여 이를 인정하는 절충설이 타당하다.

4. 결론

A공사의 부작위에 대해서는 의무이행심판 또는 부작위위법확인소송으로 다룰 수 있고, 이를 통해 권리구제가 가능하므로 의무이행소송으로는 불복할 수 없다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

토지에 대한 수용재결이 있는 상황에서 甲이 재결절차를 거치지 않고 곧바로 농업손실보상을 청구할 수 있는지를 검토한다.

II. 농업손실보상의 의의 및 취지(토지보상법 제77조 제2항)

농업손실보상이란 공익사업의 시행으로 인해 영농을 계속할 수 없게 됨에 따라 발생하는 손실을 보상하는 것을 말한다. 이는 상실된 기대이익을 전보하는 취지가 있으며, 생활보상의 성격도 가진다.

III. 재결전치주의

1. 개념

재결전치주의란 행정소송을 제기하기 앞서 토지수용위원회의 재결을 반드시 거쳐야 하는 것을 말한다. 토지보상법 제85조 제1항은 제34조에 따른 재결에 불복할 때 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하여 재결전치주의를 취하고 있다.

2. 관련 판례(2018두57865)

토지보상법 제26조, 제28조, 제30조, 제34조, 제50조, 제61조, 제83조 내지 제85조의 규정 내용 및 입법 취지 등을 종합하면, 토지보상법 제77조 제2항에 따라 농업손실에 대한 보상을 받기 위해서는 토지보상법 제34조, 제50조 등에 규정된 재결절차를 거친 다음 그 재결에 대하여 불복이 있는 때에 비로소 토지보상법 제83조 내지 제85조에 따라 권리구제를 받을 수 있을 뿐, 이러한 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다고 판시했다.

3. 재결절차를 거쳤는지 여부 판단방법

재결절차를 거쳤는지 여부는 보상항목별로 판단하여야 한다. 보상항목이란 피보상자별로 어떤 토지, 물건, 권리 또는 영업이 손실보상대상에 해당하는지, 그 보상금액이 얼마인지를 심사·판단하는 기초 단위를 말한다(2023두49172).

IV. 사안의 해결

토지보상법은 재결전치주의를 취하고 있으며, 토지보상과 농업손실보상은 서로 별개의 보상항목이어서 각각 독립한 재결절차를 거쳐야 한다. 따라서 甲은 농업손실보상에 대한 재결절차를 거치지 않고 곧바로 농업손실보상을 청구할 수 없다.

(물음3) (15점)**I. 논점의 정리**

잔여지수용청구권의 법적 성질과 甲의 잔여지수용청구가 그 요건을 충족하는지 여부를 검토한다.

II. 잔여지수용청구권의 법적 성질**1. 의의(토지보상법 제74조)**

잔여지수용청구권이란 동일한 토지 소유자에게 속하는 수용 목적물인 일단의 토지 일부가 매수 또는 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때, 사업인정 이후 토지소유자가 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있는 권리를 말한다.

2. 법적 성질**1) 학설**

- ① 피수용자와의 합의를 바탕으로 하므로 사법상 매매라는 견해,
- ② 필요 최소한도를 넘는 확장수용이므로 공법상 특별행위라는 견해,
- ③ 피수용자의 청구를 요건으로 하는 사업시행자의 일방적 권리취득행위로서, 그 본질이 일반적인 수용과 다르지 않다고 보아 공용수용으로 보는 견해가 있다.

2) 판례

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 갖춘 때에는 토지수용위원회의 특별한 조치를 기다릴 것 없이 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하므로, 이는 형성권적 성질을 가진다고 판시하여 공용수용설 입장이라고 할 수 있다.

3) 검토

잔여지수용을 청구하면 재결이 없더라도 수용의 효과가 발생하므로 잔여지수용은 공용수용으로 보는 것이 타당하다. 따라서 잔여지수용청구권은 공용수용을 원인으로 하는 공권이며, 요건 충족 시 의사표시에 의해 곧바로 효력이 발생하는 형성권으로 봄이 타당하다.

III. 잔여지수용청구의 인정 가능성**1. 잔여지수용청구 요건****1) 토지보상법 제74조**

- ① 동일한 소유자에 속하는 ② 일단의 토지의 일부로서 ③ 매수 또는 수용됨으로 인하여 ④ 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 ⑤ 현저히 곤란한 경우이어야 한다. 또한 ⑤ 잔여지수용청구는 매수에 관한 협의가 불성립된 경우에만 가능하고 ⑥ 사업완료일까지 하여야 한다.

2) 토지보상법 시행령 제39조

- ① 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우 ② 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우 ③ 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우 ④ 위와 유사한 정도로 잔여지를 종래의

목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 중 하나에 해당하여야 하며(제1항), ⑤ 잔여지의 위치·형상 이용상황 및 용도지역 ⑥ 공익사업 편입토지의 면적 및 잔여지의 면적을 종합적으로 고려해야 한다(제2항).

3) 관련 판례

종래의 목적이란 수용재결 당시에 당해 잔여지가 현실적으로 사용되고 있는 구체적인 용도를 의미하고, 사용하는 것이 현저히 곤란한 때란 물리적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우는 물론 사회적, 경제적으로 사용하는 것이 곤란하게 된 경우, 즉 절대적으로 이용 불가능한 경우만이 아니라 이용은 가능하나 많은 비용이 소요되는 경우를 포함한다고 판시했다.

2. 사안의 해결

① 동일한 소유자인 甲의 토지인 ② ④토지가 수용되고 남은 잔여지에 대하여 매수에 관한 협의가 성립되지 않았으며, ③ 사업완료일 이내에 잔여지수용청구가 있었다. 따라서 ④ 잔여지를 종래의 목적인 농작물직거래판매장으로 사용하는 것이 물리적 또는 사회적·경제적으로 현저히 곤란하다면 甲의 잔여지수용청구는 인정될 수 있다.

【문제 2】 30점**(물음1) (10점)****I. 논점의 정리**

토지보상법 제25조 토지등의 보전의무를 바탕으로 甲의 무허가건축물이 손실보상 대상인지 여부와 그 범위를 검토한다.

II. 토지등의 보전의무

토지보상법 제25조에 따라 사업인정고시 후 고시된 토지에서 건축물의 건축·대수선 등을 하려면 시장 등의 허가를 받아야 한다. 이를 위반한 자는 원상회복의무를 부담하고, 그에 따른 손실보상도 청구할 수 없다.

III. 무허가건축물에 대한 보상**1. 무허가건축물의 의의**

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물이다(토지보상법 시행규칙 제24조).

2. 무허가건축물의 보상여부**1) 문제점**

무허가건축물의 보상여부에 대해서는 명문 규정이 없기 때문에, 손실보상요건 중 허가유무에 따른 재산권 침묵 여부가 문제된다.

2) 학설

- ① 위반건축물에 대한 제재와 손실보상은 별개의 문제이므로 보상대상에 포함된다고 보는 견해,
- ② 사업인정고시로 토지등의 보전의무가 발생하므로 사업인정고시 전 건축한 무허가건축물만 보상대상이 된다는 견해,
- ③ 무허가건축물을 보상한다면 결과적으로 무질서한 건축행위까지 승인하는 결과가 되므로 보상대상이 아니라고 보는 견해가 대립한다.

3) 판례 및 검토

- ① 판례는 사업인정고시일을 기준으로 하는 견해를 취한다.
- ② 생각건대, 허가는 그 성질에 비추어 행위의 적법성 여부에만 관여하고 유효성 여부와는 무관하므로 토지등의 보전의무를 고려하여 사업인정고시일을 기준으로 하여 판단하는 견해가 타당하다.

IV. 사안의 해결

甲은 2005년 5월 무허가건축물을 건축하였고, 이는 사업인정고시일(2015.05.14.) 이전이므로 <기존 부분>은 손실보상 대상에 해당한다. 반면, 사업인정고시일 이후인 2015년 6월 허가 없이 <증축한 부분>은 토지보상법 제25조에 따른 토지 등의 보전의무가 부과된 이후에 이루어진 것이므로 손실보상 대상이 될 수 없다.

(물음2) (20점)**I. 논점의 정리**

토지보상법 시행규칙 제54조의 주거이전비 지급 대상자 요건을 바탕으로, 무허가건축물 소유자인 甲과 보상포기각서를 작성한 세입자 乙이 각각 주거이전비 지급 대상자에 포함되는지 검토한다.

II. 주거이전비 개관**1. 의의 및 취지**

주거이전비는 공익사업지구에 편입되는 주거용 건축물에 실제 거주하고 있는 소유자 및 세입자에 대하여 가구원수에 따라 지급하는 보상이다. 판례는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적인 목적과 주거이전으로 인해 특별한 어려움을 겪게 될 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원의 생활보상의 성격도 가진다고 본다.

2. 근거

토지보상법 제78조 제6항은 주거용 건물의 거주자에 대해 주거이전에 필요한 비용 등을 보상할 것을 규정하고 있고, 동법 시행규칙 제54조에서는 소유자와 세입자의 주거이전비의 구체적 보상 기준을 규정하고 있다.

III. 주거이전비 지급 요건**1. 소유자 요건 (시행규칙 제54조 제1항)**

공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 해당 건축물에 대한 보상을 하는 때에 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 세입자 요건 (시행규칙 제54조 제2항)

공익사업의 시행으로 인하여 이주하게 되는 주거용 건축물의 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 당시 해당 공익사업시행지구 안에서 3개월 이상 거주한 자에 대해서는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상해야 한다. 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있는 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 세입자에 대해서는 본문에 따라 주거이전비를 보상해야 한다.

IV. 甲(소유자)의 경우

甲이 2005년 5월 건축한 부분과 2015년 6월 증축하여 입주한 부분은 모두 무허가건축물에 해당하므로 토지보상법 시행규칙 제54조 제1항 단서에 의거 주거이전비 지급 대상자에 포함되지 않는다.

V. 乙(세입자)의 경우

1. 주거이전비 포기각서의 효력 (2011두3685)

판례는 토지보상법 시행규칙에서 정하고 있는 세입자에 대한 주거이전비는 공익사업 시행으로 인하여 생활 근거를 상실하게 되는 세입자를 위하여 사회보장적 차원에서 지급하는 금원으로 보아야 하므로, 사업시행자의 세입자에 대한 주거이전비 지급의무를 정하고 있는 토지보상법 시행규칙 제54조 제2항은 당사자 합의 또는 사업시행자 재량에 의하여 적용을 배제할 수 없는 강행규정이라고 판시했다. 따라서 사안의 주거이전비 포기각서는 강행규정 위반으로 무효이며 당사자에게 구속력이 발생하지 않는다.

2. 소결

乙이 甲의 무허가건축물 일부를 임의로 용도변경하여 일반음식점으로 사용하고 있더라도, 나머지 부분은 사업인정고시일 당시 공익사업지구 안에서 1년 이상 주거용으로 사용·거주해왔으므로 토지보상법 시행규칙 제54조 제2항 단서에 의거 주거이전비 지급 대상자에 해당한다. 또한 乙이 작성한 보상포기각서는 강행규정에 위반되어 무효이므로 乙을 구속하지 않는다. 따라서 乙은 주거이전비 지급 대상자에 포함된다.

【문제 3】 20점**(물음1) (10점)****I. 논점의 정리**

최초처분(과징금 3천만원)과 경정처분(과징금 2천만원) 중 취소소송의 대상이 무엇인지 검토한다.

II. 감정평가법 제41조의 과징금

① 감정평가법 제41조의 과징금은 감정평가법인등에 대하여 업무정지처분을 한다면 공시업무 등을 정상적으로 수행하는데 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에 업무정지를 갈음하여 부과되는 것으로서 변형된 과징금이다. ② 과징금 부과는 금전급부하명으로서 침익적 처분이며, ③ '~할 수 있다'고 규정하여 재량행위에 해당한다.

III. 경정처분 시 소의 대상**1. 학설**

- ① 당초처분은 경정처분에 흡수되어 소멸하고, 경정처분만이 효력을 가지고 소송의 대상이 된다는 견해(흡수설),
- ② 경정처분은 당초처분에 흡수되어 경정처분에 의하여 수정된 당초처분이 소송의 대상이 된다는 견해(역흡수설),
- ③ 당초처분과 경정처분은 독립된 처분으로 별개의 소송대상이라는 견해(병존설) 등이 있다.

2. 판례**1) 감액경정처분의 경우**

① 감액경정처분은 당초처분의 전부를 취소한 다음 새로이 처분을 한 것이 아니라, 당초처분의 일부취소에 불과하므로, 경정처분에 의하여 감액되고 남아 있는 당초처분이 항고소송의 대상이 된다(역흡수설). ② 이 경우 제소기간의 준수 여부도 당초처분을 기준으로 판단한다.

2) 증액경정처분의 경우

① 당초처분은 증액처분에 흡수되어 소멸되므로 증액경정처분이 항고소송의 대상이 된다(흡수설). ② 이 경우 제소기간의 준수 여부도 증액경정처분을 기준으로 판단한다.

3. 검토

- ① 감액경정처분의 경우에는 경정처분에 의하여 수정된 당초처분을 소의 대상으로 하는 것이 당초처분의 연속성 측면에서 타당하고,
- ② 증액경정처분의 경우에는 국민의 재판청구권을 보장하기 위해 증액경정처분을 소의 대상으로 삼는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

사안의 경정처분은 당사자에게 유리하게 변경된 감액처분으로서 당초 부과된 과징금의 일부를 취소한 것으로 봄이 타당하다. 따라서 감액 후 남은 당초처분(과징금 2천만원)을 소의 대상으로 해야 한다.

(물음2) (10점)**I. 논점의 정리**

- ① 행정소송법 제4조의 제1호에서 취소소송을 <행정청의 위법한 처분 등을 취소 또는 변경하는 소송>이라고 정의하고 있다.
- ② 이에 <변경>의 해석과 관련하여 법원이 과징금부과처분에 대해 일부취소판결을 할 수 있는지 검토한다.

II. 「행정소송법」 제4조 제1호 '변경'의 의미**1. 학설**

- ① 행정소송법 제4조 1호의 변경을 적극적 변경으로 보아 법원이 위법한 처분 등을 취소하고 새로운 처분을 내용으로 하는 판결을 할 수 있다고 보는 <적극적 변경설>과
- ② 행정소송법에서 의무이행소송을 규정하고 있지 않으므로 행정소송법상 변경은 일부취소만을 의미한다고 보는 <소극적 변경설>이 있다.

2. 판례

판례는 <변경>을 소극적 변경, 즉 일부취소를 의미하는 것으로 보아 적극적으로 처분을 변경하는 판결은 인정되지 않는다고 본다.

3. 검토

적극적 변경설은 법원이 행정청의 처분권한을 행사하는 것과 같은 결과를 가져오므로 권력분립의 원칙에 반하여 타당하지 않고, 현행 행정소송법이 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 행정소송법상 <변경>을 소극적 변경으로서 일부취소를 의미한다고 보는 것이 타당하다.

III. 일부취소의 가능여부에 따른 판결**1. 일부취소가 가능한 경우**

- ① 처분의 일부취소가 가능한지 여부는 일부취소의 대상이 되는 부분의 분리가능성에 따라 결정된다.
- ② 외형상 하나의 행정처분에 해당하더라도 가분성이 있거나 그 처분 대상의 일부가 특정될 수 있다면 그 일부만의 취소가 가능하다.

2. 일부취소가 불가능한 경우

- ① 과징금부과처분과 같이 재량행위의 경우에는 처분청의 재량권을 존중하여야 하므로, 법원의 일부취소는 인정되지 않는다.
- ② 따라서 법원은 전부취소를 하여야 하고, 처분청은 재량권을 행사하여 다시 적정한 처분을 해야 한다.

IV. 사안의 해결

과징금 부과처분은 재량행위이므로 처분청의 재량권을 존중해야 하고, 법원이 적정 과징금액을 산정하여 그 초과 부분만을 취소하는 일부취소판결은 허용되지 않는다. 따라서 법원은 3천만 원 과징금 부과처분 전부를 취소하는 판결을 해야 한다.

【문제 4】 10점 _ 2013두21182 판례 문제**I. 논점의 정리**

비축사업으로 甲의 수용대상 토지 보상액을 산정할 때 도로확포장공사로 인한 개발이익을 포함해야 하는지, 甲 주장의 타당성을 검토한다.

II. 개발이익 배제의 의의

- ① 개발이익이란 공익사업 시행 등으로 인해 토지소유자의 노력과 관계없이 지가가 상승되어 현저하게 받은 이익으로서 정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분을 말한다.
- ② 개발이익 배제란 보상금 산정 시 <해당> 공익사업으로 인한 토지 등의 가격 변동을 고려하지 않는 것을 말한다(토지보상법 제67조 제2항).

III. 甲 주장의 타당성**1. 관련 판례**

수용 대상 토지의 보상액을 산정함에 있어 해당 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하는 계획의 승인, 고시로 인한 가격변동은 이를 고려함이 없이 재결 당시의 가격을 기준으로 하여 적정가격을 정하여야 하나, 해당 공익사업과는 관계없는 다른 사업의 시행으로 인한 개발이익은 이를 포함한 가격으로 평가하여야 하고, 개발이익이 해당 공익사업의 사업인정고시일 후에 발생한 경우에도 마찬가지라고 판시했다(2013두21182).

2. 비축사업과 도로확포장공사가 별개의 사업인지

사업의 동일성 여부는 근거 법규, 사업주체, 목적과 내용, 시기 등을 종합해서 판단한다.

비축사업의 사업주체는 한국토지주택공사이며 사업인정 고시일은 2014.03.31.이며 [공공토지의 비축에 관한 법률]에 근거한다.

반면, 도로확포장공사의 사업주체는 관할 도지사이고 도로구역 결정·고시일은 2016.05.01.이다며 [도로법]에 근거한다. 또한 도로확포장공사가 비축사업의 시행을 직접 목적으로 한 것으로 보기 어렵다. 따라서 양 사업은 사업주체, 시기, 목적 등을 달리하므로 <별개의 사업>에 해당한다.

3. 결론

개발이익 배제는 해당 공익사업으로 인한 토지 등의 가격 변동을 고려하지 않는 것이다.

사안의 비축사업과 도로확포장공사는 별개의 공익사업이며, 비축사업 사업인정고시일 이후에 도로확포장공사로 인한 개발이익이 발생하였다면 이를 반영하여 甲 토지의 보상금을 산정해야 한다. 따라서 이를 배제한 토지수용위원회의 보상금 재결은 위법하고, 甲의 주장은 타당하다.

2기 6주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (10점)****I. 사업인정****1. 의의 및 취지(토지보상법 제20조)**

① 사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다 (제2조 제7호).

② 사업인정은 당해 사업이 공공성이 있는가를 개별*구체적으로 판단하여 <피수용자의 권리를 보호>하고, 이에 의해 수용가능여부가 결정되는 수용절차의 제1단계로서 <수용행정의 적정화>, <사전적 권리구제>장치로서의 역할을 한다.

2. 법적 성질**1) 처분성(행정행위)**

① 사업인정이 있으면 사업시행자는 토지수용 등을 위한 절차를 개시할 권리 및 토지 등을 수용하거나 사용할 권리가 창설되고,

② 토지소유자는 사업인정의 고시가 있을 후 고시된 토지 등에 보전의무 및 손실보상청구권이 주어진다.

③ 따라서, 사업인정은 사업시행자와 토지소유자 등에게 일정한 구체적 법적효과가 발생하므로 행정행위이자, 항고소송의 대상인 <처분>이다.

2) 형성행위, 재량행위, 제3자효 행정행위

① 형성행위로 보는 견해, 확인행위로 보는 견해가 대립하나, 판례는 사업인정은 그 후 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 하여 일정한 내용의 수용권을 설정해 주는 <설권적 형성행위>로 보았다.

② 또한 판례는 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하는 것이므로 사업인정의 여부는 행정청의 <재량>에 속한다고 하였다.

③ 사업인정은 사업시행자에게 수용권을 설정하는 수익적 효과를, 피수용자에게는 재산권을 침해하는 침익적 효과를 발생시키는 바 <제3자효 행정행위>이다.

II. 사업인정고시**1. 의의(동법 제22조)**

사업인정고시란 해당 공익사업에 대한 기본내용인 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하는 것을 말한다.

2. 법적 성질

① 사업인정은 고시가 있는 날부터 수용권의 발생, 목적물의 확정, 관계인의 범위 제한, 토지 등의 보전의무, 토지·물건조사권의 발생이라는 효력이 생기므로, 사업인정고시는 사업인정의 <효력발생요건>에 해당한다.

② 또한 사업인정고시는 사업인정처분의 한 구성요건으로서 <절차요건>에 해당한다. 판례도 토지세목고시를 누락한 사업인정은 절차상 위법하여 취소사유가 된다고 판시한 바 있다.

(물음2) (20점)**I. 논점의 정리**

토지보상법이 원처분주의를 채택하는지를 바탕으로 취소소송의 대상적격과 피고적격을 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적 성질**1. 수용재결(토지보상법 제34조)**

- ① 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차이다(제34조, 제50조).
- ② 강제적 권력행사를 통해 공익을 실현하고, 엄격한 절차와 형식을 통해 공익과 사익을 조절하기 위한 제도로써 취지가 있다.
- ③ 수용재결은 일정한 법적 효과를 가져오는 처분으로서 행정행위의 성질을 가지며, 행정심판의 재결과는 구별되는 <원처분>에 해당한다.

2. 이의신청 및 이의재결(토지보상법 제83조, 84조)

이의신청이란 관할토지수용위원회의 위법부당한 재결에 불복이 있는 토지소유자 및 사업시행자가 중앙토지수용위원회에 이의를 신청하는 것으로서 특별법상 행정심판이다. 따라서 이의재결은 행정심판의 결과로서 <재결>에 해당한다.

III. 대상적격 검토**1. 대상적격(취소소송의 대상)**

행정소송법 제19조에 따라 취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.

2. 원처분주의와 재결주의**1) 의의****(1) 원처분주의**

원처분주의란 원처분과 재결 모두 취소소송의 대상이 될 수 있으나, 원처분의 위법은 원처분취소소송에서만 주장할 수 있고, 재결취소소송에서는 원처분의 위법은 주장할 수 없고, 재결 자체의 고유한 위법만을 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

(2) 재결주의

재결주의란 원처분에 대해서는 소송을 제기할 수 없고, 재결에 대해서만 소송을 제기할 수 있도록 하되, 재결 자체의 위법뿐만 아니라 원처분의 위법도 재결취소소송에서 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

2) 재결 자체의 고유한 위법의 의미

원처분에는 없고 재결 자체에만 존재하는 위법을 의미하는 것으로 재결 자체의 주체·내용·절차·형식의 위법이 있는 경우를 말한다.

3. 토지보상법이 원처분주의를 채택하는지 여부

1) 토지보상법의 규정내용

토지보상법은 사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 제34조에 따른 재결에 불복할 때에는 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다(제85조 제1항).

2) 판례

대법원은 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결을 한 중앙토지수용위원회 또는 지방토지수용위원회를 피고로 하여 수용재결의 취소를 구하여야 한다는 원처분주의를 취하고 있다.

3) 검토

- ① 종래 토지수용법은 <이의신청의 재결에 대하여 불복이 있을 때에는>이라는 표현을 사용하여 재결주의를 채택하고 있었다.
- ② 그러나 토지보상법은 이와 같은 문구를 삭제하고, <제34조에 따른 재결에 불복할 때>라고 규정하여, 행정소송법상 원칙대로 원처분주의를 명확히 규정하고 있다.
- ③ 다만, 이의재결 자체의 고유한 위법이 있을 경우에는 중앙토지수용위원회를 상대로 이의재결의 취소를 구할 수 있다.

4. 사안의 경우

甲은 수용 자체의 위법을 주장하고 있을 뿐, 이의재결 자체의 고유한 하자를 주장하는 것으로 보기는 어렵다. 따라서 원처분주의에 따라 <수용재결>을 소의 대상으로 하여 취소소송을 제기해야 한다.

IV. 피고적격 검토

1. 피고적격

피고적격이란 소송이 올바른 피고를 상대로 제기되는 것을 말한다. 「행정소송법」 제13조에 따라 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다.

2. 사안의 경우

수용재결을 대상으로 취소소송을 제기하여야 하므로, 피고는 수용재결을 행한 행정청인 지방토지수용위원회가 된다.

(물음3) (10점)

I. 甲이 불복하는 경우 적합한 소송 형태

1. 관련 규정(토지보상법 제85조)

사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 제34조에 따른 재결에 불복할 때에는 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기할 수 있다.

이때 제기하려는 행정소송이 보상금의 증감에 관한 소송인 경우 그 소송을 제기하는 자가

토지소유자 또는 관계인일 때에는 사업시행자를, 사업시행자일 때에는 토지소유자 또는 관계인을 각각 피고로 한다.

2. 관련 판례

토지보상법상 손실보상대상에 해당함에도 <관할 토지수용위원회가 사실을 오인하거나 법리를 오해함>으로써 손실보상대상에 해당하지 않는다고 잘못된 내용의 재결을 한 경우에는, 피보상자는 관할 토지수용위원회를 상대로 그 재결에 대한 취소소송을 제기할 것이 아니라, 사업시행자를 상대로 제85조 제2항에 따른 보상금증감청구소송을 제기하여야 한다고 판시했다.

3. 소결

甲은 ① 토지보상금의 증액과 ② 일부 지장물이 손실보상대상에 포함되어야 한다는 점을 주장하고 있으므로, 토지보상법 제85조 제2항에 따라 보상금증액청구소송이 적합한 소송형태에 해당한다.

II. 보상금증감청구소송에 대한 설명

1. 의의 및 취지

보상금증감청구소송은 수용재결 중 보상금에 대하여서만 이의가 있는 경우에 보상금의 증액 또는 감액을 청구하는 소송이다. 이는 분쟁을 일회적으로 해결하고, 권리구제의 신속성·실효성 확보를 도모하는데 취지가 있다.

2. 소송의 성질

1) 형식적 당사자소송

보상금증감청구소송은 기본적으로 보상금액을 다투는 소송이며 소송을 제기함에 있어 재결청을 피고로 하는 것이 아니라 그 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하는 소송에 해당하게 되므로 형식적 당사자소송이라 할 것이다.

2) 확인급부소송

형성소송이라는 견해도 있으나, 보상당사자 사이에서 보상금의 증감에 관한 분쟁을 종국적으로 해결하도록 한 입법취지를 고려하고, 분쟁을 일회적으로 해결하도록 한 취지 등을 고려할 때 <확인·급부소송>으로 봄이 타당하다.

【문제 2】 30점**(물음1) (10점)****I. 논점의 정리**

이의신청의 법적성질을 바탕으로 甲이 제기한 취소소송의 제소기간 준수를 검토한다.

II. 개별공시지가의 이의신청**1. 의의 및 취지(부동산공시법 제11조)**

- ① 이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 공시일부터 30일 이내에 시장·군수·구청장에게 이의를 신청하는 것을 말한다.
- ② 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.

2. 법적 성질**1) 강학상 이의신청과 행정심판의 구별기준****(1) 학설**

- ① 심판기관기준설은 행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다.
- ② 불복절차기준설은 준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.

(2) 판례

국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 불복절차기준설을 취하고 있는 것으로 보인다.

(3) 검토

헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

2) 소결

- ① 이의신청은 부동산공시법상 준사법적 절차로 하는 어떠한 규정도 두고 있지 않으므로 강학상 이의신청에 해당한다.
- ② 판례도 부동산공시법에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다.

III. 사안의 해결

사안의 이의신청은 강학상 이의신청이므로 「행정기본법」 제36조 제4항에 따라 이의신청의 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정소송을 제기해야 한다. 따라서 甲이 취소소송을 제기한 날인 2020. 9.10.은 이의신청의 결과를 통지받은 날로부터 90일이 도과하지 않았으므로 甲이 제기한 취소소송은 제소기간을 준수하였다.

(물음2) (20점)**I. 논점의 정리**

개별공시지가 결정의 위법성 여부와 행정행위의 하자의 승계를 바탕으로 甲 주장의 인용 가능성을 검토한다.

II. 개별공시지가 결정의 위법성 여부**1. 개별공시지가의 의의, 취지, 법적 성질**

- ① 개별공시지가란 시군구청장이 표준지공시지가를 기준으로 산정한 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다(부동산공시법 제10조 제1항).
- ② 이는 세금 및 각종 부담금 등의 산정을 위하여 결정·공시된다.
- ③ 개별공시지가 결정은 과세의 기준이 되는 등 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로 항고소송의 대상인 처분에 해당한다.

2. 개별공시지가의 공시절차

- ① 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하고, ② 감정평가법인등의 검증과 토지소유자 등의 의견청취, ③ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 ④ 개별공시지가가 결정·공시된다.

3. 관련 판례

시장 등은 표준지공시지가에 토지가격비준표를 사용하여 산정된 지가와 감정평가업자의 검증의견 및 토지소유자 등의 의견을 종합하여 당해 토지에 대하여 표준지공시지가와 균형을 유지한 개별공시지가를 결정할 수 있고, 그와 같이 결정된 개별공시지가가 표준지공시지와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가 결정이 위법하다고 볼 수는 없다고 판시했다.

4. 소결

부동산공시법상 개별공시지가는 토지가격비준표에 따른 가격배율을 적용하여 지가를 산정한 후, 검증·의견청취 및 심의 절차를 거쳐 최종적으로 결정된다. 따라서 개별공시지가는 토지가격비준표의 가격배율을 적용한 지가와 다르게 결정될 수 있고, 그 결정이 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 사안의 개별공시지가 결정은 위법하지 않다.

III. 하자의 승계**1. 의의**

하자승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 이루어지는 경우에, 선행행위의 하자를 이유로 후행행위를 다룰 수 있는지에 대한 문제를 말한다.

2. 전제조건

- ① 선행행위와 후행행위가 모두 항고소송의 대상이 되는 처분일 것, ② 선행행위는 취소사유가 존재할 것, ③ 후행행위는 적법할 것, ④ 선행행위는 불가쟁력이 발생할 것이 요구된

다.

3. 인정범위

1) 학설

① 선행행위와 후행행위가 결합하여 하나의 법적 효과를 완성하는 경우에는 하자의 승계를 인정하는 하자승계론과 ② 선행행위가 후행행위에 대하여 구속력이 미치는 범위(한계)내에 서는 하자의 승계를 부정하는 구속력론이 대립한다.

2) 판례

① 원칙적으로 하자승계론에 따라 판단하고 있다.
 ② (ㄱ) 대집행절차상 계고·영장에 의한 통지·대집행의 실행·비용징수의 각 행위, (ㄴ) 강제징수절차상 독촉·압류·매각·청산의 각 행위 사이에는 하자승계를 긍정하였다.
 ③ 반면 (ㄱ)표준지공시지가결정과 개별공시지가결정, (ㄴ)표준지공시지가결정과 조세부과처분, (ㄷ)건물철거명령과 대집행 계고, (ㄹ)사업인정과 수용재결 사이, (ㄴ) 재조사청구 조정결정 통지를 받은 개별공시지가결정과 과세처분 사이에는 하자승계를 부정하였다.
 ④ 다만, (ㄱ)개별통지가 없는 개별공시지가결정과 과세처분, (ㄴ)표준지공시지가결정과 재결(보상금증감청구소송)은 별개의 법적효과를 목적으로 함에도 불구하고, 예측가능성이 없고, 수인한도를 넘는 경우에는 하자승계를 긍정한 바 있다.

3) 검토

① 하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정된다.
 ② 따라서 하자승계론을 기준으로 예측가능성이 있는지, 수인한도를 넘는지 등의 사정을 종합 고려하여 하자승계여부를 개별적·구체적으로 판단함에 타당하다.

4. 사안의 경우

1. 전제조건 충족 여부

① 개별공시지가결정과 수용재결은 모두 항고소송의 대상인 처분이고, ② 개별공시지가결정에 대한 제소기간 도과로 선행행위에 불가쟁력이 발생했으며, ③ 특별한 사정이 없는 한 수용재결은 적법하다. ④ 다만, 선행행위인 개별공시지가 결정은 위법하지 않으므로 전제조건이 충족되지 않는다.

2. 인정범위 검토

만약 선행행위인 개별공시지가 결정에 현저한 불합리 등으로 인한 취소사유의 위법이 있다고 하더라도, 개별공시지가 결정과 수용재결은 하나의 법률효과의 완성을 목적으로 하는 관계에 있지 않고, 개별공시지가는 표준지공시지기와 달리 보상금 산정의 기초가 되지 않으므로, 甲의 예측가능성이나 수인가능성을 침해한다고 볼 수도 없다. 따라서 하자의 승계는 인정되지 않는다.

IV. 결론

하자의 승계의 전제조건과 인정범위 모두 충족하지 못하므로, 甲의 주장은 인용될 수 없을

것이다.

【문제 3】 20점

I. 논점의 정리

사업시행지구 밖에서 발생한 간접손실에 대하여 보상규정 흠결시 손실보상가능성을 바탕으로 한국농어촌공사의 주장을 검토한다.

II. 간접손실보상

1. 의의

간접손실보상이란 공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실을 보상하는 것을 말한다.

2. 요건

1) 손실보상의 일반적 요건

헌법 제23조 제3항의 손실보상의 일반적 요건, 즉 공공필요에 의한 적법한 공권력 행사로 인한 재산권에 침해로 특별한 희생이 발생하고, 보상규정이 존재해야 하는 요건이 요구된다.

2) 간접손실보상의 요건

① 공익사업의 시행에 수반된 사업지구 밖의 제3자가 입은 손실이 존재할 것, ② 공익사업의 시행으로 그러한 손실이 발생하리라는 것을 예견할 수 있고, 그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있을 것이 요구된다.

3) 사안의 경우

공공필요에 따라 적법한 공권력 행사로 공유수면매립사업이 시행되었고, 그 결과 조합원들이 조업을 할 수 없게 되어 B위탁판매장을 폐쇄하게 되었으므로, 이는 사회적 제약의 범위를 넘는 특별한 희생에 해당한다. 또한 이와 같은 손실의 발생은 예견 가능하고, 그 범위도 구체적으로 특정할 수 있다. 다만, 토지보상법 제79조 제4항을 일반적인 보상 근거 규정으로 볼 수 있는지가 문제된다.

3. 토지보상법 제79조 제4항을 일반근거조항으로 볼 수 있는지 여부

- ① 토지보상법 제79조 제4항은 법에 규정된 사항 외의 간접손실보상에 관하여는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른다고 규정한다.
- ② 이에 대해 동규정을 간접손실보상에 대한 일반근거조항으로 보는 견해와, 법률에 규정되지 못한 사항에 대한 개괄수권조항으로 보는 견해가 대립한다.
- ③ 생각건대, 동규정은 위임규정인 바 일반근거조항으로 보는 것은 조문을 지나치게 확장 해석하는 것이므로 개괄수권조항설이 타당하다. 따라서 사안은 직접적인 보상 규정이 존재하지 않으므로 보상규정 흠결 시 보상청구가능성을 검토한다.

4. 보상규정 흠결시 보상청구 가능성

1. 학설

- ① 토지보상법 시행규칙 제59조 이하의 간접보상규정을 제한적 열거규정으로 보고, 동 규정에서 규정되지 않은 간접손실은 보상의 대상이 되지 않는다고 보는 <보상부정설>,
- ② 공공사업의 시행결과 발생한 간접손실에 대하여 헌법 제23조 제3항 및 토지보상법상의 간접손실보상에 관한 규정을 유추적용하여 보상을 청구할 수 있다고 보는 <유추적용설>,
- ③ 간접손실도 제23조 제3항의 손실보상의 범위에 포함되므로, 헌법 제23조 제3항에 근거하여 보상청구권이 인정된다고 보는 <헌법 제23조 제3항의 직접적용설>,
- ④ 간접손실도 헌법상 평등원칙 및 재산권 보장규정에 근거하여 보상해 주어야 한다고 보는 <평등원칙 및 재산권보장규정근거설>,
- ⑤ 간접손실에 대하여 명문의 보상규정이 없는 경우에는 손해배상을 청구하여야 한다는 <손해배상설> 등의 견해가 대립한다.

2. 판례

판례는 구 토지수용법하에서 간접손실을 헌법 제23조 제3항에 규정한 손실보상의 대상이 된다고 보고, 공공용지의 취득 및 보상에 관한 특례법 시행규칙상의 각 간접손실보상규정을 유추적용하여 그에 관한 보상을 인정하는 것이 타당하다고 보았다.

또한 공유수면매립사업으로 인하여 수산업협동조합이 관계 법령에 의하여 대상지역에서의 독점적 지위가 부여되어 있던 위탁판매사업을 중단하게 된 경우, 그로 인한 위탁판매수수료 수입 상실에 대하여 공공용지의취득및손실보상에관한특례법시행규칙을 유추적용하여 손실보상을 해야 한다고 판시했다(99다27231)

3. 검토

특별한 희생에 대하여 손실보상을 하는 것은 당연한 바, 간접손실보상도 헌법 제23조 제3항의 손실보상에 포함된다고 보아 헌법 제23조 제3항의 직접효력을 인정하여 직접 헌법 제23조 제3항에 근거하여 손실보상을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

Ⅲ. 한국농어촌공사 주장의 타당성

사안의 경우 보상규정의 존재를 제외한 나머지 간접손실보상 요건은 모두 충족하고, 직접적인 보상규정이 없더라도 헌법 제23조 제3항의 직접효력을 인정하여 손실보상을 청구할 수 있다. 또한 판례에 따르더라도 토지보상법 시행규칙 등 관련 규정을 유추적용하여 간접손실보상을 인정할 수 있다. 따라서 한국농어촌공사의 주장은 타당하지 않다.

【문제 4】 10점**I. 의의(감정평가법 제21조 제1항)**

사무소 개설이란 감정평가법 제17조에 따라 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우 사무소를 개설하는 것을 말한다.

II. 사무소 개설이 금지된 자(동법 제21조 제2항)

① 동법 제18조 제1항 등록거부사유에 해당하는 사람, ② 동법 제32조 제1항(제1·7·15호 제외)에 따라 설립인가가 취소되거나 업무가 정지된 감정평가법인의 설립인가가 취소된 후 1년이 지나지 아니하였거나 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우 그 감정평가법인의 사원 또는 이사였던 사람, ③ 동법 제32조 제1항(제1·7호는 제외)에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 업무정지 기간이 지나지 아니한 사람은 사무소 개설을 할 수 없다.

1호 : 감정평가법인이 설립인가의 취소를 신청한 경우

7호 : 감정평가법인등이 제21조제3항이나 제29조제4항에 따른 감정평가사의 수에 미달한 날부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우

15호 : 제31조제2항에 따라 기간 내에 미달한 금액을 보전하거나 증자하지 아니한 경우

III. 합동사무소의 개설(동법 제21조 제3항)

① 감정평가사는 그 업무를 효율적으로 수행하고 공신력을 높이기 위하여 합동사무소를 설치할 수 있다. ② 이 경우 합동사무소는 2명 이상의 감정평가사를 두어야 한다(동법 시행령 제21조 제2항).

IV. 복수개설 금지(동법 제21조 제4항) 및 소속 감정평가사(동법 제21조 제5항)

① 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
② 감정평가사사무소에는 소속 감정평가사를 둘 수 있다. 이 경우 소속 감정평가사는 동법 제18조 제1항 등록거부사유에 해당하는 사람이 아니어야 하며, 감정평가사사무소를 개설한 감정평가사는 소속 감정평가사가 아닌 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

2기 7주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (15점)****I. 논점의 정리**

환매권의 법적 성질에 따라 환매대금 증액청구소송이 행정소송(공법상 당사자소송)인지 민사소송인지가 달라지므로, 이하 이를 검토한다.

II. 乙의 환매권의 법적 성질**1. 환매권의 의의**

공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우, 원소유자가 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 토지를 다시 취득할 수 있는 권리를 말한다.

2. 법적 성질**1) 공권인지, 사권인지 여부****(1) 문제점**

환매권의 법적 성질에 대하여 사업인정 전 협의취득의 경우는 사법상 권리로 보는 데 문제가 없으나, 사업인정 후 취득의 경우는 공권설과 사권설이 대립되고 있다.

(2) 학설

- ① 공권설은 환매권은 수용 등 공법적 원인에 의해 형성된 법률관계를 전제로 하는 공권이라 본다.
- ② 사권설은 환매권은 원소유자와 그 포괄승계인에게만 한정되고, 환매권자의 이익을 위해 행사하므로 사권으로 본다.

(3) 판례

- ① 대법원의 주류적 입장은 환매권을 사권으로 보며,
- ② 헌법재판소도 환매권은 헌법소원심판의 대상이 되는 공권력의 행사로 볼 수 없다고 하였다.

(4) 검토

환매권은 공권력 행사의 주체인 사업시행자에 대하여 행사하며, 그 구체적 발생요건이 되는 공공필요의 소멸 여부의 판단 역시 공익적 판단에서 비롯하므로 공권으로 봄이 타당하다.

2) 형성권

환매권은 환매기간 내에 환매의 요건이 발생하면 환매권자가 수령한 보상금 상당금액을 사업시행자에게 지급하고 일방적으로 의사표시를 함으로써 사업시행자의 의사에 관계없이 성립되는 <형성권의 일종>으로 보는 것이 타당하다.

3) 물권적 효력, 채권적 효력인지 여부

- ① 물권적 효력설, 채권적 효력설이 대립된다.

② 판례는 환매권 행사는 채권적 효력으로서 소유권이전등기청구권이 발생하며, 10년의 소멸시효에 걸린다고 판시했다.

③ 환매권 행사만으로 소유권이 환매권자에게 이전되는 물권적 효력을 인정한다면 등기 없이 소유권이 변동되는 결과가 초래된다. 따라서 환매권행사에 의하여 소유권이전등기청구권이라는 청구권이 발생하고, 현재 토지소유자의 등기이전이 있어야 소유권이 이전되므로 채권적 효력으로 보는 것이 타당하다.

Ⅲ.乙에 대한 환매대금증액청구소송의 법적 성질

1. 환매대금증액청구소송의 의의(토지보상법 제91조 제4항)

환매대금증액청구소송이란 토지의 가격이 취득일 당시보다 현저히 변동하였음에도 사업시행자와 환매권자 사이에 환매금액에 관한 협의가 성립하지 않은 경우, 그 금액의 증액을 청구하는 소송을 말한다.

2. 법적 성질

앞서 살핀 것과 같이 乙의 환매권은 수용재결에 의한 취득에 기초한 것이므로 그 법적 성질은 공권으로 봄이 타당하다. 따라서 환매대금증액청구소송도 공법상 법률관계에 관한 다툼으로서 행정소송인 공법상 당사자소송에 해당한다. 다만, 판례는 환매권을 사권으로 보고, 환매대금증액청구소송도 민사소송에 해당한다고 본다.

(물음2) (10점)

Ⅰ. 논점의 정리

토지보상법상 환매권에 관한 규정과 관련 판례를 바탕으로, A지방자치단체가 선이행항변 또는 동시이행항변을 주장할 수 있는지를 검토한다.

Ⅱ. 선이행항변 또는 동시이행항변의 주장 가능성

1. 관련 규정

토지보상법 제91조 제1항은 환매기간 내에 환매요건이 발생한 경우 환매권자가 보상금 상당액을 미리 지급하고 환매의 의사표시를 함으로써 그 토지를 환매할 수 있다고 규정하고, 동조 제4항은 토지의 가격이 취득일 당시보다 현저히 변동한 경우 사업시행자와 환매권자가 그 금액에 관하여 협의하되, 협의가 성립되지 않으면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다고 규정한다.

2. 관련 판례

환매권을 행사하기 위하여는 지급받은 보상금의 상당금액을 미리 지급하여야 하고 또한 이로써 족한 것이며, 사업시행자는 소로써 법원에 환매대금의 증액을 청구할 수 있을 뿐 환매권 행사로 인한 소유권이전등기 청구소송에서 환매대금 증액청구권을 내세워 증액된 환매대금과 보상금 상당액의 차액을 지급할 것을 선이행 또는 동시이행의 항변으로 주장할 수는 없다고 판시했다.

3. 결론

환매권은 환매요건이 충족되면 환매권 행사기간 내에 보상금 상당액을 미리 지급하고 환매

의 의사표시를 함으로써 환매가 성립되는 형성권이므로, A지방자치단체는 환매대금의 증액에 관하여 협의하거나, 협의가 성립되지 않으면 법원에 청구할 수 있을 뿐, 소유권이전등기 청구소송에서 그 차액 지급을 선이행항변 또는 동시이행항변으로 주장할 수 없다.

(물음3) (15점)

I. 논점의 정리

소유권이전등기말소청구소송의 수소법원은 민사법원이고, 그 소가 인용되기 위해서는 소유권이전등기의 원인인 수용재결이 무효이어야 한다. 따라서 행정행위인 수용재결에 취소사유에 해당하는 하자가 있는 경우에 민사법원이 그 효력을 부인할 수 있는지, 즉 선결문제에 관한 법리를 바탕으로 乙의 승소 여부를 검토한다

II. 수용재결의 법적 성질(토지보상법 제34조)

- ① 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차이다.
- ② 강제적 권력행사를 통해 공익을 실현하고, 엄격한 절차와 형식을 통해 공익과 사익을 조절하기 위한 제도로써 취지가 있다.
- ③ 수용재결은 일정한 법적 효과를 가져오는 처분으로서 행정행위의 성질을 가진다.

III. 구성요건적 효력과 선결문제

1. 구성요건적 효력의 의의

유효한 행정행위가 존재하는 이상 처분청 이외 다른 국가기관은 그의 존재를 존중하여 스스로의 판단기초 내지는 구성요건으로 삼아야 한다는 구속력을 말한다.

2. 선결문제

1) 의의

선결문제란 항고소송의 수소법원 이외의 민사법원이나 형사법원에서 본안판단의 전제로서 <행정행위의 위법여부나 효력유무에 관한 판단>을 할 수 있는가의 문제를 말하며 행정행위의 효력 중 구성요건적 효력과 관련하여 문제된다.

2) 민사사건의 경우

(1) 행정행위의 무효확인이 선결문제인 경우

- ① 행정행위가 무효인 경우 구성요건적 효력은 인정되지 않는다.
- ② 따라서 누구든지 행정행위의 무효를 주장할 수 있으므로, 어느 법원도 행정행위의 무효를 확인할 수 있다.
- ③ 또한 행정소송법 제11조 제1항도 <처분등의 효력 유무>가 민사소송의 선결문제인 경우 민사법원이 이를 심리·판단할 수 있다고 규정하고 있다.

(2) 행정행위의 효력을 부인하는 것이 선결문제인 경우

- ① 민사법원이 당해 행정행위를 취소하여 위법한 행정행위의 효력을 상실시키는 것은 행정행위의 구성요건적 효력에 반한다.
- ② 판례는 행정처분의 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 인정될 경우 이를 전제로 판

단 할 수 있으나, 그 하자가 단순한 취소사유에 그칠 때에는 법원은 그 효력을 부인할 수 없다고 판시하였다.

IV. 사안의 해결

민사법원이 소유권이전등기말소청구소송에서 인용판결을 내리기 위해서는 등기원인이 무효이어야 한다. 그러나 수용재결의 하자가 취소사유에 불과하므로 민사법원이 수용재결의 효력을 부인하는 것은 행정행위의 구성요건적 효력에 반한다. 따라서 乙의 소유권이전등기의 원인인 수용재결은 유효하므로, 소유권이전등기말소청구는 인용될 수 없을 것이다.

【문제 2】 30점**(물음1) (20점)****I. 논점의 정리**

법령보충적 행정규칙인 표준지공시지가 조사·평가 기준의 법적 성질을 바탕으로 甲 주장의 타당성을 검토한다.

II. 표준지공시지가의 개관**1. 의의 및 취지(부동산공시법 제3조 제1항)**

- ① 표준지공시지가란 국토교통부장관이 토지이용상황, 주변환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지의 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가격을 말한다(부동산공시법 제3조 제1항).
- ② 이는 적정가격을 공시하여 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하는데 취지가 있다.

2. 법적 성질

- ① 행정행위설, 행정규칙설, 행정계획설, 법규명령의 성질을 갖는 고시설 등의 견해가 있다.
- ② 판례는 표준지 공시지가결정의 처분성을 인정하는 이유에 대하여는 언급하지 않고, 공시지가에 불복하기 위해서는 공시지가 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 한다고 하여 처분임을 긍정하고 있다.
- ③ 표준지공시지가를 전제로 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 후속 처분이 예정되어 있으므로, 이를 조기에 다투어 법률관계를 확정하고 법적 안정성을 도모할 필요가 있다. 따라서 표준지공시지가의 처분성을 인정하는 행정행위설이 타당하다.

III. 법령보충적 행정규칙**1. 의의 및 근거**

- ① 법령보충적 행정규칙이란 법률의 위임에 의해 법령을 보충하는 법규사항을 정하는 행정규칙을 말한다.
- ② 행정기본법 제2조 법령에서도 이를 명문화하고 있다.

2. 법적 성질(대외적 구속력 인정논의)**1) 학설**

- ① 법규명령설은 실질을 중시하는 견해로서 상위법령을 보충·구체화 하는 기능이 있는 훈령·고시 등의 대외적 구속력을 긍정하여 법규명령으로 본다.
- ② 행정규칙설은 형식을 중시하는 견해로서 법규명령 형식은 대통령령·총리령·부령으로 한정되어 있으므로 이러한 형식에 의하지 않은 훈령 등은 행정규칙이라고 본다.
- ③ 수권여부기준설은 상위법령의 수권 유무에 따라 구분하는 견해로서, 위임 있다면 법규명령으로 보고 위임이 없는 경우에는 행정규칙으로 본다.
- ④ 규범구체화 행정규칙설은 대외적으로는 법적 구속력을 인정하나, 내부적으로는 상위법령을 구체화하는 규범구체화 행정규칙으로 본다.

2) 판례**(1) 대법원**

- ① 행정규칙의 형식으로 제정된 것이라도 상위법령의 위임이 있고, 위임의 한계를 벗어나지 않으며, 상위법령의 내용을 보충하는 기능을 가지는 경우에는 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 법규명령이라고 보았다.
- ② 다만, 법률의 위임을 받은 것이기는 하나 행정적 편의를 도모하기 위한 절차적 규정은 법률보충적 행정규칙이 아니라 단순한 행정규칙이라고 보았다.

(2) 헌법재판소

헌법이 인정하고 있는 위임입법의 형식은 예시적인 것이라 하면서 대법원의 입장과 마찬가지로 법령보충적 행정규칙의 대외적 구속력을 인정한다.

3) 검토

- ① 상위법령의 위임이 있는 경우에는 그와 결합하여 법령을 보충하므로 법규성을 인정하는 것이 행정현실상 타당하다고 판단된다.
- ② 다만, 일반적인 법규명령절차를 거치지 않기 때문에 국민의 예측가능성을 고려하여 고도의 전문적 영역에 한정되어 최소한도로 인정해야 할 것이다.

IV. 표준지조사평가기준의 대외적 구속력 여부

표준지공시지가 조사·평가 기준은 훈령의 형식이지만, 상위법령인 부동산공시법 시행령 제6조 제3항의 위임에 근거하고, 그 내용도 표준지공시지가의 조사·평가에 한정되어 상위법령을 보충하는 기능을 하므로, 상위법령과 결합하여 대외적 구속력이 인정된다.

V. 甲 주장의 타당성

표준지공시지가 조사·평가 기준은 법령보충적 행정규칙으로서 대외적 구속력이 인정된다. 따라서 표준지공시지가의 평가는 동기준에 따라 이루어져야 하므로, 이를 고려한 것은 위법하지 않으며, 甲의 주장은 타당하지 않다.

(물음2) (10점)**I. 논점의 정리**

행정심판법 제51조는 행정심판의 재청구를 금지하고 있으므로, 부동산공시법 제11조에 따른 이의신청의 법적 성질에 따라 행정심판 청구 가능 여부가 달라진다. 따라서 이를 바탕으로 甲이 행정심판법상 행정심판을 제기할 수 있는지 검토한다.

II. 이의신청**1. 의의 및 취지(부동산공시법 제11조)**

- ① 이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 공시일부터 30일 이내에 시장·군수·구청장에게 이의를 신청하는 것을 말한다.
- ② 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.

2. 성격

1) 구별기준

(1) 학설

- ① 심판기관기준설은 행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다.
- ② 불복절차기준설은 준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.

(2) 판례

국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 불복절차기준설을 취하고 있는 것으로 보인다.

(3) 검토

헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

2) 소결

- ① 부동산공시법에서는 이의신청절차를 준사법적 절차로 하는 어떠한 규정도 두고 있지 않으므로 부동산공시법상 이의신청은 행정심판이 아니라고 보는 것이 타당하다.
- ② 판례도 [부동산공시법]에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다.

Ⅲ. 사안의 해결

甲이 제기한 이의신청은 강학상 이의신청으로서, 그에 대한 기각결정은 행정심판에 대한 재결이 아니다. 따라서 행정심판법 제51조의 재청구 금지규정은 적용되지 않으므로, 甲은 행정심판법상 행정심판을 제기할 수 있다.

【문제 3】 20점**(물음1) (10점)****I. 논점의 정리**

원처분주의를 바탕으로 행정심판위원회의 변경명령재결에 따라 변경(감경)처분이 이루어진 경우 취소소송의 소의 대상을 검토한다.

II. 원처분주의와 재결주의**1. 의의****1) 원처분주의**

① 원처분과 재결 모두 취소소송의 대상이 될 수 있으나, 원처분의 위법은 원처분취소소송에서만 주장할 수 있고, 재결취소소송에서는 원처분의 위법은 주장할 수 없고, 재결 자체의 고유한 위법만을 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

② 여기서 재결 자체의 고유한 위법이란 원처분에는 없고 재결 자체에만 존재하는 위법을 의미하는 것으로 재결 자체의 주체·내용·절차·형식의 위법이 있는 경우를 말한다.

2) 재결주의

원처분에 대해서는 소송을 제기할 수 없고, 재결에 대해서만 소송을 제기할 수 있도록 하되, 재결 자체의 위법뿐만 아니라 원처분의 위법도 재결취소소송에서 주장할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

2. 현행법상 태도

행정소송법 제19조는 취소소송은 처분등을 대상으로 하되, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다고 규정하고 있으므로 원처분주의를 택하고 있다.

III. 변경명령재결에 따른 변경처분 시 소의 대상**1. 학설**

① 변경된 원처분설은 변경처분은 원처분에 흡수되므로 변경되고 남은 원처분이 소송의 대상이 된다고 본다.

② 변경처분설은 변경명령재결에 따른 변경처분은 원처분을 대체하는 새로운 처분으로 보고 변경처분이 소의 대상이 된다고 본다.

2. 판례

일부인용의 처분명령재결에 따라 당초처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 그 취소소송의 대상은 <변경된 내용의 당초처분>이라고 판시한 바 있다.

3. 검토

행정소송법 제19조 단서는 재결 자체의 고유한 위법이 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 해야 한다고 규정하고 있는 바, 변경명령재결 자체에 고유한 위법이 없다면 일부취소 또는 변경되고 남은 원처분을 소의 대상으로 보는 것이 타당하다.

IV. 사안의 해결

행정심판위원회의 변경명령재결 자체에 고유한 위법이 없다면, 변경명령재결에 따라 감경되고 남은 원처분인 2개월의 업무정지처분이 취소소송의 대상이 된다. 이 경우 제소기간은 행정소송법 제20조 제1항 단서에 따라 변경명령재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내이다.

(물음2) (10점)

I. 논점의 정리

감정평가법 제41조 과징금 부과 제도를 바탕으로 과징금의 부과가능성과 과징금 납부의무를 불이행하는 경우 국토교통부장관의 조치에 대해 검토한다.

II. 과징금 부과가능성

1. 과징금의 의의 및 종류

- ① 과징금이란 행정법상 의무를 불이행하였거나 위반한 자에게 가해지는 금전적 부담을 말한다.
- ② 과징금에는 행정법상 의무위반으로 인하여 얻은 경제적 이익을 박탈하는 본래적 과징금과, 공익보호를 위해 업무정지 등에 갈음하여 부과하는 변형된 과징금이 있다.

2. 감정평가법 제41조의 과징금

1) 부과요건

국토교통부장관은 감정평가법인등이 업무정지사유에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 표준지공시지가의 조사·평가 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분에 갈음하여 5,000만원(감정평가법인의 경우는 5억 원)이하의 과징금을 부과할 수 있다.

2) 법적 성질

감정평가법 제41조의 과징금은 공익보호를 위해 업무정지처분에 갈음하여 부과되는 변형된 과징금이며, 과징금 부과는 금전급부하명으로서 침익적 처분이고, '부과할 수 있다'고 규정하고 있으므로 재량행위에 해당한다.

3. 소결

감정평가법 제41조에 따라 국토교통부장관은 甲에게 업무정지처분을 하는 경우 공익을 해칠 우려가 있을 때에는 업무정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있다.

III. 과징금 납부의무 불이행 시 국토교통부장관의 조치

1. 가산금 징수(감정평가법 제44조 제1항)

국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 가산금을 징수할 수 있다.

2. 독촉 및 국세 체납처분 예에 따른 징수(감정평가법 제44조 제2항)

국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 내에 과징금이나 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

【문제 4】 10점**I. 개설**

- ① 감정평가사는 타인의 의뢰를 받아 토지 등을 감정평가하는 것을 그 직무로 한다(감정평가법 제4조 제1항).
- ② 감정평가는 사회성·공공성이 크므로 감정평가법은 일정한 자격과 요건을 갖춘 감정평가법인등만이 감정평가를 할 수 있도록 하고, 이에 수반되는 권리·의무·책임을 규정하고 있다.
- ③ 감정평가법 제28조는 부당한 감정평가 등을 한 경우의 민사상 손해배상책임을 규정하고, 아울러 그 책임의 이행을 확보하기 위한 필요한 조치와 이를 이행하지 않은 경우의 행정상 제재도 함께 규정하고 있다.

II. 손해배상책임 보장을 위한 필요한 조치**1. 보증보험 또는 공제사업에 가입(감정평가법 제28조 제2항 및 동법 시행령 제23조)**

- ① 감정평가법인등은 손해배상책임을 보장하기 위하여 보증보험에 가입하거나 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입해야 한다.
- ② 보증보험에 가입한 감정평가법인등은 그 사실을 국토교통부장관에게 통보해야 하고,
- ③ 보험 가입 금액은 감정평가사 1명당 1억원 이상이어야 한다.
- ④ 또한 감정평가법인등이 보증보험금으로 손해배상을 한 경우에는 10일 이내에 보험계약을 다시 체결해야 한다.

2. 손해배상 결정 시 국토교통부장관에 대한 통지(감정평가법 제28조 제3항)

감정평가법인등은 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 법원의 확정판결로 손해배상책임이 확정된 경우, 그 사실을 지체 없이 국토교통부장관에게 알려야 한다.

III. 필요한 조치 불이행 시 행정상 제재**1. 인가취소 또는 업무정지 (감정평가법 제32조 제1항)**

국토교통부장관은 감정평가법인등이 감정평가법 제28조 제2항을 위반하여 보험 또는 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하지 않은 경우, 그 설립인가를 취소(감정평가법인에 한정한다)하거나 2년 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다.

2. 과태료 부과 (감정평가법 제52조 제2항)

감정평가법인등이 감정평가법 제28조 제2항에 따른 보험 또는 공제가입 등 필요한 조치를 이행하지 않은 경우 400만원 이하의 과태료가 부과된다.

2기 8주차 예시답안

[문제1] (40점)**(물음1) (10점)****I. 보상에 관한 협의의 법적 성격****1. 의의, 취지, 근거**

- ① 협의란 수용재결 신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 절차이다.
- ② 토지보상법이 사업인정 이전과 이후에 협의절차를 중복적으로 두고 있는 것은 강제적으로 재산권을 취득하기보다 가급적 상대방의 협력을 구하여 사업의 원활을 기하기 위해서이다. ③ 사업인정 전 협의는 토지보상법 제16조에, 사업인정 후 협의는 동법 제26조에 규정하고 있다.

2. 법적 성질**1) 학설****(1) 사법상 계약설**

협의의 결과 성립하는 합의는 사업시행자와 토지소유자 및 관계인 사이에 대등한 관계에서 맺어진 임의적인 합의이므로 사법상 매매계약으로 보는 견해이다.

(2) 공법상 계약설

협이가 불성립하는 경우 차후에 강제수용절차가 예정되어 있고, 공익사업이라는 공공의 목적을 달성하기 위해 체결되는 계약이므로 공법상 계약으로 보는 견해이다.

2. 판례

- ① 대법원은 사업인정 전·후 협의 모두 사법상 계약으로 본다.
- ② 다만, 사업인정 후 협의와 관련된 최근 판례에서 협의취득의 배후에는 수용에 의한 강제취득 방법이 남아 있어 토지 등의 소유자로서는 협의에 불응하면 바로 수용을 당하게 된다는 심리적 강박감이 자리 잡을 수밖에 없으며 협의취득 과정에는 여러 가지 공법적 규제가 있는 등 공익적 특성을 고려하여야 한다고 판시하였다.

3. 검토

- ① <사업인정 전 협의>는 사업시행자가 사업인정을 통해 행정주체로서의 지위를 갖기 전이므로, 그 협의로 행정상 법률관계가 형성된다고 보기 어렵다. 따라서 <사법상 계약>으로 보는 것이 타당하다.
- ② <사업인정 후 협의>는 사업인정 전 협의와 달리, 사업시행자에게 수용권이 주어진 상태에서 이루어지고, 협의에 불응하면 수용재결을 당하게 된다는 심리적 강박감이 있는 공익적 특성을 고려할 때 <공법상 계약>으로 보는 것이 타당하다.

II. 사업인정 후 협의취득의 법적 성격

- ① 사업인정 후 협의취득은 사업시행자가 원소유자에게 협의에 따른 보상금을 지급하고 소유권을 이전받는 것이므로 <승계취득>의 성격을 가진다.
- ② 다만, 토지보상법 제29조에 따른 협의성립확인이 이루어진 경우에는, 수용재결의 경우와 마찬가지로 <원시취득>의 효과가 인정된다.

(물음2) (20점)**I. 논점의 정리**

사업인정의 내용상 요건과 관련 규정을 바탕으로, ① 문화유산 보호를 이유로 공용수용을 할 수 있는지, ② 乙에게 수용권한이 인정되는지에 대한 甲 주장의 타당성을 검토한다.

II. 사업인정**1. 의의 및 취지(토지보상법 제20조)**

- ① 사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.
- ② 사업인정은 당해 사업이 공공성이 있는가를 개별·구체적으로 판단하여 <피수용자의 권리를 보호>하고, 이에 의해 수용가능여부가 결정되는 수용절차의 제1단계로서 <수용행정의 적정화>, <사전적 권리구제>장치로서의 역할을 한다.

2. 법적 성질

사업인정은 사업시행자에게 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 하여 일정한 내용의 수용권을 설정해 주는 형성적 행정처분으로서, 재량행위이자 제3자효 행정행위이다.

3. 내용상 요건

- ① 공익사업이 토지보상법 제4조의 각 호 중 하나에 해당하여야 한다.
- ② 공공필요는 <공익성>과 <필요성>이라는 2가지 측면에서 판단한다. 먼저, <공익성>은 수용 또는 사용을 허용하고 있는 개별 법률의 입법목적*사업내용 및 사업이 입법목적에 이바지하는 정도 등을 고려하여 판단하고, <필요성>은 수용 또는 사용을 통하여 달성하려는 공익과 침해당하는 공익 및 사익을 비교·형량하여 공익 및 사익에 대한 침해를 정당화할 정도의 공익 우월성이 있는지 등을 고려하여 판단한다.
- ③ 또한 사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다.

IV. 甲 주장 1의 타당성 검토**1. 수용적격사업인지 여부**

수용적격사업이란 수용주체가 수용할 수 있는 적격을 갖는 공익사업을 말한다. 토지보상법 제4조 별표는 문화재보호법상 문화유산의 보존·관리를 위한 사업을 사업인정을 받을 수 있는 수용적격사업으로 규정하고 있다.

2. 공공필요가 인정되는지**1) 공익성 인정여부**

甲의 부지는 국가지정문화유산 B유적지 보호구역에 위치하고, 백제 토성의 유물이 발견되는 등 역사적 가치에 비추어 볼 때, 이를 복원·정비하기 위한 사업은 <공익성>이 인정된다.

2) 필요성 인정여부

공장 운영에 따른 불이익은 영업보상 등으로 일정 부분 구제될 수 있으므로, 甲에게 발생하는 사익침해가 문화유산의 가치 보호라는 공익에 비추어 크다고 보기 어려워 <필요성>도 인정된다.

3. 사업시행자에게 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있는지 여부

乙은 A구청장으로서 사업수행의사나 능력은 문제되지 않는 것으로 보인다.

4. 소결

문화재보존을 위한 사업은 토지보상법이 규정하고 있는 수용적격사업에 해당하고, 수용을 해야 할 공공필요성이 인정된다. 또한 사업시행자의 사업수행의사나 능력도 충족된다. 따라서 甲의 주장은 타당하지 않다.

V. 甲 주장 2의 타당성 검토**1. A구청장 乙에게 수용권한이 인정되는지 여부**

문화재보호법 제83조 제1항에서 국가유산청장 또는 지방자치단체의 장은 문화유산의 보존·관리를 위하여 필요하면 지정문화유산이나 그 보호구역에 있는 토지 등을 토지보상법에 따라 수용하거나 사용할 수 있다고 규정한다.

2. 소결

문화재보호법이 지방자치단체의 장도 수용할 수 있다고 규정하고 있고, 문화재의 지정권자만이 토지 등을 수용할 수 있다는 등의 제한을 두고 있지 않다. 그리고 乙은 토지보상법 제20조에 따라 국토교통부장관에게 사업인정을 신청하여 그 요건을 갖추어 사업인정을 받았으므로 적법하게 수용권이 설정되었다. 따라서 甲의 주장은 타당하지 않다.

보충자료 : 관련 판례(2017두 71031)

문화재보호법은 지방자치단체 또는 지방자치단체의 장에게 시·도지정문화재뿐 아니라 국가지정문화재에 대하여도 일정한 권한 또는 책무를 부여하고 있고, 문화재보호법에 해당 문화재의 지정권자만이 토지 등을 수용할 수 있다는 등의 제한을 두고 있지 않으므로, 국가지정문화재에 대하여 관리단체로 지정된 지방자치단체의 장은 문화재보호법 제83조 제1항 및 토지보상법에 따라 국가지정문화재나 그 보호구역에 있는 토지 등을 수용할 수 있다고 판시했다.

(물음3) (10점)**I. 논점의 정리**

토지보상법 시행규칙 제45조를 바탕으로 甲의 영업손실에 대한 보상 요건을 검토한다.

II. 영업손실보상**1. 의의, 성격**

- ① 영업손실이란 수용대상이 된 토지·건물 등을 이용하여 영업을 하다가 그 토지·건물 등이 수용됨으로 인하여 영업을 할 수 없거나 제한을 받게 됨으로 인하여 생기는 직접적인 손실을 말한다.
- ② 영업손실보상(제77조 제1항)은 주로 재산권보상 중에서 일실손실의 보상이며 구체적 내용에 따라 생활보상의 성격과 간접보상의 성격도 가진다.

2. 구체적 요건

1) 시간적 요건

영업손실보상의 대상이 되려면 사업인정고시일등(사업인정고시일과 보상계획공고일 중 빠른 날) 이전부터 영업을 하고 있어야 한다.

2) 장소적 요건

영업손실보상의 대상이 되려면 적법한 장소에서 이루어진 영업이어야 한다. 이는 불법행위에 의한 영업은 보상대상에서 제외하는 것에 취지가 있다. 다만, 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 영업을 행한 경우에는 보상대상이 된다.

3) 시설적 요건

영업손실보상의 대상이 되려면 일정한 정도의 인적·물적 시설을 갖추어야 한다.

4) 계속적 요건

영업손실보상의 대상이 되기 위해서는 계속적으로 영업을 하여야 한다. 판례는 매년 일정한 계절이나 일정한 기간에만 영업을 하는 경우에도 계속적 영업에 해당한다고 판시하였다.

5) 허가 등의 요건

영업을 함에 있어 관계 법령에 따른 허가 등을 필요로 하는 경우에는, 사업인정고시일등 전에 그 허가 등을 받아 그 내용대로 영업을 하고 있어야 한다.

Ⅲ. 甲의 영업손실 보상 요건 검토

甲은 30년 넘게 콘크리트 제조공장을 허가받아 적법하게 운영해 왔으므로, 특별한 사정이 없는 한 토지보상법 시행규칙 제45조가 정한 시간적·장소적·시설적·계속적·허가 요건을 모두 충족하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 甲은 수용이 이루어질 경우 영업손실보상을 받을 수 있다.

【문제 2】 30점**(물음1) (15점)****I. 논점의 정리**

개별공시지가 정정불가 결정 통지가 취소소송의 대상이 되는 거부처분에 해당되는지를 바탕으로 대상적격 여부를 검토한다.

II. 개별공시지가의 정정(부동산공시법 제12조)

개별공시지가의 정정이란 시장 등이 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오 그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하는 것을 말한다.

III. 거부의 처분성**1. 취소소송의 대상(행정소송법 제19조)**

취소소송은 처분 등을 대상으로 하며, 처분 등이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용 및 행정심판에 대한 재결을 말한다

2. 거부행위가 처분이 되기 위한 요건

① 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용일 것, ② 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떠한 변동을 일으킬 것이 요구되며, ③ 법규상 또는 조리상의 신청권이 필요한지 여부 대해서는 견해가 대립된다.

3. 신청권 존부에 대한 견해 대립

- ① 신청권의 존부를 원고적격의 문제로 보는 견해, 본안요건으로 보는 견해, 대상적격으로 보는 견해가 대립한다.
- ② 판례는 신청권이란 신청인이 누구인가를 고려하지 않고, 단순한 응답받을 권리를 의미한다고 보았으며, 개인에게 법규상 또는 조리상 신청권이 있다면 그 거부행위는 항고소송의 대상인 처분으로 보아야 한다고 판시하여 대상적격설을 취하고 있다.
- ③ 현행 행정소송법은 신청권에 대응하는 처분의무를 부작위의 요소로 규정하고 있고, 거부처분 개념은 부작위개념과 연결되어 있으므로 현행 행정소송법하에서는 신청권을 거부처분의 요건으로 보는 것이 타당하다.

IV. 정정불가 결정 통지 대상적격 검토**1. 관련 판례(2000두5043)**

국민의 정정신청은 행정청의 직권 발동을 촉구하는 것에 지나지 않는다고 하여, 이른바 관념의 통지에 불과할 뿐 항고소송의 대상이 되는 처분이 아니라고 판시하였다.

2. 결론

- ① 甲이 신청한 개별공시지가 정정은 공권력 행사에 해당하며, ② 개별공시지가는 과세처분 등의 직접적 기준이 되므로 신청인의 법률관계에 영향을 미친다. ③ 다만, 부동산공시법 제12조의 정정은 개별공시지가에 오류가 있음을 발견한 경우 이를 행정청이 직권으로 정정하

도록 한 규정일 뿐, 토지소유자 등에게 정정결정을 신청할 수 있는 권리를 인정하고 있지 않으므로 신청권이 부정된다. 따라서 정정불가 결정 통지는 거부처분에 해당하지 않는다.

④ 다만, 행정절차법 제25조에 따라 신청권이 인정된다면 정정불가 결정 통지는 거부처분으로서 취소소송의 대상이 될 수 있을 것이다.

cf) **행정절차법 제25조(처분의 정정)**

행정청은 처분에 오기(誤記), 오산(誤算) 또는 그 밖에 이에 준하는 명백한 잘못이 있을 때에는 직권으로 또는 신청에 따라 지체 없이 정정하고 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다.

(물음2) (15점)

I. 논점의 정리

토지특성조사 착오가 명백한 경우만 정정 결정을 할 수 있는지 여부와 정정의 효력을 바탕으로 각 주장의 타당성을 검토한다.

II. 甲 주장 i의 타당성

1. 관련 규정

① 부동산공시법 제12조는 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 경우를 개별공시지가의 정정사유로 규정하고 있다.

② 이에 따라, 동법 시행령 제23조 제1항은 명백한 오류의 내용을 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우, 용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요 요인 조사에 잘못이 있는 경우, 토지가격비준표 적용에 오류가 있는 경우로 규정하고 있다.

2. 관련 판례(93누 15588)

토지특성조사의 착오 또는 위산, 오기는 지가산정에 명백한 잘못이 있는 경우의 예시로서, 이러한 사유가 있으면 경정 결정할 수 있는 것으로 보아야 하고, 그 착오가 명백하여야 비로소 경정 결정할 수 있다고 해석할 것은 아니라고 판시한 바 있다.

3. 소결

① 부동산공시법 시행령 제23조 제1항은 명백한 오류의 예시규정이다.

② 여기서 제시된 사유가 명백한 경우에 한하여만 정정할 수 있다고 보는 것은 법규정에 대한 해석의 오류라고 볼 수 있다.

③ 따라서 판례처럼 이 규정에 예시된 사유가 발생한 경우에는 명백한 오류인지를 불문하고 정정할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

④ 사안의 토지특성조사 착오는 토지가격에 영향을 미치는 주요 요인 조사상의 오류에 해당하므로, 구청장 乙은 그 착오의 명백성 여부와 관계없이 이를 정정할 수 있다. 따라서 甲의 주장은 타당하지 않다.

Ⅲ. 甲 주장ii의 타당성**1. 정정의 효력(소급효)**

대법원은 경정결정되어 공시된 이상 당초에 결정·공시된 개별공시지가는 그 효력을 상실하고 경정결정된 새로운 공시지가가 공시기준일에 소급하여 그 효력을 발생한다고 한다.

2. 소결

정정된 개별공시지가는 당초 공시기준일에 소급하여 효력을 가지며, 기존 개별공시지가는 그 효력을 상실한다. 따라서 정정결정된 개별공시지가를 기준으로 한 증여세부과처분은 적법하므로, 甲의 주장은 타당하지 않다.

【문제 3】 20점**I. 논점의 정리**

행정행위의 하자의 승계를 바탕으로, 수용재결취소소송에서 선행행위인 사업인정의 절차상 하자를 이유로 수용재결의 위법을 주장할 수 있는지 검토한다.

II. 관련 행정작용의 법적 성질**1. 사업인정(토지보상법 제20조)**

사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말하며, 사업인정은 사업시행자에게 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 하여 일정한 내용의 수용권을 설정해 주는 형성적 행정처분이다.

2. 수용재결(토지보상법 제34조)

수용재결이란 사업인정고시 후 협의불성립·불능의 경우 사업시행자의 재결신청에 의해 관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차를 말하며, 수용재결은 사업시행자의 수용권의 구체적 내용을 결정하고 그 실행을 완성시키는 형성적 행정처분이다.

III. 사업인정 절차상 하자의 위법성의 정도

- ① 사안의 사업인정은 토지보상법 제21조에 따른 의견청취 절차를 거치지 않았으므로 절차상 하자가 존재한다.
- ② 절차상 하자가 독자적 위법사유가 되는지에 대해 긍정설, 부정설, 절충설이 대립한다.
판례는 재량행위와 기속행위를 불문하고 절차상 하자는 독자적인 위법사유가 될 수 있다고 본다. 생각건대, 행정소송법 제30조 제3항에서 취소소송 등의 기속력이 절차의 위법을 이유로 하는 경우에도 준용되므로 긍정설이 타당하다.
- ③ 사안의 의견청취 결여는 적법요건의 중대한 위반이지만, 일반인의 관점에서 외관상 명백하다고 보기 어려우므로 취소사유에 해당한다.

IV. 하자의 승계**1. 의의**

하자승계란 둘 이상의 행정행위가 연속적으로 이루어지는 경우에, 선행행위의 하자를 이유로 후행행위를 다룰 수 있는지에 대한 문제를 말한다.

2. 전제조건

- ① 선행행위와 후행행위가 모두 항고소송의 대상이 되는 처분일 것, ② 선행행위는 취소사유가 존재할 것, ③ 후행행위는 적법할 것, ④ 선행행위는 불가쟁력이 발생할 것이 요구된다.

3. 인정범위**1) 학설**

- ① 선행행위와 후행행위가 결합하여 하나의 법적 효과를 완성하는 경우에는 하자의 승계를 인정하는 하자승계론과 ② 선행행위가 후행행위에 대하여 구속력이 미치는 범위(한계)내에서는 하자의 승계를 부정하는 구속력론이 대립한다.

2) 판례

- ① 원칙적으로 하자승계론에 따라 판단하고 있다.
- ② (ㄱ) 대집행절차상 계고*영장에 의한 통지*대집행의 실행*비용징수의 각 행위, (ㄴ)강제징수절차상 독촉*압류*매각*청산의 각 행위 사이에는 하자승계를 긍정하였다.
- ③ 반면 (ㄱ)표준지공시지가결정과 개별공시지가결정, (ㄴ)표준지공시지가결정과 조세부과처분, (ㄷ)건물철거명령과 대집행 계고, (ㄹ)사업인정과 수용재결 사이, (ㄴ) 재조사청구 조정결정 통지를 받은 개별공시지가결정과 과세처분 사이에는 하자승계를 부정하였다.
- ④ 다만, (ㄱ)개별통지가 없는 개별공시지가결정과 과세처분, (ㄴ)표준지공시지가결정과 재결(보상금증감청구소송)은 별개의 법적효과를 목적으로 함에도 불구하고, 예측가능성이 없고, 수인한도를 넘는 경우에는 하자승계를 긍정한 바 있다.

3) 검토

- ① 하자승계론은 일정한 기준을 제시하여 객관적이고, 구속력론은 예측 가능성과 수인 가능성을 고려한다는 점에서 구체적 타당성을 기할 수 있으므로 양자 모두 합리성이 인정된다.
- ② 따라서 하자승계론을 기준으로 예측가능성이 있는지, 수인한도를 넘는지 등의 사정을 종합 고려하여 하자승계여부를 개별적·구체적으로 판단함에 타당하다.

4. 사안의 경우

1) 전제조건 충족 여부

- ① 사업인정과 수용재결은 모두 항고소송의 대상이 되는 처분이고,
- ② 선행행위인 사업인정에는 취소사유가 존재하며,
- ③ 사업인정에 대한 취소소송의 제소기간이 도과하여 불가쟁력이 발생하였다.
- ④ 또한 후행행위인 수용재결은 특별한 사정이 없는 한 적법하므로 전제조건이 충족된다.

2) 인정여부 검토

(1) 관련 판례

사업인정처분 자체의 위법은 사업인정단계에서 다투어야 하고 이미 그 쟁송기간이 도과한 수용재결단계에서는 사업인정처분이 당연 무효라고 볼 만한 특단의 사정이 없는 한 그 위법을 이유로 재결의 취소를 구할 수는 없다고 판시했다(91누4324).

(2) 소결

- ① 사업인정은 토지보상법 제4조의 공익사업임을 인정하고 수용권을 설정해주는 행위이나, 수용재결은 수용권의 내용을 결정하고 그 실행을 완성시키는 행위이므로, 양자는 별개의 법률효과를 목적으로 한다.
- ② 또한 甲에게 사업인정을 현실적으로 다투는 것이 불가능하다고 볼만한 특별한 사정이 존재하지 않으므로, 甲의 예측가능성과 수인가능성이 침해되었다고 보기 어렵다.
- ③ 따라서 하자의 승계는 인정되지 않는다.

V. 결론

사업인정의 하자가 수용재결에 승계되는 것은 인정되지 않으므로 수용재결취소소송에서 사업인정의 절차상 하자를 이유로 수용재결의 위법을 주장할 수 없다.

【문제 4】 10점**I. 감정평가법 제25조 성실의무등의 내용****1. 품위유지 및 신의성실의무**

감정평가법인등은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 감정평가를 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니 된다.

2. 불공정한 감정평가 금지

감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정한 감정평가를 할 우려가 있다고 인정되는 토지 등에 대해서는 이를 감정평가하여서는 아니 된다.

3. 토지등의 매매업 금지

감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.

4. 금품수수 금지

감정평가법인등이나 그 사무직원은 제23조에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 되며, 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다.

5. 중복소속 금지

감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없으며, 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.

6. 감정평가 유도, 요구에 따른 평가 금지

감정평가법인등이나 사무직원은 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 경우, 이에 따라서는 아니된다.

7. 관련 판례 : 감정평가법인에게 적용되는 성실의무의 내용

감정평가법인인 경우에 실질적인 감정평가업무는 소속감정평가사에 의하여 이루어질 수밖에 없으므로, 감정평가법인이 감정평가의 주체로서 부담하는 성실의무란, 소속감정평가사에 대한 관리·감독의무를 포함하여 감정평가사 심사 등을 통해 감정평가 과정을 면밀히 살펴 공정한 감정평가결과가 도출될 수 있도록 노력할 의무를 의미한다고 판시했다.